

DIGESTO

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

MANUAL DE ESTUDIO · NIVEL EXAMEN DE GRADO

Elaborado por **Laura Schultz Solano**

Texto refundido a partir de los apuntes de Cristián Boetsch Gillet y Juan Andrés Orrego Acuña, con desarrollo de Rodríguez Grez (el daño), Pizarro Wilson y Aedo Barrena, jurisprudencia seleccionada y comparaciones doctrinales · Versión Junio 2026

ÍNDICE

1. Marco general de la responsabilidad contractual
 - a. Concepto de responsabilidad civil y de responsabilidad contractual
 - b. Los estatutos de responsabilidad y la regla general (arts. 1437 y 2284)
 - c. Sentido restringido y amplio. Los «efectos de las obligaciones»
 - d. El sistema de acciones o «remedios» del art. 1489
 - e. Sistema de atribución: responsabilidad subjetiva y objetivación
2. El incumplimiento contractual
 - a. Concepto y clases de incumplimiento (art. 1556)
 - b. Incumplimientos que no generan responsabilidad
 - c. Obligaciones de medio y de resultado
 - d. Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad
3. La acción de cumplimiento
 - a. Nociones generales y concepto
 - b. ¿Es el «derecho principal» del acreedor?
 - c. Objeto: cumplimiento en naturaleza y por equivalencia
 - d. Presupuestos de procedencia
 - e. Cumplimiento y ejecución forzada de obligaciones de dar, hacer y no hacer
 - f. Límites a la acción de cumplimiento: la imposibilidad

4. La resolución por incumplimiento
 - a. Generalidades y nomenclatura
 - b. La condición resolutoria tácita: concepto y fundamento
 - c. Características y ámbito de aplicación
 - d. El incumplimiento resolutorio
 - e. Necesidad de sentencia judicial
 - f. La acción resolutoria
 - g. Enervar la acción mediante el pago
 - h. El art. 1552 y la excepción de contrato no cumplido
 - i. Efectos de la resolución
 - j. Resolución, nulidad y resciliación
 - k. El pacto comisorio
 - l. La cláusula de término unilateral
5. La indemnización de perjuicios
 - a. Concepto y naturaleza jurídica
 - b. Clases: indemnización compensatoria y moratoria
 - c. ¿Es la indemnización un remedio autónomo?
 - d. Primer requisito: incumplimiento imputable (dolo y culpa)
 - e. Segundo requisito: el perjuicio (concepto, requisitos y clases)
 - f. Tercer requisito: la relación de causalidad
 - g. Cuarto requisito: la mora del deudor
 - h. Evaluación judicial de los perjuicios
 - i. Evaluación legal (art. 1559)
 - j. Evaluación convencional: la cláusula penal
6. Causales de exención de responsabilidad
 - a. El caso fortuito o fuerza mayor
 - b. La ausencia de culpa
 - c. El estado de necesidad
 - d. El hecho o culpa del acreedor
 - e. El hecho ajeno
 - f. La teoría de la imprevisión
 - g. La frustración del fin del contrato

7. Los derechos auxiliares del acreedor
 - a. El derecho de prenda general y su fundamento
 - b. Las medidas conservativas
 - c. La acción oblicua o subrogatoria
 - d. La acción pauliana o revocatoria
 - e. El beneficio de separación
8. Cláusulas que modifican la responsabilidad
 - a. Consideraciones generales
 - b. Reglas de interpretación de estas cláusulas
 - c. Análisis de determinadas cláusulas de estilo

1. MARCO GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

1.1. Concepto de responsabilidad civil y de responsabilidad contractual

En términos muy generales, la **responsabilidad** consiste en la necesidad efectiva, o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio. Se trata de una noción transversal a todo el Derecho —existe responsabilidad penal, administrativa, política, internacional— que en sede privada adquiere un sentido preciso.

En particular, la **responsabilidad civil** consiste en la necesidad en que se encuentra un individuo de tener que reparar un daño causado por su obrar doloso o culposo; tal necesidad se satisface por medio de la **indemnización de perjuicios**. Como se aprecia, la responsabilidad civil se encuentra esencialmente vinculada al daño que sufre una o más personas, y al deber de repararlo o compensarlo con medios equivalentes. En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto que *«por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado»*.

La **esencialidad del daño** que exige la responsabilidad civil constituye una notable diferencia con la responsabilidad penal: esta última contempla la existencia de figuras delictivas de mero peligro y sanciona conductas tentativas y frustradas, sin daño. En lo civil, por el contrario, sin daño no hay nada que indemnizar, y por tanto no hay responsabilidad: el daño es, a la vez, su presupuesto y la medida de la reparación.

JURISPRUDENCIA — NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Corte Suprema ha definido la responsabilidad, en general, como «la **obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado**». La idea de *reparación adecuada* reaparecerá al estudiar la indemnización: ésta debe dejar a la víctima, en lo posible, en la situación en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento (principio de reparación integral).

1.2. Los estatutos de responsabilidad y la regla general (arts. 1437 y 2284)

De conformidad al artículo **1437**, las obligaciones pueden encontrar **cinco fuentes**: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Frente al incumplimiento de una obligación, el Libro IV del Código Civil regula **dos estatutos jurídicos** de responsabilidad: en el Título XII («Del efecto de las obligaciones») se regula la **responsabilidad contractual**, referida al incumplimiento de obligaciones que surgen de un contrato; por su lado, el Título XXXV regula la **responsabilidad extracontractual**, que consiste en la obligación en que se encuentra el autor de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito —delito o cuasidelito— ha ocasionado a la víctima.

El estudio detallado de las diferencias entre ambos estatutos se realiza al analizar la responsabilidad extracontractual. Por ahora, interesa una pregunta de orden sistemático: ¿qué reglas de responsabilidad se aplican a las obligaciones nacidas *de la ley o de los cuasicontratos*? Dicho de otro modo, ¿cuál es la **regla general** en materia de responsabilidad: la contractual o la extracontractual?

Buena parte de la **doctrina tradicional** —fundada en los amplios términos del Título XII, «Del efecto de las obligaciones», que no hace distinciones— estima que las normas de los artículos 1545 y siguientes constituyen el **derecho común y general** en materia de indemnización de perjuicios, aplicándose cualquiera sea el origen de la obligación incumplida (contractual, cuasicontractual, legal, etc.). No se aplicarían, en cambio, a dos casos: **(a)** cuando la ley ha dado reglas distintas, como ocurre con la responsabilidad extracontractual proveniente de los delitos o cuasidelitos civiles, materia tratada especialmente en el Título XXXV del Libro IV (arts. 2314 y ss.); y **(b)** cuando las partes se han dado reglas especiales, haciendo uso del principio de la autonomía de la voluntad —con ciertas limitaciones, como

la que les impide renunciar anticipadamente al dolo o a la culpa grave (arts. 1465 y 44 inc. 1.º, parte final). Esta es la posición de **Stitchkin** y **Alessandri**.

Sin embargo, tal conclusión es a lo menos **cuestionable**. El Título «Del efecto de las obligaciones» discurre sobre la idea de una *estipulación previa entre las partes* (un contrato), sin considerar las obligaciones que surgen sin convención (legales, cuasicontractuales, delictuales y cuasidelictuales). Lo anterior se ve reforzado por el artículo **2284**, que precisamente distingue entre las obligaciones que se contraen *con* convención de las que se generan *sin* ella, dando a entender que estas últimas tienen una naturaleza diversa de las obligaciones contractuales. En razón de lo anterior, resulta más adecuado sostener que los artículos 1545 y siguientes, sobre responsabilidad contractual, se aplican **únicamente a las obligaciones contractuales**; en cambio, las obligaciones que encuentran su origen en la ley, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito quedan regidas por las normas de la responsabilidad extracontractual, contenidas en el Título XXXV del Libro IV.

Dato de grado — ¿Cuál es el estatuto «de derecho común»?

Pregunta clásica de cédula. **Tesis tradicional** (Alessandri, Stitchkin): el estatuto contractual (arts. 1545 y ss.) es el derecho común, y se aplica supletoriamente a las obligaciones legales y cuasicontractuales. **Tesis moderna y más correcta** (apoyada en los arts. 1437 y 2284): el Título XII supone un contrato, de modo que las obligaciones sin convención se rigen por el estatuto extracontractual, que sería el verdadero derecho común. Conviene exponer ambas y tomar partido fundadamente.

1.3. Sentido restringido y amplio. Los «efectos de las obligaciones»

Tradicionalmente, gran parte de la doctrina entiende la responsabilidad contractual en un **sentido restringido o estricto**: el deber u obligación de *indemnizar los perjuicios* causados por el incumplimiento del deudor. En esta acepción, la responsabilidad contractual se asimila a lo que usualmente se denomina «**cumplimiento por equivalencia**», y existe una íntima

vinculación de la responsabilidad con un hecho ilícito —el incumplimiento de la obligación contractual imputable a dolo o culpa del deudor—. Ligada a lo anterior —entender la responsabilidad contractual como una *sanción* a un hecho ilícito—, la doctrina tradicional señala como fundamento de la obligación de indemnizar la **culpabilidad del deudor**, esto es, la infracción dolosa o culposa del contrato. Para esta doctrina, que sustenta la responsabilidad *subjetiva* o por culpa, resulta esencial que el incumplimiento sea imputable a dolo o culpa del deudor.

Con todo, la doctrina nacional más moderna ha comenzado a abogar por un **sentido amplio**, que no agota la responsabilidad contractual en la indemnización de perjuicios, sino que la extiende al *conjunto de derechos y acciones* —que también denominan «**remedios**»— en cuya virtud el acreedor puede reclamar la satisfacción de su interés contractual. De acuerdo con esta concepción amplia, la responsabilidad contractual no sólo comprende acciones resarcitorias, sino también el derecho a obtener el *cumplimiento en naturaleza* (la prestación de lo debido) y las acciones destinadas a conservar el patrimonio del deudor (tradicionalmente, los *derechos auxiliares del acreedor*). Esta responsabilidad en sentido amplio se vincula, en buena medida, con una visión más **objetiva** de la responsabilidad, conforme a la cual su fundamento no es propiamente el obrar imputable a dolo o culpa. Como han observado **Cárdenas y Reveco**, lo novedoso no es la idea de un sistema de acciones ante el incumplimiento —que la doctrina nacional siempre ha estudiado de manera sistemática—, sino la pretensión de prescindir de la imputabilidad del incumplimiento y de comprender la relación obligatoria como una *garantía de resultado*.

Este giro hacia el sentido amplio es coherente con la propia ubicación y técnica del Código. Los artículos 1545 a 1559 conforman el Título XII del Libro IV y tratan «Del efecto de las obligaciones»; sin embargo, como advierte **Orrego** siguiendo a Alessandri, el Código **confunde en este título los efectos de los contratos con los efectos de las obligaciones**. En rigor, no deben confundirse: los *efectos de un contrato* son las obligaciones que crea (el contrato es la causa y la obligación el efecto); en tanto que el *efecto de las obligaciones* es la necesidad jurídica en que se halla el deudor de cumplirlas, para lo cual la ley confiere al acreedor ciertos derechos destinados a asegurar el cumplimiento. Reglamentan exclusivamente los *efectos de los contratos* los artículos 1545 (ley del contrato), 1546 (ejecución de buena fe), 1547 (grado de culpa de que se responde), 1552 (efec-

tos de la mora en los contratos bilaterales), 1554 (contrato de promesa) y 1558 (perjuicios de que responde el deudor según dolo o culpa). Reglamentan los *efectos de las obligaciones*, en cambio, los artículos 1548 (obligación de dar), 1549 (deber de conservación), 1550 (riesgo de la pérdida fortuita), 1551 (constitución en mora), 1553 (opciones del acreedor de obligación de hacer), 1555 (opciones del acreedor de obligación de no hacer), 1556 (qué comprende la indemnización), 1557 (desde cuándo se debe) y 1559 (indemnización moratoria en obligaciones de dinero).

Definidos así, los **efectos de las obligaciones** son las consecuencias que para el acreedor y el deudor surgen del vínculo jurídico que los liga. Lo normal en la vida jurídica es que el deudor cumpla voluntaria y espontáneamente su obligación; si ello no acontece, entramos en el ámbito de los efectos de las obligaciones, que pueden definirse —con Alessandri— como el **conjunto de medios que la ley confiere al acreedor para obtener el cumplimiento íntegro de la obligación** cuando el deudor no la cumple en todo o en parte o está en mora de cumplirla, o para obtener el pago de una indemnización compensatoria y moratoria cuando el deudor en definitiva no cumple. Estos medios son tres: **(1)** un derecho principal para exigir, en cuanto sea posible, la *ejecución forzada* de la obligación; **(2)** un derecho secundario y supletorio para exigir la *indemnización de perjuicios*; y **(3)** los *derechos auxiliares* destinados a dejar afecto el patrimonio del deudor al cumplimiento, manteniéndolo en condiciones de afrontar las obligaciones contraídas (medidas conservativas, acción oblicua o subrogatoria, acción pauliana o revocatoria y beneficio de separación de patrimonios).

No confundir — Efectos del contrato vs. efectos de la obligación

El **efecto del contrato** es *crear obligaciones* (el contrato es causa). El **efecto de la obligación** es la *necesidad jurídica de cumplir* y los medios que la ley da al acreedor si el deudor no cumple. El Código rotula el Título XII «Del efecto de las obligaciones», pero entremezcla ambos planos: por eso normas como el art. 1545 (ley del contrato) o el 1546 (buena fe) son, en rigor, efectos del *contrato*, no de la *obligación*.

1.4. El sistema de acciones o «remedios» del art. 1489

Concebida la responsabilidad contractual en sentido amplio, corresponde analizar el régimen de acciones que la ley confiere al acreedor frente al incumplimiento del contrato. Conviene partir por una premisa de método: en virtud del principio de **autonomía de la voluntad**, primero se aplica la regulación particular contenida en el contrato, si la hay. La ley otorga a los contratantes amplia libertad para reglamentar las más variadas materias —el grado de diligencia con que el deudor debe obrar, quién soporta los efectos del caso fortuito, la valuación anticipada de los perjuicios mediante una cláusula penal, multas por atrasos o incumplimientos, pactos comisorios, causales específicas de incumplimientos resolutorios, etc.—. Dicha autonomía reconoce los límites generales de los artículos 1461 y 1467 (el orden público, las buenas costumbres y la ley) y límites particulares (v. gr., la prohibición de condonar el dolo futuro). Sólo si las partes nada regularon, o lo hicieron de modo incompleto, se recurre a las normas legales supletorias.

La norma base y esencial relativa a los efectos del incumplimiento del deudor es el artículo **1489**. No obstante su ubicación —dentro del Título IV, sobre las obligaciones condicionales—, esta disposición consagra el catálogo de remedios con que cuenta el contratante diligente. Dispone que *«en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios»*. De aquí se desprenden tres derechos:

(a) Derecho a exigir el cumplimiento forzado de la obligación

El acreedor puede solicitar la **ejecución forzada** de la obligación, esto es, obtener —con el auxilio de la fuerza pública— el cumplimiento en naturaleza o pago de la obligación incumplida. Para ello, la ley civil y procesal distingue entre las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer (materia que se desarrolla en la Sección 3).

Cabe preguntarse si las partes pueden **renunciar** a la acción de cumplimiento forzado. Una posición minoritaria —fundada genéricamente en la autonomía de la voluntad— afirma que tal renuncia es factible. Pero la mayoría de los autores opina que **no es posible renunciar a la acción de**

cumplimiento, por la sencilla razón de que, de hacerlo, se desnaturalizaría por completo la obligación, que por definición es un vínculo jurídico que impone un deber cuyo cumplimiento es susceptible de ser exigido por la fuerza. Vista desde otra perspectiva, la renuncia anticipada al derecho a pedir el cumplimiento daría cuenta de una manifestación de voluntad que no es realmente seria (y, por tanto, ineficaz), o bien tal pacto equivaldría a una *condición meramente potestativa del deudor* —pactar tal renuncia es lo mismo que convenir «cumpliré la obligación si quiero»—, las que son nulas conforme al artículo **1478**. Lo que se encuentra fuera de toda duda es que no se puede renunciar a demandar *tanto* la ejecución forzada *como* la resolución en el evento de infracción: si no se pudiera compeler al deudor a cumplir ni sancionarlo por la infracción, se produciría una situación equivalente a la obligación contraída bajo la condición que consiste en la mera voluntad del que se obliga («me obligo si quiero»), por lo que esa renuncia es ineficaz.

(b) Derecho a solicitar la resolución del contrato

El acreedor puede pedir la **resolución —total o parcial—** del contrato del cual emanaba la obligación incumplida. Esta es la comúnmente denominada *condición resolutoria tácita*, en cuya virtud se otorga al acreedor el derecho a exigir la resolución por incumplimiento (materia de la Sección 4).

A diferencia del cumplimiento forzado, la ley **sí reconoce a las partes el derecho a renunciar anticipadamente a la acción resolutoria**. Tal renuncia no se traduce en que el incumplimiento quede impune: el acreedor conserva siempre su derecho a pedir el cumplimiento forzado (irrenunciable) y/o la correspondiente indemnización de perjuicios. La renuncia anticipada de la acción resolutoria da cuenta, en definitiva, del ánimo de las partes de que el contrato no se termine por el incumplimiento de una de ellas. Con todo, por amplios que sean los términos en que se hubiere pactado, jamás comprenderá el *incumplimiento doloso*, pues ello equivaldría a condonar el dolo futuro, pacto que no vale por adolecer de objeto ilícito conforme al artículo **1465**. Las partes también pueden darse una reglamentación contractual particular por vía de convenir pactos comisorios y causas específicas de incumplimientos resolutorios.

(c) Derecho a solicitar la indemnización de los perjuicios

Finalmente, el artículo 1489 permite pedir el cumplimiento o la resolución «*con indemnización de perjuicios*». La doctrina tradicional trata la indemnización como un «**cumplimiento por equivalencia**», atendido que el acreedor no obtendrá el pago de la obligación misma (la «prestación de lo que se debe»), sino que verá satisfecha su acreencia por una cantidad de dinero equivalente al cumplimiento en naturaleza. Como se verá en la Sección 5, la doctrina moderna ha objetado que la indemnización sea propiamente un cumplimiento por equivalencia. También aquí la ley reconoce a las partes amplia libertad para reglamentar los diversos aspectos de la indemnización, entre otros, el incumplimiento que la genera y los daños que deben resarcirse.

Dos precisiones importantes cierran el análisis del sistema de remedios:

Compatibilidad de las acciones. Las acciones de cumplimiento y de resolución son *incompatibles entre sí*, pero pueden interponerse *sucesivamente*. Por ello no pueden demandarse conjuntamente, a menos que lo sea en forma **subsidiaria**; pero nada obsta a que, ejercida una, se pueda ejercer posteriormente la otra si no se obtuvo (art. 17 del Código de Procedimiento Civil). Si el contratante diligente demanda el cumplimiento y no lo obtiene, mantiene su opción para demandar la resolución. La indemnización de perjuicios, en cambio, sí puede acumularse a cualquiera de las dos.

¿Existe un «derecho principal»? La doctrina tradicional afirma que el cumplimiento forzado sería el *derecho principal* del acreedor, mientras que la resolución y consecuente indemnización compensatoria serían un *derecho secundario*. Se objeta esta nomenclatura porque no considera que, según el artículo 1489, el acreedor puede optar «**a su arbitrio**» entre solicitar el cumplimiento (con indemnización moratoria) o la resolución (con indemnización compensatoria), sin que el Código establezca un orden de prelación entre ambos: muy por el contrario, deja en claro que se trata de un *derecho optativo* del acreedor.

Por otro lado, en su afán de proteger al acreedor, la ley le otorga ciertos derechos destinados a la **conservación del patrimonio del deudor**, en razón de que será en ese patrimonio donde se hará exigible el cumplimiento, en virtud del *derecho de prenda general* del artículo **2465**. Son los de-

rechos auxiliares (beneficio de separación, acción subrogatoria, acción pauliana, medidas conservativas), que se estudian en la Sección 7. Conviene tener presente, por último, que el incumplimiento de las **obligaciones naturales** no produce estos efectos, pues su característica es justamente no otorgar acción para exigir su cumplimiento (art. 1470).

Ejemplo — La opción del art. 1489 en acción

Pedro vende a Juan un departamento por \$120.000.000 y Juan no paga el saldo de precio. Pedro, contratante diligente, puede a su arbitrio: (i) demandar el **cumplimiento** (que Juan pague el precio), con indemnización moratoria por el retardo; o (ii) demandar la **resolución** del contrato (recuperar el departamento), con indemnización compensatoria. No puede pedir ambas a la vez, salvo en forma subsidia-ria; pero si demanda el cumplimiento y no logra que Juan pague, conserva la opción de demandar después la resolución.

1.5. Sistema de atribución: responsabilidad subjetiva y objetivación

La pregunta por el **factor de atribución** de la responsabilidad contractual —esto es, en virtud de qué título se hace responder al deudor— enfrenta hoy dos concepciones.

La **doctrina tradicional** entiende que el factor de atribución es de carácter **subjetivo**: sólo habrá lugar a la responsabilidad en la medida en que se verifique un incumplimiento *imputable a dolo o culpa*. Sin incumplimiento culpable o doloso, no hay responsabilidad contractual.

Sin embargo, doctrina más reciente —con **Baraona y Peñailillo** a la cabeza en nuestro medio— sostiene que el análisis no puede reducirse al incumplimiento imputable. El Código contiene normas que demostrarían que el principal factor de atribución es el **incumplimiento mismo**, aun cuando no sea imputable: verificado el incumplimiento —y no mediando un evento de fuerza mayor—, el deudor igualmente se encuentra obligado a cumplir el contrato. Por tanto, producido el incumplimiento, aunque éste no pueda atribuirse a dolo o culpa del deudor, el acreedor igualmente queda facultado para solicitar el cumplimiento del contrato —o incluso su resolución

—; pero **sin tener derecho a indemnización de perjuicios**, pues ésta sí presupone imputabilidad.

Baraona observa que una comprensión objetiva de la responsabilidad contractual obliga a admitir que, en tanto no sobrevenga la imposibilidad, no hay necesidad de indagar otra fuente de responsabilidad que no sea la misma obligación; y que, concurriendo tal imposibilidad por causa no imputable al deudor, se extingue la obligación, quedando el deudor liberado. En similares términos, **Peñailillo** señala que el fundamento de la responsabilidad es la *obligatoriedad del contrato*, que ahora ha sido infringido: se pide la ejecución de la prestación simplemente porque a eso se obligó el deudor. En tal eventualidad, la culpa no tiene intervención; producido el incumplimiento, no se divisa razón para exigir un requisito adicional más allá del contrato a fin de que el acreedor pueda demandar la prestación convenida —y, por lo demás, no hay norma que lo exija—. Demandada la prestación en especie, al acreedor le bastará demostrar la *existencia de la obligación*, correspondiendo al deudor la prueba del pago o de la extinción por cualquiera de los medios del artículo 1567 (como lo confirman los arts. 438 del CPC y 1672 y 1698 del CC). Mientras la obligación no se extinga, la ejecución forzada es plenamente procedente, y el deudor no puede excepcionarse ofreciendo simplemente la prueba de la diligencia o la ausencia de culpa: ella no está contemplada entre las causas de extinción de la obligación.

Dato de grado — La clave de la objetivación

La tesis objetiva **no elimina la culpa**; la *reubica*. El incumplimiento, por sí solo, habilita el cumplimiento forzado y la resolución (no exigen imputabilidad). La **culpa o el dolo sólo se exigen para la indemnización de perjuicios**. De ahí que pueda haber resolución sin indemnización (incumplimiento fortuito) y que la presunción de culpa del art. 1547 inc. 3.º opere precisamente en el terreno indemnizatorio. Dominar esta distribución —qué remedio exige imputabilidad y cuál no— es decisivo en el examen.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 1 — Marco general de la responsabilidad contractual**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

2. EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL COMO FACTOR DE ATRIBUCIÓN

El primer y elemental presupuesto para que el acreedor pueda ejercer cualquiera de los derechos que el contrato o la ley le otorgan es que exista un **incumplimiento** de la obligación por parte del deudor. El incumplimiento es el factor de atribución de la responsabilidad contractual y el punto de partida de todo el sistema de remedios: sin incumplimiento no hay cumplimiento forzado, ni resolución, ni indemnización que reclamar.

2.1. Concepto y clases de incumplimiento (art. 1556)

Para precisar qué se entiende por incumplimiento conviene partir por su reverso: el **pago**. Pagar es la «prestación de lo que se debe» (art. 1568), y debe hacerse *exactamente*—total y oportunamente, en el lugar convenido y con sujeción a los principios de **identidad** e **integridad**—. Si la obligación es de dar, el deudor debe entregar la cosa misma que se debe; si es de hacer, debe ejecutar el hecho a que se obligó y no otro; si es de no hacer, debe abstenerse de los hechos prohibidos. Hay **incumplimiento**, entonces, cada vez que no se verifica ese pago íntegro y oportuno.

Empleando los términos del artículo 1556, hay incumplimiento en **tres casos**: (i) cuando la obligación *no se cumple*; (ii) cuando la obligación *se cumple imperfectamente*; o (iii) cuando se *retarda* el cumplimiento de la obligación. Dicho de otra manera: cuando se falta íntegramente al pago, o se infringe alguno de sus requisitos. Cada vez que no se verifica un pago íntegro y oportuno se está en presencia de un incumplimiento, que en rigor es un **concepto de carácter objetivo**. El hecho de que tal incumplimiento obedezca a un obrar doloso o negligente del deudor otorgará al acreedor el derecho a pedir—además del cumplimiento o la resolución—

la indemnización de perjuicios, si la infracción efectivamente causó un daño (o bien se estipuló al efecto una cláusula penal).

El incumplimiento puede ser **total** o **parcial**. Es *total* si no se ejecuta la obligación en ninguna de sus partes. Es *parcial* en los dos últimos casos del artículo 1556: **(i)** si la obligación se cumple imperfectamente, o sea, no se paga en forma íntegra —como si, de una deuda de \$10.000, el acreedor acepta un abono de \$5.000; si se paga la deuda pero no los intereses; o si el edificio entregado tenía defectos de construcción—; y **(ii)** cuando existe retardo en el cumplimiento, es decir, la obligación no se ha cumplido en su oportunidad. Conviene subrayar una consecuencia técnica del cumplimiento imperfecto: el acreedor **debe haber aceptado** ese cumplimiento incompleto, porque no está obligado a recibir un pago que no sea íntegro (art. 1591); si rechaza el cumplimiento incompleto, habrá lisa y llanamente *incumplimiento total*.

Ejemplo — Las tres formas de incumplir

De una obligación de \$10.000.000 por la construcción de una casa: si el constructor **no construye nada**, hay incumplimiento *total*; si construye pero el edificio presenta **defectos de construcción**, hay cumplimiento *imperfecto* (incumplimiento parcial); si la entrega **tres meses después** del plazo pactado, hay *retardo*. En los tres casos el acreedor puede recurrir a los remedios del art. 1489; pero sólo en el segundo y el tercero, si acepta el pago tardío o imperfecto, la deuda subsiste reducida o se añade la indemnización moratoria.

2.2. Casos en que el incumplimiento no da lugar a responsabilidad

No necesariamente cada vez que se verifica un incumplimiento hay lugar a la responsabilidad contractual. En efecto, puede suceder que:

- **(a) Acuerdo con el acreedor.** El deudor deja de cumplir por un acuerdo con el acreedor, esto es, aceptando éste el incumplimiento, por lo cual no hay responsabilidad ulterior para el deudor; así ocurre si opera una *remisión*, una *transacción* o una *novación* —aunque esta última, en rigor, equivale al cumplimiento, pues sustituye la obligación primitiva por una nueva—.

- **(b) Incumplimiento recíproco del acreedor.** El deudor no cumple, pero se justifica en que, a su turno, el acreedor tampoco ha cumplido alguna obligación suya; así ocurre con la *excepción de contrato no cumplido* (art. 1552), que se analiza más adelante (§4.8).
- **(c) Modo de extinguir liberatorio.** El deudor deja de cumplir porque ha operado algún modo de extinguir liberatorio para él, ya sea que destruyó el vínculo jurídico o puso término a la obligación nacida de él: *prescripción, nulidad, etc.*
- **(d) Causal de exención de responsabilidad.** Puede concurrir alguna causal de exclusión de responsabilidad (Sección 6). La principal es el **caso fortuito o fuerza mayor**: en tal caso la obligación se extinguirá sin ulterior responsabilidad para el deudor, o bien éste la cumplirá una vez eliminado el obstáculo, pero sin responder por el retardo.

De lo anterior se sigue una idea de método que conviene retener: el incumplimiento (objetivo) es *necesario* pero no siempre *suficiente* para gatillar todos los remedios. Habilita siempre el cumplimiento forzado y la resolución; pero la indemnización exige, además, imputabilidad y daño, y todos los remedios pueden verse neutralizados por las defensas y causales recién enunciadas.

2.3. Obligaciones de medio y de resultado

Para analizar el incumplimiento de un contrato y, particularmente, las eventuales causales de exención de responsabilidad, adquiere relevancia la distinción doctrinal entre **obligaciones de medio** y **obligaciones de resultado**. Son *obligaciones de medio* aquellas en que el deudor se compromete únicamente a realizar todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia, para alcanzar un resultado determinado, **sin garantizarlo** (el abogado que litiga, el médico que trata). Son *obligaciones de resultado* aquellas en que el deudor, para cumplir, debe **alcanzar el resultado propuesto** (el transportista que debe entregar la mercadería en destino; el constructor que debe entregar la obra terminada).

La relevancia práctica de la distinción radica en su incidencia sobre el incumplimiento y la exención. En las obligaciones de medio, la diligencia cumple una **función integradora de la prestación** —como acontece en las labores que desarrolla un abogado en el juicio—, de modo que si, no obs-

tante haberse obrado con la debida diligencia, no se alcanza el resultado deseado —ganar el juicio—, *no se configura responsabilidad*. De ahí que se afirme que, respecto de estas obligaciones, la **ausencia de culpa configura una causal de exención**. En las obligaciones de resultado ocurre lo contrario: para determinar el incumplimiento —y la consecuente responsabilidad— la culpa no es un elemento a considerar; el deudor únicamente se exonera acreditando la existencia de un evento de **fuerza mayor** que le imposibilitó ejecutar la obligación debida, sin que sea procedente invocar la mera ausencia de culpa como causal de exención.

Atención — La clasificación es debatida

No existe consenso doctrinal sobre esta distinción. *Primero*, mientras algunos autores hacen depender el carácter de la obligación de la descripción contenida en la ley o el contrato, otros sostienen que en rigor **todas** las obligaciones son de medio (con lo que siempre cabría alegar la ausencia de culpa como exoneración); y, en el extremo opuesto, hay quienes afirman que toda obligación es de resultado. *Segundo*, entre quienes admiten la clasificación, unos sostienen que sólo puede predicarse de las obligaciones de **hacer**, mientras otros la extienden a las de **dar** e incluso a las de **no hacer**. La utilidad de la distinción es, sobre todo, *probatoria y de exención*: define qué debe acreditar el deudor para liberarse.

2.4. Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad

De acuerdo con el artículo **1698**, incumbe probar la obligación o su extinción al que alega una u otra. La aplicación de esta regla al incumplimiento arroja una distribución de cargas decisiva. Si al acreedor le corresponde acreditar la **existencia** de la obligación, no le toca, en cambio, probar el **incumplimiento**: es el *deudor* quien debe establecer que ha cumplido, porque alega el pago —o sea, la extinción de la obligación—, y la ley coloca sobre él la carga de la prueba en tal caso.

Pero aún más: si el deudor no ha cumplido, deberá probar —si quiere quedar exento de responsabilidad— que el incumplimiento **no le es imputable**. El deudor se defenderá de la demanda alegando que ha operado algún

modo extintivo liberatorio para él; según la regla general del artículo 1698, deberá probarlo. Y si lo que alega es la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito, debe acreditar la concurrencia de la fuerza mayor. Así resulta no sólo de la regla del 1698, sino que lo dispone expresamente el inciso 3.º del artículo **1547**: «*La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega*».

La conclusión es de la mayor importancia: si debe probar la diligencia quien debió emplearla, **ello equivale a presumir la culpa**. Sobre el deudor pesa, por tanto, una *presunción legal de imputabilidad* que él debe destruir, acreditando que empleó la debida diligencia o que el incumplimiento se debió a un caso fortuito.

Dato de grado — La presunción de culpa contractual

Ésta es una de las grandes diferencias con la responsabilidad extracontractual. En sede **contractual**, acreditada la obligación y el incumplimiento, **la culpa del deudor se presume** (art. 1547 inc. 3.º): el acreedor no debe probarla; es el deudor quien debe probar su diligencia o el caso fortuito. En sede **extracontractual**, la regla general es la inversa: la culpa del autor debe ser *probada* por la víctima (salvo las presunciones de los arts. 2320 y ss.). Esta inversión de la carga probatoria es, históricamente, una de las principales ventajas de demandar por la vía contractual.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 2 — El incumplimiento contractual**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

3. LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

3.1. Nociones generales y concepto

El derecho del acreedor a exigir el pago de la obligación y el cumplimiento del contrato es una cuestión evidente, connatural a la noción misma de obligación jurídica: las obligaciones se asumen *para ser cumplidas*, por lo que su infracción lógicamente otorga al acreedor el derecho a exigir su cumplimiento o pago. Precisamente por ello, conforme al artículo **1489**, ante el evento de un incumplimiento el acreedor tiene el derecho de instar por el cumplimiento. Como nadie puede hacerse justicia por su propia mano, el acreedor debe recurrir al juez para reclamar el cumplimiento, de modo que el deudor sea compelido por la autoridad de la justicia a pagar lo que debe.

Llamativamente —y salvo excepciones—, la doctrina nacional no había desarrollado mayormente el estudio de la acción de cumplimiento, limitándose en general a analizar el «cumplimiento forzado» y a distinguir entre obligaciones de dar, hacer (art. 1553) y no hacer (art. 1555), junto con los requisitos para iniciar un juicio ejecutivo —materia mayormente regulada en el Código de Procedimiento Civil—. La materia, sin embargo, es más amplia: comprende desde el objeto mismo de la acción hasta los requisitos de procedencia y la cuestión de si es o no necesario que el incumplimiento sea imputable. En lo que sigue se recogen los aportes recientes de **Cárdenas y Reveco**, que han ampliado el análisis.

Puede definirse la **acción de cumplimiento** como aquella de que dispone el acreedor insatisfecho, una vez acontecido el incumplimiento, para que se declare la existencia y exigibilidad de una obligación y se condene al deudor a su pago. En términos simples, es la acción destinada a obtener directamente que el deudor sea condenado al cumplimiento de la obligación. Se la denomina también **acción de cumplimiento específico**, en cuanto su función es obtener forzosamente el pago, esto es, la prestación de lo que se debe.

3.2. ¿Es el «derecho principal» del acreedor?

La doctrina tradicional afirma habitualmente que el cumplimiento específico es el **derecho principal** del acreedor frente al incumplimiento, concediéndole un lugar preponderante entre las diversas acciones de que dispone y haciendo primar el cumplimiento en naturaleza sobre las demás. Así, **Claro Solar** sostuvo que la ley permite al acreedor *«adoptar la determinación que más le convenga en el momento en que se realiza la condición resolutoria; pero lógicamente, y en la generalidad de los casos naturalmente también, no se ha de recurrir a la resolución cuando la ejecución del contrato es aún posible; pues los contratos se hacen para cumplirlos, no para resolverlos»*.

En el derecho comparado, esta primacía se ha fundado en argumentos adicionales. Desde un punto de vista *ético*, se sostiene que el reconocimiento de la acción de cumplimiento es disuasivo del incumplimiento e incentiva el comportamiento de buena fe de los contratantes. Desde un punto de vista *económico y social*, es el remedio que mayor seguridad jurídica confiere al tráfico, reforzando la certeza del contrato y protegiendo la confianza depositada.

Con todo, la primacía ha sido **cuestionada** por un sector de la doctrina contemporánea, que considera que el acreedor insatisfecho cuenta con una *batería de acciones* que le permiten remediar su situación según su interés específico. Esta postura encuentra asidero normativo: el artículo 1489, lejos de distinguir entre derechos «principales» y «secundarios», expresamente indica que ante el incumplimiento el acreedor tiene la opción de pedir el cumplimiento o la resolución, en uno u otro caso con indemnización de perjuicios. Tal opción la ejerce el acreedor **«a su arbitrio»**, sin tener que justificar su decisión, y sin que proceda cotejar las consecuencias de la alternativa elegida con las de la abandonada para deducir alguna limitación.

3.3. Objeto: cumplimiento en naturaleza y por equivalencia

El primer —y primordial— objeto de la acción es el **cumplimiento en naturaleza**, en especie o *in natura*: lo que se pide es propiamente el pago, la «prestación de lo que se debe», sea un dar, hacer o no hacer. Sobre esto no hay duda. La controversia recae en si también es objeto de esta acción

el **valor o precio de lo adeudado** (*aestimatio rei*), esto es, el «cumplimiento por equivalencia».

Tradicionalmente, la doctrina nacional identificó el «cumplimiento por equivalencia» con la *indemnización de perjuicios*, tratándolos como sinónimos. Doctrina más reciente objeta esa identificación. **Peñailillo** distingue ambas figuras: el *cumplimiento por equivalencia* tiene lugar cuando, estando vigente la obligación, ya no es posible (o útil) el cumplimiento específico; en esta alternativa la obligación **subsiste pero varía de objeto**, y el deudor es obligado a pagar el «precio» o valor de la prestación incumplida. La *indemnización de perjuicios* (o daños ulteriores), en cambio, ya no persigue el valor de la prestación, sino resarcir los perjuicios que, más allá de la cosa o prestación no ejecutada, se causaron al acreedor por el incumplimiento.

Baraona agrega que, si se revisa el contenido de los daños y perjuicios a que puede ser condenado el deudor, se advierte que no necesariamente coinciden con el valor de la prestación: el artículo **1556** comprende el *daño emergente* y el *lucro cesante*, y por mucho que se quiera hacer coincidir el daño emergente con el valor de la prestación, el lucro cesante no puede reconducirse a esa idea. La distinción permite separar dos conceptos básicos: lo que se debe *porque se obligó* (el valor económico de la obligación) y lo que se debe *ex novo*, porque se ha causado daño con ocasión del cumplimiento o incumplimiento (los daños propiamente obligacionales).

Una serie de normas del Código distinguen claramente el valor o precio de la cosa de la indemnización de perjuicios:

- El artículo **1672**, sobre la pérdida de la cosa debida, señala que si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste pero varía de objeto (*perpetuatio obligationis*), y «el deudor es obligado **al precio de la cosa y a indemnizar** al acreedor».
- El artículo **1486** inc. 1.º dispone que si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece por culpa del deudor, éste es obligado «**al precio, y a la indemnización de perjuicios**».

- Aún más elocuente, el artículo **1521**, en sede de solidaridad, prescribe que si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los codeudores solidarios, «todos ellos quedan obligados solidariamente **al precio** [...] Pero la **acción de perjuicios** a que diere lugar la culpa o mora no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso».

El propio Código de Procedimiento Civil asimila ambas clases de cumplimiento: su artículo **438** señala que la ejecución puede recaer «1.º Sobre la *especie o cuerpo cierto* que se deba y que exista en poder del deudor; 2.º Sobre el *valor* de la especie debida y que no exista en poder del deudor». La relevancia de entender que el cumplimiento por equivalencia es propiamente *cumplimiento* —y no indemnización— es enorme: para su procedencia **no se requiere dolo o culpa del deudor**, sino que basta que objetivamente la obligación se haya incumplido. Como dice Peñailillo, el régimen del cumplimiento por equivalencia es el mismo del cumplimiento en especie: se trata de que el deudor pague lo que la prestación «vale».

Dato de grado — Aestimatio rei ≠ indemnización

Pregunta fina de cédula. El **valor de la prestación** (*aestimatio rei*) es *cumplimiento por equivalencia*: se debe porque la obligación subsiste y varió de objeto; no exige culpa, basta el incumplimiento (arts. 1672, 1486, 1521, 438 CPC). La **indemnización de perjuicios** repara los daños ulteriores (daño emergente, lucro cesante, daño moral); exige imputabilidad. Sostener la distinción permite cobrar el valor de lo debido aunque el incumplimiento sea fortuito, reservando la culpa para los daños adicionales.

3.4. Presupuestos de procedencia

Los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento son fundamentalmente **dos**: que exista una *obligación exigible* y que la misma se haya *incumplido*. Para que la acción prospere **no hay que acreditar daño**, ni necesariamente culpa o dolo, pudiendo realizarse la imputación en forma objetiva. Atendido el tenor del artículo 1698, basta con que el acreedor acredite la *existencia* de la obligación, teniendo el deudor la carga de pro-

bar su extinción —ya sea por pago (cumplimiento) o por otro modo—. En cuanto a la exigibilidad, como la regla general es que la obligación sea pura y simple, bastará la prueba de su existencia, presumiéndose —salvo pacto expreso o prueba en contrario— que es actualmente exigible.

3.5. Cumplimiento y ejecución forzada de obligaciones de dar, hacer y no hacer

La satisfacción plena de la acción de cumplimiento implica **dos fases**: una *declarativa*, en que se discute la existencia y exigibilidad de la obligación, y otra de *ejecución*, que presupone una obligación indubitada y a cuyo cumplimiento se compele incluso por la fuerza. El acreedor dispone de la acción de cumplimiento *aun cuando no tenga título ejecutivo*: en tal caso deberá iniciar un juicio de lato conocimiento y la sentencia favorable firme constituirá el título ejecutivo con base en el cual hará efectivo su crédito. El Código de Procedimiento Civil regula los **juicios ejecutivos**, procedimiento más expedito que requiere un *título ejecutivo* —documento que deja constancia indubitada de la obligación—; si el acreedor carece de él y no lo obtiene mediante *gestiones preparatorias de la vía ejecutiva* (reconocimiento de firma, confesión de deuda), sólo le queda el juicio ordinario.

Lo que se exige forzosamente no es de una misma naturaleza, pues depende del tipo de obligación. Hay que distinguir.

(a) Cumplimiento forzado de las obligaciones de dar

Si la obligación es de pagar una suma de dinero —lo más corriente—, el acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero, o sobre los bienes del deudor para realizarlos y pagarse con el producto. Si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto que está en poder del deudor, la ejecución se dirigirá a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si ello no es posible. El procedimiento ejecutivo está en el Título I del Libro III del CPC (arts. 434 a 530). Entablada la demanda ejecutiva, el juez examina el título y despacha *mandamiento de ejecución y embargo*, tramitándose la causa hasta subastar bienes suficientes; el remate de muebles se efectúa por un martillero en pública subasta, y el de inmuebles, en pública subasta ante el tribunal, pagándose luego al acreedor

conforme al artículo 2469. Para que proceda la ejecución forzada de una obligación de dar se requiere, en síntesis:

- **(i) Título ejecutivo.** Documento al que la ley atribuye mérito ejecutivo (idoneidad para exigir el cumplimiento forzado). Los principales se enumeran en el artículo **434** del CPC (sentencias, escrituras públicas, etc.). El carácter ejecutivo lo da la *ley*: las partes no pueden conferírsele a un título que ella no reconoce.
- **(ii) Obligación actualmente exigible.** Al momento de interponer la acción, la obligación no debe estar sujeta a plazo ni condición pendiente que suspenda su exigibilidad.
- **(iii) Obligación líquida** o liquidable mediante simples operaciones aritméticas con los solos datos del título.
- **(iv) Acción ejecutiva no prescrita.** La acción ejecutiva prescribe en **tres años**; cumplidos, se convierte en ordinaria y dura otros dos (art. **2515**).

(b) Cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer

El cumplimiento forzado de una obligación de hacer presenta más dificultades, pues es difícil obligar a un deudor a que realice satisfactoriamente el hecho debido; sólo será posible tratándose de hechos que puedan ser ejecutados por otra persona. Por ello, el artículo **1553** dispone que, constituido el deudor en mora, el acreedor podrá pedir —junto con la indemnización moratoria— cualquiera de estas **tres cosas a su elección**:

- **1.º Que se apremie al deudor** para la ejecución del hecho convenido. El apremio consiste en arresto hasta por 15 días y multa proporcional, medidas que podrán repetirse hasta que la obligación se cumpla (art. 543 del CPC). Es uno de los casos en que subsiste excepcionalmente la prisión por deudas, compatible con el Pacto de San José de Costa Rica.
- **2.º Que se le autorice para hacer ejecutar el hecho por un tercero a expensas del deudor.** Este «cumplimiento por equivalencia» no siempre es posible: sólo lo será cuando la obligación sea susceptible de ejecutarse por otra persona, sin que resulten decisivas las condiciones personales del deudor (obligación *fungible*, no *intuitu personae*).

- **3.º Que el deudor le indemnice** los perjuicios resultantes de la infracción. A diferencia de los dos anteriores, este derecho no puede ejercitarse ejecutivamente, sino en juicio ordinario, pues es necesario determinar y avaluar la extensión del derecho del acreedor (salvo que se haya estipulado cláusula penal en título ejecutivo, caso en que la indemnización es líquida).

El procedimiento (Título II del Libro III del CPC, arts. 530 a 544) varía según el hecho debido consista en (i) la suscripción de un documento, (ii) la constitución de una obligación, o (iii) la ejecución de cualquier otro hecho material. Si se trata de suscribir un documento o constituir una obligación, el juez requiere al deudor para que lo haga en el plazo señalado, **bajo apercibimiento de hacerlo el juez a su nombre** (art. 532 CPC; típico caso de la promesa de celebrar contrato). Si el objeto es la ejecución de una obra material, el mandamiento ejecutivo contendrá la orden de requerir al deudor y la fijación de un plazo prudente para iniciar los trabajos (art. 533 CPC); si el deudor no ejecuta o abandona la obra, el acreedor puede solicitar autorización para llevarla a cabo por un tercero a expensas del deudor (art. 536 CPC), presentando un presupuesto que el demandado puede aceptar u objetar (art. 537), debiendo el deudor consignar su monto (art. 538) y, si no consigna, procediéndose a embargarle y enajenar bienes suficientes (art. 541).

(c) Cumplimiento forzado de las obligaciones de no hacer

La obligación de no hacer se infringe cuando se hace lo que no debió hacerse. La materia se regula en el artículo 1555. Para determinar lo que el acreedor puede pedir, hay que distinguir si es o no posible destruir lo hecho y, si lo es, si tal destrucción es o no necesaria:

- **1.º Si lo hecho puede destruirse y la destrucción es necesaria** para el objeto que se tuvo en mira al contratar (art. 1555 inc. 2.º): el acreedor tiene derecho a pedir la destrucción de la obra y a que se le autorice para hacerla destruir por un tercero a expensas del deudor. Como observa Abeliuk, si el deudor no se allana, la obligación de no hacer se ha transformado, por su infracción, en una de hacer —*deshacer lo hecho*—, por lo que el artículo 544 del CPC hace aplicables las normas de la ejecución de las obligaciones de hacer.

- **2.º Si la destrucción no es de absoluta necesidad** y el mismo fin puede obtenerse por otros medios (art. 1555 inc. 3.º): el deudor podrá cumplir su obligación por un modo equivalente, y será oído el deudor que se allane a prestarlo.
- **3.º Si no es posible destruir o deshacer lo hecho:** no le queda al acreedor más remedio que pedir la indemnización de perjuicios (art. 1555 inc. 1.º). Es el caso del artista contratado para presentarse exclusivamente en cierto teatro que actúa en otro, o del ex trabajador que, pagado para no prestar servicios a la competencia, igualmente los presta: como es imposible deshacer lo hecho, sólo cabe la indemnización.

El inciso final del artículo 1555 agrega que **«el acreedor quedará de todos modos indemne»**: cualquiera sea la solución que se dé a la infracción, el acreedor ha de quedar libre de daño; aun obteniendo la destrucción o la prestación equivalente, podrá reclamar además los perjuicios moratorios que el incumplimiento le hubiere causado.

Ejemplo — Tres deudores que no cumplen

Dar: A debe entregar un automóvil individualizado y consta la deuda en escritura pública; el acreedor, con ese título ejecutivo, demanda ejecutivamente, embarga y obtiene la entrega o su valor. **Hacer:** B, maestro, se obligó a pintar la fachada y no lo hace; el acreedor pide que se le autorice a contratar a otro pintor a expensas de B (art. 1553 N.º 2), presenta presupuesto y, si B no consigna, le embarga bienes (art. 541 CPC). **No hacer:** C se obligó a no levantar un muro que tapa la vista y lo construye; si el muro frustra el fin del contrato, el acreedor pide que se demuela a expensas de C (art. 1555 inc. 2.º), aplicándose por remisión (art. 544 CPC) las reglas del hacer.

3.6. Límites a la acción de cumplimiento: la imposibilidad

El gran límite de la acción de cumplimiento en naturaleza es la **imposibilidad** de la prestación, física o jurídica: a lo imposible nadie está obligado. La *imposibilidad física* atiende a la naturaleza del objeto —una especie o cuerpo cierto que se destruye o pierde—; la *imposibilidad jurídica* se refiere a una norma que prohíbe cumplir, o a una orden de autoridad compe-

tente (resolución judicial o decreto administrativo). La imposibilidad admite además otras clasificaciones, según el momento, la extensión y la duración:

- **Originaria o sobrevenida:** según exista ya al momento de contratar o sobrevenga después de nacida la obligación.
- **Absoluta o relativa:** según la prestación sea imposible total o sólo parcialmente.
- **Definitiva o transitoria:** según el impedimento sea permanente o sólo temporal.

En Chile, para que la imposibilidad **extinga** las obligaciones debe ser física o jurídica, *sobrevenida*, *absoluta* y *definitiva*. Las demás hipótesis reciben otro tratamiento: si la imposibilidad es *originaria*, se configura una hipótesis de **falta de objeto** conforme al artículo **1461** (la obligación no llegó a nacer válidamente); si es *relativa*, la obligación debe cumplirse en los términos en que sea posible —salvo que, tratándose de especie o cuerpo cierto, la imposibilidad relativa consista en la destrucción de la aptitud de la cosa para su finalidad, pues entonces se entiende absolutamente destruida (art. 1486 inc. final)—; y si es *transitoria*, sólo permite al deudor suspender la ejecución mientras subsista el impedimento, salvo que la prestación debiera ejecutarse dentro de un plazo y el impedimento subsista hasta su expiración, caso en que la imposibilidad se entiende definitiva.

Cuando la imposibilidad está sustentada en un **caso fortuito o fuerza mayor**, se configura el modo de extinguir «**pérdida de la cosa debida**» (arts. **1670** y siguientes). Si bien estas normas se aplican literalmente sólo a las obligaciones de especie o cuerpo cierto, trasuntan el principio general de que nadie está obligado a lo imposible; de ahí que, tratándose de obligaciones de hacer o no hacer, aun cuando no exista norma expresa, la imposibilidad también opere como modo de extinguir. Ahora bien, el efecto liberatorio sólo es pleno si la pérdida es *fortuita*: si la cosa perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste y varía de objeto, debiendo el deudor el precio de la cosa y la indemnización (art. 1672), según se vio.

Dato de grado — Imposibilidad ≠ exención automática

Que la prestación en naturaleza sea imposible no significa que el deudor quede sin responsabilidad. Sólo la imposibilidad **fortuita** extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad es *imputable* (culpa o mora), la obligación subsiste bajo la forma del valor de la cosa más indemnización (art. 1672). Por eso es decisiva la presunción de culpa del art. 1547 inc. 3.º: probada la pérdida, el deudor debe acreditar que fue fortuita para liberarse.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 3 — La acción de cumplimiento**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

4. LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Una segunda acción o «remedio» que se confiere al acreedor frente al incumplimiento consiste en el derecho a solicitar la **resolución del contrato incumplido**. Tal derecho es otorgado directamente por la ley en virtud de la denominada *condición resolutoria tácita*, que es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral para el evento de no cumplirse lo convenido; o bien puede ser ejercido en base a una estipulación contractual denominada *pacto comisorio*, que, en términos simples, no es más que la condición resolutoria tácita expresada. Mientras la acción de cumplimiento que se estudió en la sección anterior persigue la subsistencia del contrato y la satisfacción de la prestación en naturaleza, la resolución apunta en la dirección opuesta: extinguir el vínculo, liberar al acreedor de su propia obligación y, en su caso, recuperar lo que hubiere prestado. Ambos remedios comparten un mismo presupuesto —el incumplimiento— pero conducen a resultados antagónicos, y de ahí que el artículo **1489** los configure como una opción a favor del contratante cumplidor.

4.1. Generalidades y nomenclatura

Tradicionalmente, y fundamentalmente a raíz de la ubicación del artículo **1489** en el título de las obligaciones condicionales (Título IV del Libro IV), la doctrina ha analizado los efectos de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio a propósito del estudio de la condición resolutoria general. Con todo, más allá de su ubicación sistemática, lo cierto es que el artículo 1489 es la principal norma que establece los derechos del acreedor ante el incumplimiento; por ello, como apunta **Boetsch**, resulta más adecuado analizarlo a propósito de la responsabilidad contractual, particularmente si se adopta una noción amplia de ésta, no limitada a la indemnización de perjuicios, sino comprensiva de toda la reacción del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento del contrato.

La norma dispone: *«En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios»*. Inspirada en el artículo 1184 del *Code* francés, regula lo que la doctrina tradicional denomina la «condición resolutoria tácita», entendida como el hecho futuro e incierto consistente en el incumplimiento de alguna de las obligaciones generadas por un contrato bilateral.

Sin embargo, la **doctrina moderna** y la gran mayoría de los Códigos Civiles del siglo XX han abandonado tal nomenclatura y concepción. Se sostiene que, más que una condición propiamente tal, se trata de un *remedio frente a una infracción del contrato*: la resolución por incumplimiento. En cuanto tal, el artículo 1489 no debería encontrarse en el título sobre las condiciones, sino en el Título XII del Libro IV, correspondiente a los efectos de las obligaciones. En otras palabras, no sería correcto hablar de «condición resolutoria tácita», sino de «resolución por incumplimiento», por cuanto no es acertado considerar la facultad de resolver como una condición, sino como un remedio frente al incumplimiento.

Doctrina — La doble lectura de Peñailillo

Peñailillo apunta con agudeza que el artículo 1489 abarca dos planos: (i) un tema *sustantivo*, como es la resolución del contrato por incumplimiento; y (ii) la *forma* que adopta tal regulación, que es la de una condición tácita. La «forma» elegida por el Código no sería correcta, entre otras razones, porque —a diferencia de las condiciones propiamente tales— la resolución por incumplimiento **no opera de pleno derecho**; y porque, cumplida la supuesta «condición» (esto es, generado el incumplimiento), se otorga al acreedor la *alternativa* de pedir el cumplimiento, nota que también la distingue de las condiciones genuinas, las cuales no confieren opción alguna a su titular.

4.2. La condición resolutoria tácita: concepto y fundamento

Abeliuk define la condición resolutoria tácita como «*aquella que va envuelta en todo contrato bilateral, y en que el hecho futuro e incierto que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes es el incumplimiento de sus obligaciones*». Se funda, agrega, en la falta de cumplimiento del deudor. El incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral da a la otra parte un derecho alternativo para solicitar o el cumplimiento o la resolución, y en ambos casos con indemnización de perjuicios.

En cuanto al **fundamento** de la institución, la doctrina ha ensayado diversas explicaciones —equidad, voluntad presunta de las partes, falta de causa, interdependencia de las prestaciones, modo de reparar el perjuicio— que conviene examinar críticamente:

- **Equidad y justicia.** Es evidente la razón de equidad que hay en que, si una de las partes no cumple su obligación en un contrato bilateral, la otra pueda a su vez desligarse del vínculo, dejando sin efecto el contrato. No sería justo mantener atado al contratante diligente frente a quien desatiende sus compromisos.

- **Voluntad presunta de las partes.** Se dice que el legislador interpreta lo que las partes habrían querido: parece lógico concluir que el contratante diligente no desea seguir ligado con quien no ha cumplido, y que esta intención estuvo presente al otorgarse el contrato.
- **Falta de causa.** Según **Capitant** y sus seguidores, el fundamento estaría en que, incumplida la obligación de una parte, la del otro contratante carecería de causa. Se objeta —con razón— que de faltar la causa el contrato sería *nulo*, y entonces el contratante diligente no podría pedir el cumplimiento; si la ley se lo permite (art. 1489), es porque la obligación *tiene* causa. Como precisan los hermanos **Mazeaud**, el requisito de la causa debe verificarse al momento de celebrarse el contrato, y a ese momento la causa existía, pues ambas partes contrajeron obligaciones recíprocas; el incumplimiento posterior no hace desaparecer la causa.
- **Interdependencia de las prestaciones.** Se ha sostenido que la resolución sería consecuencia de la interdependencia de las obligaciones nacidas del contrato sinalagmático. Los **Mazeaud** objetan que «esta explicación carece de precisión y no da cuenta de las diferencias que separan la resolución y la teoría de los riesgos».
- **Modo de reparación.** Los propios **Mazeaud** concluyen que «en realidad, la resolución judicial es un modo de reparación del perjuicio que causa al acreedor el incumplimiento de la obligación del deudor»: al dispensarle de cumplir su propia obligación, o al permitirle recuperar la prestación efectuada, la resolución se presenta como un modo de reparación de mayor eficacia.

4.3. Características y ámbito de aplicación

Entendida como una *condición*, la resolutoria tácita presenta las siguientes características: **a)** es un tipo de condición *resolutoria*, pues tiene por objeto extinguir una obligación; **b)** es *tácita*, ya que el legislador la subentende en todo contrato bilateral —por ello es un elemento de la naturaleza del contrato y, como tal, *renunciable*—; **c)** es *negativa*, pues consiste en que no ocurra un hecho (que una parte no cumpla); **d)** es *simplemente potestativa*, pues depende de un hecho voluntario del deudor; y **e)** *no opera de pleno derecho*, sino que requiere declaración judicial.

De lo anterior se desprenden las **diferencias con la condición resolutoria ordinaria**: en la tácita el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral, mientras que en la ordinaria es cualquier hecho que no sea ese incumplimiento; la ordinaria opera de pleno derecho y la tácita requiere sentencia; la ordinaria exige una manifestación expresa de voluntad y la tácita la subentiende la ley; y la tácita sólo opera —según la opinión mayoritaria— en los contratos bilaterales, en tanto la ordinaria puede establecerse en cualquier negocio jurídico.

¿Sólo contratos bilaterales?

El artículo 1489 indica expresamente que la condición resolutoria tácita va envuelta «en los contratos bilaterales», motivo por el cual buena parte de la doctrina (**Stitchkin, Alessandri, Abeliuk**) estima que la resolución por incumplimiento sólo opera respecto de tal clase de contratos, al punto de erigir la bilateralidad en requisito de procedencia. La cuestión, sin embargo, no es pacífica. **Claro Solar** sostuvo que también opera en los contratos unilaterales, con dos argumentos: **(a)** el artículo 1489 dice que la condición va envuelta en los bilaterales, pero no *excluye* que pueda darse en los unilaterales; y **(b)** diversas disposiciones demuestran que el Código no entendió restringida la institución a los bilaterales —así, en el comodato (contrato unilateral) se faculta al comodante para pedir la restitución anticipada cuando el comodatario no destina la cosa al uso convenido (art. **2177**); en la renta vitalicia la ley debió señalar *expresamente* que el acreedor no podrá pedir la resolución por falta de pago de la pensión (art. **2271**); y en la prenda el deudor puede pedir la restitución inmediata si el acreedor abusa de la cosa (art. **2396**)—.

La tesis de Claro Solar no ha tenido mayor acogida. Se le replica: **(a)** el tenor literal del artículo 1489 habla de «contratos bilaterales»; **(b)** tratándose de los unilaterales, el Código fue resolviendo caso a caso qué ocurre ante el incumplimiento (precisamente los arts. 2177, 2271 y 2396), guardando en cambio silencio respecto del mutuo, que es donde el problema se ha discutido; y **(c)** el fundamento de la institución radicaría, según algunos, en la interdependencia de las prestaciones, que sólo se da en los bilaterales. La jurisprudencia se ha inclinado definitivamente por la procedencia exclusiva en los contratos bilaterales. Resulta interesante, sin embargo, la posición del profesor **Vial**: la falta de norma específica debe suplirse por los principios generales, y es principio del derecho que el contratante in-

cumplidor —de un contrato unilateral o bilateral— contrae responsabilidad que se hace efectiva mediante indemnización; para poder solicitar la indemnización compensatoria, que reemplaza la obligación incumplida, es indispensable extinguir la obligación infringida, y ese modo de extinción es precisamente la resolución.

La resolución en los contratos de tracto sucesivo

La resolución también opera en los contratos de tracto sucesivo, pero pasa a llamarse **terminación**, porque sus efectos no operan retroactivamente, sino sólo para el futuro, en razón de que las prestaciones ya ejecutadas no pueden devolverse. Así, en un arrendamiento a dos años plazo, si el arrendatario paga las rentas de los primeros seis meses pero deja luego de cumplir, el contrato puede darse por terminado, mas el arrendador no deberá restituir las rentas percibidas, porque mal podría a su vez devolver el uso y goce de la cosa arrendada del que el arrendatario ya disfrutó.

La resolución no tiene lugar en la partición

Es corriente que en una partición se produzcan *alcances* en contra de algún comunero —cuando a un interesado se le adjudican bienes que exceden su cuota y queda debiendo el saldo—. ¿Puede pedirse la resolución de la partición si no se pagan esos alcances? La respuesta es negativa, y así lo afirma unánimemente la doctrina (**Somarriva, Claro Solar, Abeliuk**) y la jurisprudencia, por las siguientes razones: **(a)** la partición, aunque participe de ciertos caracteres del contrato, no lo es, y menos uno bilateral; **(b)** se opone a ello el efecto *declarativo* de la partición (art. **1344**), que supone que lo adjudicado a cada comunero deriva directamente del causante y no del acto particional; **(c)** el artículo 1489 es doblemente excepcional —establece una modalidad, y además tácita—, por lo que debe interpretarse restrictivamente y sólo para el caso regulado; y **(d)** el artículo **1348** hace aplicables a la partición la nulidad y la rescisión, pero nada dice de la resolución, lo que revela la intención de excluirla.

4.4. El incumplimiento resolutorio

La doctrina nacional tradicional afirma que los requisitos para que opere la condición resolutoria tácita son cuatro: **(1)** que se trate de un contrato bilateral; **(2)** incumplimiento de una de las partes; **(3)** que quien la invoca haya a su vez cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación; y **(4)** que sea declarada judicialmente. Pero, como ya se vio y como se verá, tanto el primer requisito (exclusividad de los bilaterales) como el tercero (necesidad de no estar en mora) son discutidos. Por ello conviene analizar separadamente el que es el *presupuesto fundamental* de la acción: la existencia de un **incumplimiento resolutorio**. El artículo 1489 sitúa el hecho condicional en «no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado»: el incumplimiento es el hecho que abre la opción (el comprador que no paga el precio, el vendedor que no entrega la cosa, el promitente que se niega a suscribir la escritura definitiva, etc.). Varios puntos requieren desarrollo.

a) ¿Es necesario que el incumplimiento sea imputable a dolo o culpa?

La doctrina tradicional y mayoritaria (**Claro Solar, Alessandri, Somarriva**) sostiene que el incumplimiento debe ser *imputable* al deudor —debido a su dolo o culpa— sobre la base de tres argumentos: **(a)** el propio artículo 1489 establece que, producido el incumplimiento, la otra parte puede pedir el cumplimiento o la resolución «con indemnización de perjuicios», y uno de los requisitos de la indemnización es el dolo o la culpa (lo reiteran, en la compraventa, los arts. **1826** y **1873**); **(b)** si el incumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor no hay lugar a resolución, porque la obligación se habrá extinguido por otro modo —la imposibilidad sobrevenida, que el Código reglamenta como pérdida de la cosa debida—; y **(c)** el artículo **1546** ordena cumplir los contratos de buena fe, de donde se sigue que si el deudor no pudo cumplir por un hecho ajeno a su voluntad, sería contrario a la equidad sancionarlo con la resolución.

Doctrina moderna — El incumplimiento objetivo (Mejías)

Frente a la posición mayoritaria, una postura reciente —que construye sobre el concepto de pago de los arts. 1568 y 1569— elabora una noción **objetiva** de incumplimiento, que prescinde del dolo o culpa del deudor. **Mejías** lo define como «toda desviación del programa de prestación idealmente convenido que conlleve una desarmonía con el interés que las partes se propusieron satisfacer al momento de la celebración del contrato». En esta tesis, si el incumplimiento no es imputable, el acreedor sólo podrá pedir la resolución, *sin* indemnización. Como el artículo 1489 no define qué es un incumplimiento resolutorio, la postura lo construye con tres criterios: (i) la *voluntad* explícita o implícita de las partes, que pueden señalar de antemano en qué casos el incumplimiento será resolutorio; (ii) a falta de estipulación, que el incumplimiento sea de tal incidencia que *altere el sentido práctico* perseguido con el contrato —lo que ocurre en la imposibilidad material o jurídica de la prestación, la privación sustancial del beneficio esperado, la entrega de cosa distinta a la convenida, o la prestación tardía que ya no reporta utilidad—; y (iii) la *pérdida de confianza* del acreedor ante la conducta del deudor (dolo o culpa grave, reticencia al cumplimiento, infracción de obligaciones propias de contratos *intuitu personae*).

b) ¿Procede la resolución si el incumplimiento es parcial?

En general se admite la resolución aun tratándose de un incumplimiento parcial —por no cumplirse una de varias obligaciones, o por el cumplimiento imperfecto de una de ellas—, pudiendo pedirse en tal caso una *resolución parcial* del contrato. Así lo permite expresamente el artículo 1875 inciso 2.º, y en este punto hay prácticamente unanimidad doctrinal y jurisprudencial (**Somarriva, Abeliuk**). **Vial** precisa, no obstante, que la resolución parcial no es posible cuando la obligación infringida constituye un efecto *esencial* del contrato, o cuando —sin serlo— la consideración de su existencia fue el motivo determinante para contratar, de modo que, si falta, el contrato pierde su razón de ser; o cuando las cláusulas están de tal modo engarzadas que se sirven unas de sustento a las otras.

c) ¿Procede la resolución por incumplimientos intrascendentes?

Cuestión distinta es si *cualquier* incumplimiento, por inocuo o insignificante que sea, basta para demandar la resolución, o si se requiere un incumplimiento **grave**. Parte de la doctrina tradicional (**Alessandri, Somarriva, Meza Barros**) afirma que, al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento sería suficiente. El primero en sostener lo contrario fue **Claro Solar**, quien —fundado en la equidad— estimó que el incumplimiento de una obligación secundaria no basta para resolver. Lo han seguido otros; **Abeliuk** razona que no puede dejarse sin efecto un contrato por minucias, y que la resolución, por su esencia, deriva de la infracción de las obligaciones recíprocas que constituyen la bilateralidad del contrato (el precio y la cosa en la venta, la renta y el goce en el arrendamiento). Esta última postura parece la más acertada: resolver por una insignificancia atentaría contra la equidad, faltaría el interés del acreedor en demandar, habría abuso del derecho y se contravendría la buena fe. Para identificar qué obligaciones son *principales* y cuáles *secundarias* resultará imprescindible interpretar la convención conforme a las reglas de los artículos **1560** y siguientes.

JURISPRUDENCIA — CA DE TALCA, 1920 (FALLO CLÁSICO SOBRE INCUMPLIMIENTO DE POCA MONTA)

Un fallo clásico de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió que «*la falta de cumplimiento de las demás obligaciones accesorias [...] no es bastante para determinar la resolución del contrato, por más absolutos que parezcan los términos en que está concebida la disposición del artículo 1489 del Código Civil, dado que tratándose de una materia tradicional como es ésta, que es regida por la equidad antes que por el derecho [...], debe decidirse la resolución o negarse lugar a ella según sean las circunstancias de la causa; circunstancias que, en este caso, inducen a negar lugar a la acción resolutoria en razón de que, habida consideración a la poca o ninguna influencia de esas obligaciones en los fines prácticos del contrato [...], es de presumir que aun sin ellas el comprador lo habría celebrado*». La sentencia es la piedra angular jurisprudencial de la exigencia de un incumplimiento de cierta entidad o gravedad como presupuesto de la resolución.

Dato de grado — Incumplimiento esencial / resolutorio

Si en el examen le preguntan «¿basta cualquier incumplimiento para resolver?», la respuesta correcta articula *texto + doctrina + fallo*: el art. 1489 no distingue (de ahí la tesis amplia de Alessandri), pero la doctrina dominante (Claro Solar, Abeliuk) y la jurisprudencia desde la **CA de Talca de 1920** exigen un incumplimiento **grave o de entidad**, que afecte los fines prácticos del contrato, fundado en la equidad, la buena fe (art. 1546) y la proscripción del abuso del derecho. La doctrina moderna reconduce todo esto a la noción de **incumplimiento esencial** (privación sustancial de aquello que se esperaba del contrato).

4.5. Necesidad de ejercicio de la acción y de sentencia judicial

La existencia de un incumplimiento resolutorio es presupuesto *necesario*, pero no *suficiente*: además resulta indispensable que se ejerza la acción resolutoria en juicio y que se pronuncie una sentencia que declare la resolución. Esto constituye una diferencia notable con la condición resolutoria ordinaria, que opera de pleno derecho. La necesidad del ejercicio y del pronunciamiento judicial fluye con claridad del propio tenor del artículo 1489: su inciso 2.º señala «*Pero en tal caso...*», dando a entender que aquí no ocurre lo mismo que en la condición ordinaria; y emplea la expresión «pedir a su arbitrio», lo que implica demandar ante un tribunal que deberá resolver.

Se agrega que, de operar la resolución de pleno derecho, no se ve cómo podría el acreedor ejercer la opción de pedir el *cumplimiento*, pues no parece lógico exigir el cumplimiento de una obligación ya extinguida. **Abeliuk** observa que este razonamiento no es del todo concluyente, ya que el artículo **1487** —aplicable a toda condición resolutoria— permite al acreedor renunciar a la resolución, de modo que «aun cuando ella operara de pleno derecho, al acreedor le bastaría con manifestar su renuncia para poder exigir el cumplimiento». Con todo, la conclusión es firme: la resolución por condición resolutoria tácita exige sentencia.

4.6. La acción resolutoria

Conforme al artículo 1489, ante el incumplimiento el acreedor tiene la opción de pedir el cumplimiento o la resolución, en uno y otro caso con indemnización. Tal opción la ejerce «a su arbitrio»: no debe justificar su decisión, ni procede cotejar las consecuencias de la alternativa elegida con las de la abandonada para deducir alguna limitación. Por ser *incompatibles*, no es posible pedir simultáneamente el cumplimiento y la resolución, pero sí puede pedirse una en subsidio de la otra (art. 17 del Código de Procedimiento Civil). Como precisa **Peñailillo**, la acción resolutoria «es el instrumento procesal destinado a pedir la resolución del contrato».

Abeliuk la define como «la que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial, y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él». La precisión «en los casos en que requiere sentencia» es importante: hay acción resolutoria en la condición resolutoria tácita, en los pactos comisorios típicos (simple y calificado) y en el pacto comisorio atípico simple; en cambio, en la condición resolutoria ordinaria y en el pacto comisorio atípico calificado *no* hay acción, porque la resolución opera de pleno derecho. De ahí que sea erróneo —advierte Abeliuk— afirmar sin matices que la acción resolutoria proviene de la condición resolutoria, pues hay condiciones que no dan acción.

La acción resolutoria presenta las siguientes **características**:

- **Es personal.** En Chile la unanimidad de la doctrina (**Alessandri, Abeliuk, Somarriva**) así lo entiende: deriva del contrato, y los contratos generan derechos personales (art. 578: de los derechos personales nacen las acciones personales). Por ser personal, sólo puede entablarse contra quien celebró el contrato, no contra terceros. Si el comprador enajena la cosa a un tercero, no podrá intentarse contra éste la acción resolutoria —sin perjuicio de que exista contra el tercero *otra* acción (reivindicatoria o restitutoria), según los arts. 1490 y 1491—.

- **Es patrimonial.** Su objeto es dejar sin efecto un contrato patrimonial; no cabe la resolución en el Derecho de Familia. De su carácter patrimonial derivan tres consecuencias capitales:
 - *Es renunciable* (art. 1487 en relación con el art. 12), pues sólo mira al interés del renunciante y su renuncia no está prohibida. Puede renunciarse en el mismo contrato, antes o después del incumplimiento, expresa o tácitamente; el solo hecho de demandar el cumplimiento no supone renuncia a la acción resolutoria.
 - *Es transferible y transmisible:* pueden deducirla los herederos y cesionarios del acreedor, y deben soportarla los herederos del deudor, conforme a las reglas generales.
 - *Es prescriptible.* Por regla general prescribe en **5 años** contados desde que la obligación se hace exigible (arts. 2514 y 2515). Pero en el pacto comisorio de la compraventa por no pago del precio rige la regla especial del artículo 1880: prescribe en el plazo fijado por las partes si no excede de **4 años**, contados *desde la celebración* del contrato. Entre ambas hay tres diferencias: el plazo (5 / 4 años), el momento desde el cual corre, y que la primera es de largo tiempo y se suspende a favor de las personas del art. 2509, mientras que la del art. 1880 es de corto tiempo y, conforme al art. 2524, no se suspende.
- **Es mueble o inmueble** según la cosa sobre que recaiga (art. 580): la del vendedor de un automóvil es mueble; la del vendedor de un bien raíz, inmueble.
- **Es indivisible**, subjetiva y objetivamente. Subjetiva, porque siendo varios los acreedores todos deben ponerse de acuerdo para pedir cumplimiento o resolución, y siendo varios los deudores no podría exigirse a uno el cumplimiento y a otro la resolución (art. 1526 N.º 6; **Fueyo, Somarriva**). Objetiva, porque no se puede demandar en parte el cumplimiento y en parte la resolución: el artículo 1489 da la alternativa entre uno y otra, no la posibilidad de fraccionarlas.

4.7. La posibilidad de enervar la acción mediante el pago

Se suele señalar que, como la resolución por condición resolutoria tácita requiere sentencia, el deudor podría **enervar** la acción *pagando* hasta an-

tes de la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda. Así lo ha sostenido buena parte de los autores. **Claro Solar**: «Mientras la resolución del contrato no ha sido declarada por la sentencia [...], el contrato subsiste; y por lo mismo, hallándose requerido judicialmente el demandado con la notificación de la demanda, puede evitar la resolución ejecutando la obligación [...] durante toda la secuela del juicio» (en igual sentido **Fueyo, Abeliuk, Stitchkin, Somarriva**, y abundante jurisprudencia). El apoyo normativo es el artículo **310** del Código de Procedimiento Civil, que entre las *excepciones anómalas* permite oponer la de pago en cualquier estado de la causa hasta la citación para sentencia en primera instancia y la vista de la causa en segunda.

Doctrina moderna — «El 310 dice que puede oponerse, no que pueda pagarse»

La doctrina moderna estima errada esa solución. **Vial** ofrece tres argumentos: **(1)** el Código Civil no establece que el deudor incumplidor pueda enervar la acción resolutoria con la excepción de pago; **(2)** el artículo 310 del CPC no es sustantivo sino procesal, y sólo precisa la *oportunidad* para oponer la excepción de pago en los casos en que ella sea procedente —si el demandante busca el cumplimiento, el demandado puede oponer el pago; pero si persigue la resolución, esa norma procesal tornaría ilusoria la facultad del art. 1489—; y **(3)** es la parte *diligente*, y no la incumplidora, quien decide si perseverar en el contrato, de modo que la tesis tradicional invierte indebidamente la opción, dejándola en manos del deudor. **Peñailillo** lo sintetiza: «lo que el artículo 310 dispone es que la excepción de pago puede *oponerse* en cualquier estado del juicio, no que se pueda *pagar* en cualquier estado del juicio. [...] Si el deudor había pagado antes de la demanda, puede oponer la excepción durante todo el litigio, pero no significa que pueda pagar después de la demanda, porque entonces la opción la tendría él, lo que es contrario al texto legal; él es el incumplidor, y habiéndose optado por la resolución por quien tenía la opción, ya no es tiempo de que pague».

JURISPRUDENCIA — CS, 25 DE MAYO DE 2011 (SENTIDO DEL ART. 310 CPC)

La Corte Suprema acogió la tesis moderna. Razonó que las excepciones anómalas del artículo 310 —entre ellas la de «pago efectivo de la deuda»— son perentorias que excepcionalmente pueden oponerse en cualquier estado de la causa; pero «obsta al éxito de esta pretensión la tesis defendida en doctrina por Peñailillo [...] en el sentido que, perteneciendo la opción de instar por la resolución o el cumplimiento al contratante diligente, la posibilidad reconocida al incumplidor para neutralizar la demanda mediante el pago de la deuda en cualquier momento del juicio *invertiría el derecho de opción*, traspasándolo a este último y contrariando el sentido de la institución consagrada en el artículo 1489». Y precisó que «lo que el artículo 310 dispone es que la excepción de pago puede oponerse en cualquier estado del juicio, no que se pueda pagar en cualquier estado del juicio». Esta inteligencia —agregó— se asimila a la de códigos modernos como el italiano de 1942 (art. 1453 inc. 3.º) y el boliviano de 1975 (art. 568 inc. 2.º), y «se concilia mejor con el verdadero sentido y alcance del artículo 1489 [...] y acota a su correcta dimensión el 310 del ordenamiento procesal civil».

Distinta es la situación del **pacto comisorio** de la compraventa: el artículo **1879** sí permite enervar la acción comisoria pagando dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. Por ello **Vial** concluye que la acción resolutoria con que el acreedor manifiesta su opción de desistirse del contrato no puede enervarse por el cumplimiento de la obligación infringida, *salvo* que se trate de la obligación de pagar el precio en la compraventa, por aplicación del artículo 1879.

4.8. El artículo 1552 y la excepción de contrato no cumplido

Buena parte de la doctrina tradicional (**Claro Solar, Abeliuk, Alessandri, Somarriva**) sostiene que un requisito de procedencia de la acción resolutoria es que quien la demanda haya cumplido sus obligaciones o esté llano a cumplirlas. El requisito no aparece en el artículo 1489, sino que se haría derivar del artículo **1552**: «*en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos*». Según esta lectura, el artículo 1552 cumpliría un rol *paralizador*: ante la petición de cumplimiento o resolución, el demandado puede denunciar que el actor también es incumplidor, y entonces —porque «cuan-

do ambos están morosos, ninguno lo está»— el actor no está en mora. Es la conocida regla de que «*la mora purga la mora*», que se traduce procesalmente en la **excepción de contrato no cumplido** (*exceptio non adimpleti contractus*).

Doctrina moderna — El verdadero alcance del art. 1552 (Vial)

La doctrina moderna postula que el artículo 1552 tiene un alcance distinto. A diferencia de los ordenamientos que han consagrado expresamente la *exceptio non adimpleti contractus* —los cuales explicitan que una parte no puede exigir el cumplimiento a la otra sino cuando ella misma ha cumplido o está llana a hacerlo—, el artículo 1552 sólo expresa que ninguno de los contratantes se entiende *en mora* si el otro no ha cumplido o no se allana a cumplir. Es decir, el legislador consideró la bilateralidad únicamente para un objeto preciso: **determinar si una parte está o no constituida en mora**. ¿Y para qué efectos se regula la mora? Para establecer si procede o no la **indemnización de perjuicios** derivada del incumplimiento —nada más, ni nada menos—. La norma, por tanto, *no* tiene por finalidad limitar la acción resolutoria.

La consecuencia práctica es relevante. De seguirse la tesis tradicional, ante un *incumplimiento recíproco* no cabría la resolución, porque ninguna de las partes ha cumplido ni está llana a cumplir; y si las partes no acuerdan resciliar, quedarían atadas a un contrato que ninguna quiere ejecutar, en una situación de incertidumbre indefinida (¿qué harán los herederos si fallece una de ellas?), a la espera de que opere la prescripción. Como observa **Vial**, no es lógico que obligaciones que debieron extinguirse por el incumplimiento —aunque éste sea imputable a ambas partes— deban mantenerse artificialmente con vida hasta que las extinga la prescripción; no parece razonable que, si ninguna de las partes quiere perseverar, deban continuar ligadas a menos que una de ellas cumpla, máxime si cumple con el solo objeto de demandar la resolución, que opera como si el contrato nunca hubiera existido.

Dato de grado — No confunda 1489, 1552 y 1551

Tres normas vecinas que el examinador disfruta enredar: el art. **1489** confiere la opción cumplimiento / resolución + indemnización; el art. **1551** regula *cuándo* el deudor queda constituido en mora (las tres reglas: plazo estipulado, plazo tácito necesario, e interpelación judicial); y el art. **1552** establece que en los bilaterales nadie está en mora mientras el otro no cumpla. La pregunta fina es: *¿el 1552 es requisito de la resolución o sólo de la indemnización?* Tradicional → requisito de ambas (excepción de contrato no cumplido). Moderna (Vial, Peñailillo) → sólo condiciona la indemnización, no la resolución, que debe proceder incluso ante incumplimiento recíproco.

4.9. Efectos de la resolución

Los efectos de la resolución por incumplimiento son los mismos de la condición resolutoria ordinaria. En síntesis, la resolución produce un triple orden de efectos:

- **Efecto extintivo.** La resolución pone término al contrato. El artículo **1567** N.º 9 contempla, como modo de extinguir las obligaciones, «el evento de la condición resolutoria»; extinguidas las obligaciones, se extingue el vínculo contractual.
- **Efecto restitutorio entre las partes.** Las partes deben volver al estado anterior a la celebración del contrato, como si nunca hubieren contratado. Así lo ordena el artículo **1487**, de alcance general: «Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente...». De ahí la diferencia con la *terminación* de los contratos de tracto sucesivo, donde no hay restitución de las prestaciones ya consumidas.
- **Efectos respecto de terceros.** Se regulan en los artículos **1490** y **1491**, que distinguen según se trate de bienes muebles o inmuebles y según la buena o mala fe del tercero —régimen sustancialmente más protector del tercero que el de la nulidad—.

4.10. Resolución, nulidad y resciliación

Conviene precisar las diferencias de la resolución con dos instituciones que también dejan sin efecto el contrato: la nulidad y la resciliación.

Frente a la **nulidad** (y la rescisión): **(1)** la nulidad supone una omisión de los requisitos de validez del acto, que nace viciado, mientras que en la resolución el acto es perfectamente válido —inatacable en sí mismo— y es un hecho posterior, el incumplimiento, el que permite dejarlo sin efecto (por ello no puede demandarse la resolución de un contrato de promesa nulo); **(2)** la nulidad produce efectos radicales y da acción contra terceros de buena o mala fe (art. **1689**), mientras que la resolución es de efectos más atenuados y sólo afecta a terceros con las distinciones de los arts. 1490 y 1491; **(3)** la nulidad procede en toda clase de actos y contratos, la resolución sólo en los bilaterales (doctrina mayoritaria); **(4)** la nulidad absoluta prescribe en 10 años, la rescisoria en 4, y la resolutoria por regla general en 5 (4 en el pacto comisorio); y **(5)** las prestaciones mutuas difieren —en la nulidad el poseedor de mala fe restituye los frutos y se pagan las mejoras necesarias, lo que no ocurre del mismo modo en la resolución—.

Frente a la **resciliación**: son instituciones absolutamente diversas. La resolución procede cuando, en un contrato bilateral, una parte no cumple. La resciliación, en cambio, es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo y en virtud de la autonomía de la voluntad, acuerdan dejar sin efecto el contrato (art. **1567** inc. 1.º). Por su propia naturaleza, la resciliación no puede afectar a los terceros: el acuerdo que la constituye les es inoponible (*res inter alios acta*).

4.11. El pacto comisorio

El pacto comisorio está tratado en el párrafo 10 del Título XXIII del Libro IV, a propósito de la compraventa y por el incumplimiento de la obligación de pagar el precio. Su concepto lo da el artículo **1877**: «por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa» (inc. 1.º); «entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio» (inc. 2.º). De allí se desprende que el

pacto comisorio no es más que **la condición resolutoria tácita expresada**, por el no pago del precio en la compraventa: si las partes nada hubieran dicho y el comprador no pagara, el efecto sería en principio el mismo.

Procede en cualquier contrato y por cualquier obligación

Pese a su ubicación, hoy la doctrina es conteste en que el pacto comisorio tiene alcance general: puede establecerse en cualquier contrato —incluso unilateral, con el efecto de anticipar el cumplimiento— y por el incumplimiento de cualquier obligación. Los argumentos: **(a)** el pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria tácita convenida; **(b)** en virtud de la autonomía de la voluntad las partes pueden celebrar cualquier estipulación lícita; y **(c)** sólo por una razón histórica —su origen en la *lex commissoria* romana, en una época en que no se aceptaba la condición resolutoria tácita— el pacto se ubicó entre los pactos accesorios de la compraventa. Es usual en los arrendamientos («si el arrendatario no pagare la renta dentro de los cinco primeros días de cada mes, el contrato se extinguirá de inmediato») y, en la compraventa, respecto de la obligación del vendedor de entregar la cosa.

Pacto comisorio simple y calificado

La doctrina extrae del artículo **1879** dos modalidades: el **pacto comisorio simple**, que no es más que la condición resolutoria tácita expresada (si el comprador no paga, se resolverá el contrato; si el arrendatario no paga la renta, el arrendamiento terminará); y el **pacto comisorio calificado o con cláusula *ipso facto***, que es el acuerdo de dejar sin efecto el contrato *de inmediato*, por el solo hecho del incumplimiento. No se requieren palabras sacramentales: habrá pacto calificado cualesquiera sean los términos empleados, si aparece clara la intención de que la resolución se produzca de inmediato, sin necesidad de declaración judicial («se resolverá de ipso facto», «de pleno derecho», «sin necesidad de juicio», etc.).

Efectos del pacto comisorio

Para estudiar los efectos hay que distinguir si el pacto es *típico* o *atípico* y, en cada caso, si es *simple* o *calificado*.

(1) Pacto comisorio típico —el regulado en los arts. 1877 a 1880, accesorio a la compraventa, por el no pago del precio—:

- *Típico y simple*: el artículo **1878** dispone que «por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873», esto es, exigir el precio (cumplimiento) o la resolución, con indemnización. Sus efectos son idénticos a los de la condición resolutoria tácita y, por lo mismo, requiere sentencia judicial.
- *Típico y calificado*: los regula el artículo **1879**: aunque se haya estipulado que la venta se resuelva «*ipso facto*» por el no pago del precio, «el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda». Pese a la cláusula de inmediatez, la resolución **no opera de pleno derecho**: se concede al comprador un plazo de 24 horas para enervar la acción pagando. La resolución exige, pues, sentencia. Los argumentos son decisivos: **(a)** argumento histórico —Bello se apartó deliberadamente del art. 1656 del Code francés—; **(b)** el art. 1878 no priva al vendedor de pedir el cumplimiento, lo que sería imposible si el contrato ya estuviera resuelto; **(c)** el verbo «subsistir» del art. 1879 supone que el contrato sigue vivo (de otro modo diría «revivir»); **(d)** que el comprador pueda enervar pagando en 24 horas demuestra que la resolución no operó por el solo incumplimiento; y **(e)** el plazo se cuenta «desde la notificación judicial de la demanda», lo que prueba que es necesario un juicio.

Dato de grado — Las 24 horas no son «un día»

El plazo del art. 1879 es de **24 horas**, no de un día. Por tratarse de un plazo de horas, se cuenta desde el momento mismo de la notificación: notificada la demanda a las 17:00 del 13 de septiembre, vence a las 17:00 del 14. Si fuera «un día», en cambio, vencería a la medianoche del 14 (art. 48 CC). Es, además, un plazo **fatal**: cumplido, caduca el derecho del comprador a pagar, sin necesidad de acusar rebeldía (art. 49 CC). Si el vendedor no quiere recibir el pago, el comprador puede pagar por consignación (art. 1600 inc. final). Sobre *cuándo* se produce la resolución hay dos posiciones: al ejecutoriarse la sentencia que acoge la demanda (Barros Errázuriz, Fueyo) o al expirar el plazo de 24 horas sin pago (Alessandri).

(2) Pacto comisorio atípico —el convenido para contratos distintos de la compraventa, o en ésta por una obligación distinta del pago del precio—:

- *Atípico y simple*: siendo sólo la condición resolutoria tácita expresada, sus efectos son los de aquélla —opción de cumplimiento o resolución más indemnización— y requiere sentencia judicial.
- *Atípico y calificado*: aquí se planteó la discusión de si la resolución opera de pleno derecho o requiere sentencia. La doctrina hoy dominante (**Abeliuk, Ramos**) estima que **opera de pleno derecho**, porque eso es lo que las partes quisieron: no estamos ante el pacto del art. 1879 —norma excepcional, restringida a la compraventa por no pago del precio—, sino ante un pacto creado en virtud de la autonomía de la voluntad (art. **1545**), que debe interpretarse según los arts. 1560 y siguientes atendiendo a la intención de los contratantes. **Stitchkin** apoya esta solución.

JURISPRUDENCIA — CS, 2 DE JULIO DE 1948 (PACTO COMISORIO CALIFICADO ATÍPICO OPERA DE PLENO DERECHO)

La Corte Suprema resolvió que en los contratos de arrendamiento las partes pueden estipular la **terminación *ipso facto*** del contrato por incumplimiento de las obligaciones de alguna de ellas, y que esa estipulación «surte los efectos que quisieron atribuirle, o sea, que el contrato queda terminado por el solo hecho de no cumplirse la obligación de que se trata, *sin necesidad de acción en que se pida la terminación ni de sentencia que la declare*». El fallo cuenta con un célebre comentario favorable de **Santa Cruz Serrano**, quien recuerda que el pacto comisorio constituye una condición y que, conforme al artículo **1484**, las condiciones deben cumplirse *literalmente*, en la forma convenida —y exigir sentencia judicial no es lo que las partes convinieron—. En contra se pronunciaron **Arturo Alessandri** y **Claro Solar**, partidarios de aplicar por analogía el art. 1879 (enervación pagando dentro de 24 horas) también a estos pactos, con lo cual igualmente se requeriría juicio. La consecuencia práctica de la tesis dominante: si en el arrendamiento se pactó la terminación *ipso facto* por no pago de las rentas, producido el incumplimiento el arrendador puede demandar directamente la restitución de la cosa, sin pedir la terminación, y el arrendatario carece de la facultad de hacer subsistir el contrato consignando las rentas adeudadas.

Prescripción del pacto comisorio

El artículo **1880** dispone que «el pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes, si no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato», y que «transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno». Importa precisar: **(a)** esta regla rige *únicamente* para el pacto comisorio —simple o calificado— de la compraventa por no pago del precio; el pacto comisorio de otros contratos, o de la compraventa por otra obligación, se rige por las reglas generales de los arts. 2514 inc. 2.º y 2515 (5 años desde que la obligación se hace exigible); **(b)** el art. 1880 no fija un plazo de 4 años, sino el que acuerden las partes *si no pasare* de 4 años, de modo que puede ser menor; y **(c)** contiene una grave anomalía: la prescripción se cuenta *desde la fecha del contrato* y no desde que la obligación se hace exigible, de suerte que la acción puede estar prescrita *antes de nacer* —si en una compraventa se conceden 5 años para pagar el precio y se pacta comisorio, a los 5 años la acción comisoria ya habrá prescrito por haber transcurrido 4 desde el contrato—. Esto último ha sido debatido, pues se sostiene que el acreedor conservaría la acción del art. 1873 (la condición resolutoria tácita), regida por sus propios plazos.

4.12. La cláusula de término unilateral del contrato

Es frecuente que un contrato establezca, en beneficio de una de las partes o de cualquiera de ellas indistintamente, la facultad de ponerle término *sin expresión de causa*, sujetando así la extinción del contrato a la mera voluntad de la parte en cuyo beneficio se ha establecido el derecho de desligarse del vínculo. Existe consenso doctrinal y jurisprudencial sobre la **plena validez** de estas cláusulas: constituyen una manifestación de lo preceptuado en el artículo **1545**, que admite que un contrato válidamente celebrado sea invalidado por el consentimiento mutuo de los contratantes. Esta estipulación —que habilita al término unilateral y anticipado— no es incompatible con una cláusula que fije un plazo general de vigencia: ésta regula el modo «normal» de expiración (el vencimiento del plazo), aquélla una forma «anómala» de terminación anticipada; entenderlo de otro modo restaría efecto a una u otra cláusula, lo que rechaza la regla de interpretación del artículo **1562**.

Ahora bien, que el contrato consagre la facultad de poner término anticipado «sin expresión de causa» **no convierte esa potestad en un derecho absoluto** susceptible de ejercicio arbitrario o abusivo. La cláusula, en su recto sentido, sólo significa que el aviso de término no requiere *expresar* la causa, lo que no exime al término de tener una causa real y lícita, controlable por la jurisdicción para evitar su ejercicio malicioso. Ello se apoya en el artículo **1467**: toda manifestación de voluntad debe tener una causa real y lícita, aunque no sea necesario expresarla. El término anticipado es una manifestación de voluntad y, por tanto, aunque no deba expresar su causa, ha de estar motivado por una causa real y lícita, sometible al escrutinio judicial.

JURISPRUDENCIA — CS, 22 DE MAYO DE 2019 (BUENA FE Y TÉRMINO NO ABUSIVO)

La Corte Suprema resolvió que, más allá de los términos de la cláusula, resulta contrario a la **buena fe** (art. 1546) admitir un término *intempestivo, abrupto o abusivo* del contrato, de modo que la decisión de poner término anticipado debe sustentarse en un «motivo racional y justo». El fallo se inscribe en la línea jurisprudencial que interpreta los contratos conforme al principio de buena fe, especialmente respecto de convenciones que alteran la responsabilidad civil legal, y hace suya una cita de Corral: «Una absolutización ideológica del principio de la intangibilidad contractual, que llevara a excluir a priori todo tipo de intervención en el contenido de un acuerdo contractual, correría un serio riesgo de transformar el contrato en un instrumento de explotación y dominio más que de expresión de la libertad personal». Como han resuelto reiteradamente los tribunales de alzada, la interpretación de buena fe impide que los contratantes se asilen en la literalidad inflexible del contrato para dar menos o exigir más arbitrariamente, al influjo de un interés propio y mezquino.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 4 — La resolución por incumplimiento**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Presta especial atención a las diferencias entre la doctrina tradicional y la moderna en el incumplimiento resolutorio, el art. 1552 y la enervación por pago.

5. LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

La indemnización de perjuicios es, de todos los efectos del incumplimiento, el que mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial ha alcanzado, y constituye —junto con la ejecución forzada y la resolución— uno de los pilares del derecho de la responsabilidad contractual. Mientras la ejecución forzada persigue la prestación *en naturaleza* y la resolución desliga al acreedor del vínculo, la indemnización mira a un objetivo distinto: **reparar el daño** que el incumplimiento ha causado en el patrimonio o en la persona del acreedor. Por eso suele decirse que es el remedio que, sin restituir lo debido *in natura*, procura colocar al acreedor en la situación patrimonial equivalente a aquella en que se hallaría si la obligación se hubiese cumplido oportuna e íntegramente.

Es ésta la materia donde confluyen con mayor intensidad las tres fuentes que este manual procura refundir: la sistematización de **Boetsch**, la exposición de **Orrego** y —muy señaladamente en lo relativo al daño— el tratado de **Rodríguez Grez**, cuyo análisis de las clasificaciones del perjuicio y del daño moral contractual es el más extenso de nuestra literatura. A ellos se suman los desarrollos jurisprudenciales recientes de la Corte Suprema, que han ido perfilando cuestiones tan debatidas como la autonomía de la indemnización, la procedencia del daño moral en sede contractual y la reparación de la pérdida de una chance u oportunidad.

5.1. Concepto y naturaleza jurídica

Siguiendo a **Abeliuk**, la indemnización de perjuicios puede definirse como «*la cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor y que equivalga o represente lo que éste habría obtenido con el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación*». **Boetsch** la concibe, en la misma línea, como el derecho que tiene el acreedor para que el deudor le repare los perjuicios derivados del incumplimiento, sustituyendo el objeto de la obligación o agregándose a él. De ahí que tradicionalmente se la denomine *cumplimiento por equivalencia*: el deudor no ejecuta la prestación debida, pero satisface el interés del acreedor mediante un equivalente pecuniario. La indemnización opera, así, como una forma de cumplimiento que sustituye —cuando es compensatoria— o complementa —cuando es moratoria— la prestación originaria.

Orrego introduce aquí una precisión terminológica de raíz **pothieriana** que conviene retener, pues distingue tres nociones que el lenguaje corriente confunde: el *daño*, el *perjuicio* y la *indemnización*. El **daño** es el detrimento, menoscabo o lesión que sufre una persona, sea en su patrimonio, sea en su persona física o moral; el **perjuicio** es la consecuencia o proyección de ese daño, esto es, la ganancia o beneficio que se deja de obtener a raíz de él; y la **indemnización** es la reparación de ambos, el resarcimiento en que se traduce la obligación del deudor. Existe, pues, una secuencia lógica: el incumplimiento produce un *daño*, del daño se sigue un *perjuicio*, y a la reparación de uno y otro se la llama *indemnización*. Si bien nuestro Código Civil emplea con frecuencia las voces «daño» y «perjuicio» como sinónimas —y la práctica forense las trata indistintamente—, la distinción

es útil para comprender que lo que se indemniza no es sólo la lesión actual, sino también sus repercusiones económicas futuras.

La indemnización tiene siempre un carácter **pecuniario**: se traduce en el pago de una suma de dinero. Ello la diferencia de la ejecución forzada en naturaleza y constituye una de sus notas definitorias en el sistema chileno, donde no se admite con generalidad la reparación en especie de la responsabilidad contractual. El dinero cumple aquí una función de *medida común de los valores*, permitiendo traducir a una cifra el menoscabo sufrido por el acreedor.

Doctrina — La indemnización como obligación de segundo grado

La doctrina coincide en que la obligación de indemnizar no es la obligación primitiva, sino una **obligación nueva en su objeto** que nace del incumplimiento. Sin embargo —y aquí radica su naturaleza— no es una obligación enteramente autónoma: deriva, se apoya y se explica por referencia a la obligación incumplida. Es, en expresión gráfica, una obligación «de segundo grado» que presupone y prolonga la primera. De esta dependencia se extraen consecuencias prácticas relevantes: la indemnización conserva los caracteres, garantías y privilegios de la obligación originaria, y se rige —en cuanto a su fuente y naturaleza— por el estatuto de aquélla.

En cuanto a su **naturaleza jurídica**, la cuestión decisiva es determinar si la obligación de indemnizar constituye una obligación *distinta* de la incumplida o si es *la misma* obligación que subsiste, mudada su forma. La doctrina dominante —recogida por **Boetsch**— responde a través de la noción romana de *perpetuatio obligationis*: la obligación primitiva no se extingue con el incumplimiento, sino que **subsiste y se perpetúa**, variando únicamente su objeto, que de la prestación específica pasa a ser su equivalente en dinero. La obligación es, pues, la misma; lo que cambia es aquello en que ha de satisfacerse. Este principio encuentra anclaje en dos disposiciones capitales del Código:

- El artículo **1672**, según el cual «*si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor*». La fórmula es inequívoca: la obligación *subsiste* —no nace una nueva— y sólo *varía de objeto*.
- El artículo **1555**, en materia de obligaciones de no hacer, que conduce a la indemnización cuando no puede deshacerse lo hecho, confirmando que el incumplimiento desemboca en el equivalente pecuniario sin extinguir el vínculo.

De la tesis de la *perpetuatio obligationis* se sigue una consecuencia dogmática que el examinando debe dominar: **la indemnización de perjuicios no importa novación** de la obligación. No hay aquí sustitución de una obligación por otra con extinción de la primera (art. **1628**), sino subsistencia de la misma obligación con un objeto distinto. Por ello la indemnización conserva las cauciones, los privilegios y la prescripción de la obligación primitiva; la fianza, la prenda o la hipoteca que garantizaban el cumplimiento garantizan también la indemnización, precisamente porque no estamos ante una obligación nueva sino ante la antigua transformada en su objeto. Esta es una de las razones por las que la distinción entre *perpetuatio* y novación tiene rendimiento práctico y no es una mera sutileza académica.

Dato de grado — Perpetuatio obligationis, no novación

Pregunta recurrente: «¿La indemnización de perjuicios extingue la obligación incumplida?». Respuesta: **no**. La obligación *subsiste* y sólo *varía de objeto* (art. 1672), por aplicación del principio de *perpetuatio obligationis*. No hay novación (no concurre la voluntad de novar ni se cumplen los requisitos de los arts. 1628 y ss.), y por eso la indemnización conserva las garantías y privilegios de la obligación originaria. Memoriza el binomio: **perpetuatio sí, novación no**.

Doctrina — La doble función de la indemnización (Pizarro): aestimatio rei e id quod interest

Carlos Pizarro, recogiendo la distinción que en la doctrina francesa esclareció **Huet**, advierte que la indemnización contractual no cumple una función única, sino **doble**. Por una parte, opera como *cumplimiento por equivalencia* de la prestación prometida —el **aestimatio rei**, esto es, el valor de la cosa o prestación insatisfecha—, lo que importa sancionar una deuda preexistente; por otra, opera como genuina *reparación* de los daños causados al acreedor con ocasión del incumplimiento —el **id quod interest**, vale decir, los perjuicios que recaen en bienes distintos del objeto del contrato o en la persona misma del acreedor (señaladamente, el daño moral o el daño a la integridad física)—. Por eso —concluye **Pizarro**, en la línea ya anunciada por **Fueyo y Alessandri**— la responsabilidad contractual *no se restringe al simple valor de la prestación debida*: muchas veces el daño consecutivo al incumplimiento excede con creces el valor del crédito —piénsese en la semilla defectuosa que arruina toda la cosecha, o en el servicio médico que lesiona la salud—, hasta el punto de tornar irrelevante la reparación del primero. La distinción entre una y otra función no es ociosa: incide en la **prueba** (el valor de la prestación es de fácil acreditación; los daños consecutivos exigen una prueba más compleja a cargo del acreedor) y en la **extensión** del resarcimiento (art. 1558).

5.2. Clases: indemnización compensatoria y moratoria

La distinción capital, sobre la que descansa buena parte del régimen de la indemnización, es la que separa la **indemnización compensatoria** de la **indemnización moratoria**. **Boetsch** la expone tomando como apoyo la clásica formulación de **Baudry-Lacantinnerie**, y **Orrego** la recoge en idénticos términos. El criterio diferenciador atiende a *qué* es lo que la indemnización viene a reparar:

- La **indemnización compensatoria** es la suma de dinero que el acreedor tiene derecho a exigir del deudor y que *equivale o representa el valor de la prestación no cumplida*, sea total o parcialmente. Repara el daño derivado del *incumplimiento mismo* —del no pago, del pago parcial o del pago defectuoso— y, por ello, **reemplaza** a la prestación debida: ocupa el lugar del objeto de la obligación.
- La **indemnización moratoria** es la suma de dinero que el acreedor tiene derecho a exigir del deudor y que *representa el perjuicio causado por el retardo* en el cumplimiento. No reemplaza a la prestación —que aún puede ejecutarse o ejecutarse forzosamente—, sino que repara el daño que el acreedor experimenta por *no haber recibido la cosa o el servicio en la oportunidad debida*. Se **agrega**, pues, a la prestación.

De esta caracterización se sigue la regla práctica más importante de la materia, relativa a su **acumulabilidad**. La indemnización *compensatoria*, por reemplazar a la prestación, **no puede acumularse** con el cumplimiento en naturaleza de la misma obligación, pues ello importaría un doble pago: el acreedor recibiría a la vez la cosa debida y su equivalente en dinero, enriqueciéndose sin causa. En cambio, la indemnización *moratoria*, por reparar un daño distinto —el del retardo— y agregarse a la prestación, **sí puede acumularse** tanto con el cumplimiento en naturaleza como con la indemnización compensatoria. Esta regla, lejos de ser una construcción puramente doctrinal, se desprende con nitidez de varias disposiciones del Código:

- El artículo **1553**, en las obligaciones de hacer, faculta al acreedor para pedir, junto con cualquiera de las opciones que enumera, «*que se le indemnicen los perjuicios resultantes de la infracción del contrato*»: la indemnización moratoria se suma a la ejecución.
- El artículo **1537**, en sede de cláusula penal, permite al acreedor —después de constituido el deudor en mora— pedir *a la vez* el cumplimiento de la obligación principal y la pena, cuando ésta se ha estipulado por el simple retardo (es decir, cuando es moratoria), o cuando se ha pactado expresamente que el pago de la pena no extingue la obligación principal.
- El artículo **1543** confirma, a contrario, que por regla general *no* pueden acumularse la obligación principal y la pena (compensatoria), «*a menos de haberse estipulado*» lo contrario o de tratarse de pena moratoria.

Doctrina — La crítica de Vial a la sinonimia «compensatoria = total»

Víctor Vial advierte que la nomenclatura tradicional puede inducir a error si se identifica mecánicamente la indemnización compensatoria con la reparación *total* del incumplimiento. La compensatoria no necesariamente cubre «todo»: puede ser *parcial* cuando lo incumplido es sólo una parte de la prestación, o cuando el cumplimiento ha sido imperfecto. Lo que define a la compensatoria no es su cuantía, sino su *función sustitutiva*: viene a ocupar el lugar de la prestación (o de la porción de ella) que no se ejecutó. La distinción relevante, por tanto, no es «total/parcial» sino **«sustituye» (compensatoria) frente a «se agrega» (moratoria)**.

Conviene precisar un punto que suele confundir al examinando: el hecho de que la indemnización compensatoria *no se acumule* con el cumplimiento en naturaleza no significa que el acreedor deba optar entre la indemnización y *toda* otra pretensión. El acreedor puede, perfectamente, demandar el cumplimiento forzado de la obligación **más** la indemnización moratoria por el retardo sufrido hasta el cumplimiento; o demandar la resolución del contrato **más** la indemnización compensatoria y moratoria. Lo único vedado es sumar el cumplimiento en naturaleza de una prestación *con* su equivalente compensatorio, porque ambos cubren el mismo interés.

Finalmente, la determinación de si una indemnización es compensatoria o moratoria no es una cuestión puramente teórica: incide en el **cómputo de los plazos**, en la **imputación de pagos**, en la **compatibilidad con la resolución o el cumplimiento** y, sobre todo, en la **carga de probar** uno u otro tipo de perjuicio. De ahí que el primer ejercicio que debe hacer quien analiza un caso de responsabilidad contractual sea calificar con precisión qué daño se reclama: el derivado del incumplimiento mismo (compensatorio) o el derivado del retardo (moratorio).

5.3. ¿Es la indemnización un remedio autónomo?

Una de las controversias más vivas del derecho de obligaciones contemporáneo es la relativa a la **autonomía de la indemnización de perjuicios**,

esto es, la cuestión de si el acreedor puede demandar *directamente* la indemnización compensatoria —sin pedir simultánea o previamente el cumplimiento forzado o la resolución del contrato— o si, por el contrario, la indemnización es un remedio *subordinado* que sólo puede ejercerse «acompañando» a uno de aquéllos. El debate, que parece técnico, tiene enorme rendimiento práctico, pues de su solución depende que un acreedor que ya no tiene interés en la prestación ni en deshacer el contrato pueda, no obstante, obtener la reparación del daño sufrido.

La tesis tradicional: la indemnización compensatoria es accesorio

La doctrina clásica chilena —representada por **Alessandri**, **Claro Solar** y, en general, por los autores que interpretan literalmente el artículo **1489**— sostiene que la indemnización compensatoria **no es autónoma**. Su argumento central es de texto: el art. 1489, al consagrar la condición resolutoria tácita, dispone que el contratante diligente podrá pedir «a su arbitrio» o la resolución o el cumplimiento del contrato, «con indemnización de perjuicios». La preposición «con» revelaría que la indemnización es un complemento que se agrega a una de las dos acciones principales (resolución o cumplimiento), pero que no puede ejercerse de modo independiente. A ello se añade un argumento sistemático: si se admitiera la indemnización compensatoria autónoma, el acreedor podría, en los hechos, alterar unilateralmente el objeto de la obligación, transformando la prestación específica en una suma de dinero sin que concurra ninguna de las hipótesis que la ley contempla para ello. Bajo esta tesis, sólo la indemnización *moratoria* puede demandarse aisladamente, porque ella supone la subsistencia de la obligación y se agrega naturalmente al cumplimiento.

La tesis moderna: la indemnización como remedio autónomo

La doctrina moderna —cuyos exponentes en Chile son, entre otros, **Álvaro Vidal**, **Carlos Pizarro** y la corriente que se inspira en el derecho uniforme (Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, Principios UNIDROIT, Principios de Derecho Europeo de los Contratos)— sostiene, por el contrario, que la indemnización es un **remedio autónomo** que el acreedor puede ejercer con independencia de la resolución o del cumplimiento. **Boetsch** distingue, dentro de esta corriente, **dos vertientes** argumentativas:

- **Primera vertiente (sistemática-finalista):** el moderno «derecho de los remedios» concibe el incumplimiento como un supuesto de hecho único que abre al acreedor un *abanico de medios de tutela* —cumplimiento específico, resolución, reducción del precio, indemnización— entre los cuales puede optar libremente según cuál satisfaga mejor su interés. La indemnización no es un apéndice de los otros remedios, sino uno más, situado en pie de igualdad. La preposición «con» del art. 1489 no expresaría subordinación, sino la *posibilidad* de acumulación. El interés del acreedor —y no la voluntad abstracta de mantener la prestación específica— es el centro del sistema.
- **Segunda vertiente (basada en la obligación de garantía):** el deudor, al obligarse, garantiza un resultado; si éste no se alcanza, debe reparar el daño consiguiente cualquiera sea la suerte del contrato. La indemnización surge directamente del incumplimiento como lesión del derecho de crédito, sin necesidad de pasar por la resolución o el cumplimiento.

El principal argumento de texto de la tesis moderna se construye a partir del artículo **1553** (obligaciones de hacer), que permite al acreedor pedir «a su arbitrio» —entre otras cosas— «que se le indemnicen los perjuicios resultantes de la infracción del contrato», sin condicionar esa pretensión al ejercicio previo de otra acción. Si en las obligaciones de hacer la indemnización puede demandarse autónomamente, no se ve razón para negarlo en las de dar. Se invoca también el artículo **1672**, que en la pérdida culpable del cuerpo cierto hace «subsistir» la obligación variando su objeto al «precio de la cosa» *más* la indemnización, lo que demuestra que el ordenamiento admite la transformación del objeto en su equivalente pecuniario.

La jurisprudencia de la Corte Suprema

La Corte Suprema ha transitado desde una posición tradicional hacia una creciente apertura a la autonomía, aunque sin una línea del todo uniforme. Conviene conocer los fallos que **Boetsch** y **Orrego** citan como hitos:

JURISPRUDENCIA — CS, ROL 1782-2007, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (TESIS DE LA DEPENDENCIA)

En este fallo la Corte adscribió a la **tesis tradicional**: sostuvo que la indemnización de perjuicios *compensatoria* es **dependiente** de la acción de cumplimiento o de resolución, de modo que no puede demandarse de manera autónoma respecto de una obligación de dar. Se apoyó en la lectura literal del art. 1489 («con indemnización de perjuicios») y en la idea de que admitir la autonomía equivaldría a permitir que el acreedor mude unilateralmente el objeto de la obligación.

JURISPRUDENCIA — CS «ZORIN CON COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO», ROL 3.325-2012, 31 DE OCTUBRE DE 2012 (AUTONOMÍA)

Es el fallo emblemático del giro hacia la **autonomía**. En un contrato de compraventa de níquel en que el comprador (Zorin) reclamó los perjuicios derivados de la entrega de un producto que no servía para el fin previsto, la Corte acogió la **demanda autónoma de indemnización de perjuicios**, desvinculada de la resolución y del cumplimiento, y concedió el lucro cesante reclamado (del orden de US\$330.000). Razonó que el moderno derecho de la contratación, influido por la Convención de Viena, reconoce al acreedor un *sistema de remedios* entre los que la indemnización ocupa un lugar propio; que el art. 1489 no impone subordinación; y que negar la autonomía dejaría sin reparación a quien, habiendo recibido una prestación inútil, ya no tiene interés en el cumplimiento ni en la resolución. El fallo cita también los Roles 5898-2012 y 3341-2012 en la misma dirección.

JURISPRUDENCIA — CS «UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS», ROL 17.108-2013, 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 (AUTONOMÍA, CON VOTO DISIDENTE)

La Corte reiteró la procedencia de la **indemnización autónoma**, consolidando la línea de *Zorin*. El fallo es especialmente útil para el examen porque incluye un **voto disidente del ministro Valdés**, que defendió la tesis tradicional de la dependencia. El contraste entre la mayoría y la disidencia ofrece, en una sola sentencia, el mapa completo del debate: la mayoría privilegia el interés del acreedor y el sistema de remedios; la disidencia, la literalidad del art. 1489 y la integridad del objeto de la obligación.

JURISPRUDENCIA — CS, ROL 474-2014, 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 (IURA NOVIT CURIA)

La Corte acogió la indemnización empleando el principio *iura novit curia* (el juez conoce el derecho), recalificando la acción para dar al acreedor la tutela que correspondía a los hechos probados, aun cuando la pretensión no hubiese sido planteada con precisión técnica. El fallo muestra la tendencia a privilegiar la **satisfacción efectiva del interés del acreedor** por sobre los reparos formales.

JURISPRUDENCIA — CS, ROL 14.008-2013, 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 (FUNDAMENTOS DE LA AUTONOMÍA)

En sus considerandos 4.º a 6.º la Corte desarrolló con amplitud los **fundamentos dogmáticos de la autonomía**: el incumplimiento como supuesto único generador de responsabilidad, el carácter del crédito como derecho cuya lesión debe repararse, y la inexistencia de un mandato legal que obligue a ejercer previamente el cumplimiento o la resolución. Es uno de los fallos más citados para fundar la tesis moderna.

La opinión de Boetsch: una autonomía matizada

Frente a este panorama, **Boetsch** adopta una posición **matizada** que el examinando hará bien en retener, por su equilibrio. Sostiene que, como *regla general*, la indemnización **compensatoria no es autónoma**: debe demandarse conjuntamente con la resolución o el cumplimiento, conforme a la estructura del art. 1489. Sin embargo, reconoce **tres excepciones** en que la indemnización sí puede reclamarse de modo independiente:

- **(i) La indemnización moratoria.** Por reparar el daño del retardo y no sustituir a la prestación, siempre ha podido demandarse autónomamente, sin necesidad de pedir cumplimiento ni resolución. Sobre este punto no hay controversia.
- **(ii) El cumplimiento imperfecto no resolutorio (art. 1590 inc. 2.º).** Cuando el deudor entrega la cosa con deterioros o de modo imperfecto, pero el acreedor opta por recibirla en lugar de resolver, el art. 1590 inc. 2.º lo autoriza a recibir la cosa «y exigir... que se le indemnice de los deterioros». Aquí la indemnización se demanda *sin* resolución y *sin* cumplimiento adicional, porque el acreedor ya recibió la prestación, aunque defectuosa.

- **(iii) Los contratos de tracto sucesivo.** En contratos de ejecución continuada o periódica (arrendamiento, suministro), el incumplimiento de una prestación ya devengada e irrecuperable —por ejemplo, la falta de suministro durante un período ya transcurrido— sólo puede repararse mediante indemnización, pues ni el cumplimiento en naturaleza (el tiempo no vuelve) ni la resolución (que opera hacia el futuro) restituyen el interés lesionado. La indemnización es, entonces, el único remedio idóneo y se demanda autónomamente.

Dato de grado — Cómo responder la pregunta por la autonomía

Estructura tu respuesta en cuatro pasos: **(1)** plantea el problema (¿puede demandarse la indemnización compensatoria sin pedir cumplimiento ni resolución?); **(2)** expón la *tesis tradicional* (no autónoma; argumento literal del art. 1489 «con indemnización»; Alessandri, Claro Solar; CS Rol 1782-2007); **(3)** expón la *tesis moderna* (autónoma; sistema de remedios e interés del acreedor; CVCIM; Vidal, Pizarro; CS «Zorin» Rol 3.325-2012 y «Santo Tomás» Rol 17.108-2013); y **(4)** cierra con la *posición matizada de Boetsch* (regla: no autónoma; excepciones: moratoria, art. 1590 inc. 2.º y tracto sucesivo). Mencionar el voto disidente de Valdés en «Santo Tomás» denota dominio fino del tema.

5.4. Primer requisito: incumplimiento imputable (dolo y culpa)

Para que el acreedor tenga derecho a la indemnización de perjuicios no basta el solo incumplimiento: la doctrina exige la concurrencia copulativa de varios **requisitos**. Orrego, siguiendo a **Alessandri**, los enumera del siguiente modo: **(1)** que haya *incumplimiento* de la obligación; **(2)** que el incumplimiento sea *imputable* al deudor, esto es, que provenga de su dolo o de su culpa; **(3)** que el deudor esté *en mora*; **(4)** que el incumplimiento haya causado *perjuicios* al acreedor; **(5)** que entre el incumplimiento y los perjuicios exista una *relación de causalidad*; y **(6)** que no concurra una *causal de exención* de responsabilidad. Las subsecciones siguientes desarrollan cada uno de los requisitos sustantivos —imputabilidad, perjuicio, causalidad y mora—; las causales de exención se tratan separadamente en la Sección 6. Comenzamos por la **imputabilidad**, que es la con-

dición que transforma un mero incumplimiento objetivo en un incumplimiento *generador de responsabilidad*.

El incumplimiento es **imputable** cuando puede atribuirse a un factor subjetivo de reproche del deudor, que en materia contractual reviste dos formas: el **dolo** y la **culpa**. A ellas la doctrina añade el llamado *hecho del deudor*, que **Orrego** trata como una tercera modalidad de imputación. Sólo si el incumplimiento proviene de alguna de estas causas surge la obligación de indemnizar; si, en cambio, obedece a un hecho ajeno e irresistible —el caso fortuito o la fuerza mayor—, el deudor queda exonerado, según se verá.

El dolo contractual

El artículo **44** define el dolo como «*la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro*». Trasladada esta noción al ámbito contractual, el dolo consiste en el **incumplimiento deliberado** de la obligación con el propósito de dañar al acreedor o, al menos, con conciencia de que el incumplimiento le causará perjuicio. **Boetsch** subraya que el dolo es un *vicio de la conducta* en la fase de ejecución del contrato —distinto del dolo como vicio del consentimiento (art. 1458) y del dolo como elemento de la responsabilidad extracontractual—, aunque la definición del art. 44 es común a las tres hipótesis (el llamado «dolo, concepto unitario»). De la regulación del dolo contractual interesan cuatro reglas capitales:

- **(a) El dolo no se presume; debe probarse (art. 1459).** «El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse». Quien alega que el incumplimiento fue doloso —el acreedor— soporta la carga de acreditarlo, lo que en la práctica es difícil por tratarse de un elemento interno. Esta es una diferencia esencial con la culpa, que sí se presume en sede contractual.

- **(b) El dolo agrava la responsabilidad (art. 1558).** Si el incumplimiento es *culpable*, el deudor sólo responde de los perjuicios *directos previstos* (los que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato). Pero si el incumplimiento es *doloso*, el deudor responde, además, de los perjuicios *directos imprevistos*. En ningún caso, eso sí, se responde de los perjuicios *indirectos*, ni siquiera mediando dolo: el art. 1558 traza ahí una frontera infranqueable. El dolo, pues, *extiende* la responsabilidad de los perjuicios previstos a los imprevistos, pero no la lleva hasta los indirectos.
- **(c) La condonación del dolo futuro no vale (art. 1465).** «El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale». Esta norma es de orden público: las partes no pueden pactar anticipadamente que el deudor quedará exento de responsabilidad por su propio dolo, pues ello equivaldría a autorizar el fraude. Sí puede, en cambio, condonarse el dolo *ya acontecido*, con tal de que la condonación sea expresa.
- **(d) El dolo se aprecia in concreto.** A diferencia de la culpa —que se aprecia en abstracto, comparando la conducta del deudor con un modelo ideal—, el dolo se valora *en concreto*, atendiendo a la efectiva intención o representación del deudor incumplidor. No hay «grados» de dolo: o lo hay o no lo hay.

La culpa contractual

La culpa es la falta de la **diligencia o cuidado** debidos en el cumplimiento de la obligación. A diferencia del dolo, no supone intención de dañar, sino *negligencia, imprudencia o impericia*. El artículo **44** establece la célebre **graduación tripartita** de la culpa, que es columna vertebral de todo el sistema:

- **Culpa grave o lata:** «consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios». Es la máxima negligencia. El art. 44 agrega una regla de enorme importancia: «*Esta culpa en materias civiles equivale al dolo*». La **asimilación culpa grave = dolo** implica que el deudor que incurre en culpa grave responde como si hubiera obrado dolosamente —incluidos los perjuicios imprevistos del art. 1558— y que, en lo relativo a la condonación anticipada, tampoco puede liberarse de antemano de su culpa grave.
- **Culpa leve:** «la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios». Es el modelo del «*buen padre de familia*» que el propio art. 44 menciona: quien responde de culpa leve debe comportarse como un administrador medianamente diligente. La culpa leve es la **regla general**: cuando la ley habla de «culpa» o «descuido» sin otra calificación, se entiende culpa leve.
- **Culpa levísima:** «la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes». Es el grado más exigente: responde de culpa levísima quien debe emplear una diligencia *esmerada*, superior a la ordinaria.

Ahora bien, ¿**de qué culpa responde el deudor** en un contrato determinado? La respuesta la da el artículo **1547** inciso 1.º, que distribuye la carga de la diligencia según la *utilidad* que el contrato reporta a las partes —criterio de raíz romana (la *prestación de la culpa* según el provecho):

- El deudor responde de la **culpa levísima** en los contratos que por su naturaleza son útiles *sólo al deudor* (ej.: el comodato, en que sólo el comodatario se beneficia del préstamo gratuito de la cosa). Como recibe todo el provecho, se le exige la máxima diligencia.
- Responde de la **culpa leve** en los contratos que se hacen para *beneficio recíproco* de ambas partes (ej.: la compraventa, el arrendamiento). Es el caso más frecuente y por eso la culpa leve es la regla general.
- Responde de la **culpa grave** en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles *al acreedor* (ej.: el depósito, en que el depositario presta un servicio gratuito al depositante). Como nada gana, se le exige sólo evitar la negligencia grosera.

Esta distribución es *supletoria*: las partes pueden alterarla por estipulación (art. 1547 inc. final: «todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes»), y también puede modificarla la ley en contratos específicos.

Doctrina — La presunción de culpa contractual (art. 1547 inc. 3.º)

La regla probatoria más característica de la responsabilidad contractual —y una de las que con más frecuencia se pregunta— está en el artículo **1547** inciso 3.º: «*La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*». De aquí se sigue que, acreditada por el acreedor la existencia de la obligación y su incumplimiento, **la culpa del deudor se presume**: es el deudor quien debe probar que empleó la diligencia debida (o que el incumplimiento se debió a caso fortuito) para liberarse. Esta presunción de culpa —que no existe, en cambio, respecto del dolo (art. 1459)— invierte la carga de la prueba en favor del acreedor y constituye una de las grandes ventajas del estatuto contractual frente al extracontractual, donde por regla general la culpa debe probarla la víctima. **Boetsch** precisa que lo presumido es la *culpa*, no el incumplimiento ni el perjuicio, que siguen correspondiendo al acreedor (art. 1698).

El deudor responde, además, del **hecho de las personas por quienes fuere responsable**. Así lo confirman el artículo **1679** («En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable») y el artículo **1590**, que en la pérdida o deterioro de la cosa debida imputa al deudor el hecho de sus dependientes. La responsabilidad contractual por el hecho ajeno opera, así, de modo más severo que en sede extracontractual, pues el deudor no puede exonerarse probando que eligió o vigiló diligentemente a sus auxiliares: responde de su hecho como del propio.

El hecho del deudor como factor de imputación

Orrego agrega a la imputación por dolo y por culpa una tercera categoría: el **hecho (o culpa) del deudor** propiamente tal, que abarca aquellas conductas del deudor que, sin ser necesariamente dolosas ni encuadrarse

limpiamente en la negligencia, determinan el incumplimiento por haber el deudor *dispuesto* de la cosa o *provocado* la imposibilidad. La ley contempla diversas hipótesis que conviene comparar:

- El artículo **2187**, en el comodato, hace responsable al comodatario que *enajena* la cosa prestada.
- El artículo **1678** dispone que «si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios», regulando el *hecho del deudor* que destruye la cosa creyéndose libre.
- El artículo **898**, en la reivindicación, hace responsable al poseedor que por *hecho o culpa suya* dejó de poseer, permitiendo dirigir la acción contra él.

La comparación de estas normas muestra que el ordenamiento atribuye al deudor las consecuencias de sus propios hechos voluntarios sobre la cosa debida, con matices según concurra o no buena fe e ignorancia de la obligación.

Doctrina — ¿Ausencia de culpa o caso fortuito? El debate Claro Solar / Abeliuk

Una cuestión clásica, que **Orrego** expone con detalle, es si al deudor le basta, para liberarse, probar la **simple ausencia de culpa** (que empleó la diligencia debida) o si debe acreditar derechamente el **caso fortuito** (un hecho externo, imprevisible e irresistible). **Claro Solar** sostiene que basta probar la *ausencia de culpa*: el art. 1547 inc. 3.º pone a cargo del deudor «la prueba de la diligencia o cuidado», de modo que demostrada ésta, el deudor se exonera aunque no identifique la causa precisa del incumplimiento. **Abeliuk**, en cambio, advierte que el inciso 2.º del mismo art. 1547 exige al deudor probar el *caso fortuito* para liberarse, y que ambas exigencias —ausencia de culpa y caso fortuito— no son equivalentes: puede haber incumplimiento sin culpa que, sin embargo, no constituya caso fortuito. La doctrina mayoritaria moderna se inclina por admitir que la prueba de la ausencia de culpa es suficiente cuando la obligación es de medios, mientras que en las obligaciones de resultado el deudor sólo se libera probando el caso fortuito. El punto se conecta directamente con la Sección 6 (causales de exención).

5.5. Segundo requisito: el perjuicio (concepto, requisitos y clases)

El perjuicio es el **requisito medular** de la indemnización: sin daño no hay nada que reparar, por dolosa o culpable que haya sido la conducta del deudor. Aquí la exposición se enriquece decisivamente con el tratado de **Rodríguez Grez**, «El Daño», cuyo análisis es el más extenso y matizado de la doctrina nacional y que en numerosos puntos desarrolla o discrepa de las exposiciones de **Boetsch** y **Orrego**. Esta subsección refunde las tres fuentes, dando especial relieve —conforme lo exige el carácter monográfico de Grez sobre la materia— a sus clasificaciones del daño y a su tesis sobre el daño moral contractual.

Concepto de daño y de perjuicio

En su acepción más amplia, el **daño** es todo *menoscabo, detrimento o lesión* que una persona experimenta en su patrimonio, en su persona física o en sus atributos morales. **Boetsch** lo define, en sede contractual, como

el detrimento que sufre el acreedor en su patrimonio o en su persona a consecuencia del incumplimiento. **Rodríguez Grez** aporta una definición de mayor densidad conceptual: el daño contractual es el «*menoscabo real o virtual que experimenta el patrimonio del acreedor a consecuencia del incumplimiento*». La incorporación de la idea de menoscabo **virtual** —y no sólo real o actual— es una de las claves de todo el sistema de Grez, pues le permite explicar tanto el lucro cesante como, según se verá, el propio daño moral contractual.

Doctrina — Reparación limitada (contractual) frente a reparación integral (extracontractual): la tesis de Grez

Un aporte central de **Rodríguez Grez** —que conviene contrastar con la exposición más uniforme de Boetsch y Orrego— es su insistencia en que el daño *contractual* y el daño *extracontractual* obedecen a **principios reparatorios distintos**. En sede extracontractual rige el principio de **reparación integral**: conforme al artículo **2329** («por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta»), se indemniza *todo* el daño, sin más límites que la causalidad. En sede contractual, en cambio, la reparación es **limitada o restringida**: los artículos **1556** (daño emergente y lucro cesante), **1558** (perjuicios previstos/imprevistos, directos/indirectos) y **1559** (obligaciones de dinero) *acotan* qué daños se indemnizan y hasta qué punto. El deudor contractual no responde de todo el daño causado, sino sólo de aquél que la ley delimita: los perjuicios *directos* y, en principio, sólo los *previstos*. Esta asimetría se explica porque en el contrato las partes han podido *prever y distribuir* los riesgos, lo que no ocurre entre extraños. Grez extrae de aquí consecuencias para casi todas las clasificaciones del daño.

Requisitos del daño indemnizable

No todo menoscabo es indemnizable: para serlo, el daño debe reunir ciertos **requisitos**. **Boetsch** exige tres; **Rodríguez Grez** los desglosa en cinco, que en rigor coinciden y se complementan. Refundiendo ambas exposiciones, el daño indemnizable ha de ser:

- **(1) Cierto, no eventual ni hipotético.** El daño debe ser *real y efectivo*, en el sentido de que conste su existencia, aunque su monto no esté aún determinado. Lo que se excluye es el daño puramente *eventual o conjetural*, esto es, aquel cuya producción es incierta. **Grez** precisa que la certidumbre se refiere a la *existencia* del daño, no a su *cuantía*: un daño futuro puede ser cierto (la pérdida de ganancias que con seguridad se habrían obtenido) y, por tanto, indemnizable; lo que no se indemniza es el daño meramente posible. Esta exigencia es la que está en el centro del problema de la *pérdida de una chance*, que se examina más abajo.
- **(2) Directo.** El daño debe ser consecuencia *inmediata y necesaria* del incumplimiento (art. 1558). Los daños *indirectos* —los que sólo se conectan remota o mediatamente con el incumplimiento— no se indemnizan ni siquiera mediando dolo. Este requisito se confunde, en rigor, con la exigencia de relación de causalidad (requisito tercero), y por eso suele tratarse en ambos lugares.
- **(3) No reparado o no indemnizado todavía.** El daño cuya reparación se pide no debe haber sido ya satisfecho por otra vía. Aquí se inserta el problema del **cúmulo u opción de responsabilidades** y, más precisamente, el de la *compensación de beneficios* (*compensatio lucri cum damno*): si el mismo hecho que causó el daño reportó al acreedor algún beneficio, éste debe descontarse; y si el daño ya fue cubierto por un seguro u otra fuente, no puede pretenderse doble reparación, sin perjuicio de la subrogación del asegurador.
- **(4) Que lesione un interés legítimo del acreedor.** **Boetsch** exige que el daño afecte un *interés jurídicamente protegido*; no se indemniza la frustración de expectativas ilícitas o contrarias a derecho.
- **(5) Avaluable en dinero.** **Grez** añade expresamente este requisito: como la indemnización es siempre pecuniaria, el daño ha de ser susceptible de traducirse a una suma de dinero, sea directamente (daños patrimoniales), sea por vía de estimación prudencial (daño moral). Grez agrega que el daño puede ser *real o presuntivo*: junto al daño probado, la ley admite en ciertos casos daños que se presumen (por ejemplo, los intereses en las obligaciones de dinero del art. 1559, que se deben «aunque no se justifiquen perjuicios»).

Las clasificaciones del daño: el sistema decuple de Rodríguez Grez

Es en la **clasificación del daño** donde el tratado de **Rodríguez Grez** despliega su mayor originalidad y donde más conviene seguirlo, pues propone **diez pares clasificatorios** que exceden con creces las cuatro o cinco distinciones habituales de los manuales. Las enunciamos primero en bloque y desarrollamos a continuación las de mayor rendimiento, contrastándolas con la exposición de **Boetsch**. Para Grez, el daño puede ser: **(1)** real o virtual; **(2)** cierto o eventual; **(3)** directo o indirecto; **(4)** actual o futuro; **(5)** probado o presuntivo; **(6)** patrimonial o extrapatrimonial; **(7)** daño emergente o lucro cesante; **(8)** previsto o imprevisto; **(9)** compensatorio o moratorio; y **(10)** intrínseco o extrínseco.

(7) Daño emergente y lucro cesante (art. 1556)

Es la clasificación legal por excelencia y la primera que debe dominarse. El artículo **1556** dispone que «la indemnización de perjuicios comprende el *daño emergente* y el *lucro cesante*, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento». La distinción es la siguiente:

- El **daño emergente** es la *disminución efectiva y actual* del patrimonio del acreedor: aquello que *salió* o *dejó de estar* en su patrimonio a consecuencia del incumplimiento. Es la pérdida real, el empobrecimiento. Ejemplo: el valor de la cosa que no se entregó, o el costo de reparar lo defectuosamente ejecutado.
- El **lucro cesante** es la *ganancia o utilidad que el acreedor dejó de percibir* a consecuencia del incumplimiento; aquello que habría *entrado* en su patrimonio de haberse cumplido oportunamente la obligación. Es la frustración de un incremento patrimonial. Ejemplo: las rentas que el arrendador dejó de percibir, o las utilidades que el comprador de níquel (caso «Zorin») habría obtenido de revender el producto apto.

Grez conecta esta distinción con su noción de menoscabo *real* (que corresponde al daño emergente: una pérdida efectiva ya producida) y menoscabo *virtual* (que corresponde al lucro cesante: una ganancia que sólo virtualmente integraba el patrimonio). Por su naturaleza, el **daño emergente es más fácil de probar** —pues recae sobre realidades pasadas y constatables— mientras que el **lucro cesante exige un juicio de probabili-**

dad sobre lo que habría ocurrido, lo que lo aproxima al terreno de la *certidumbre* antes examinado. La regla general es que se indemnizan ambos; excepcionalmente la ley limita la reparación al daño emergente, como en el artículo **1556** mismo cuando una disposición especial lo dispone, o en ciertos contratos.

(3) Daños directos e indirectos (art. 1558)

El daño **directo** es el que constituye consecuencia *inmediata y necesaria* del incumplimiento; el daño **indirecto** es el que se sigue del incumplimiento sólo de un modo *remoto o mediato*, a través de una cadena de causas en la que intervienen otros factores. El artículo **1558** consagra la regla esencial: **los daños indirectos no se indemnizan nunca**, ni siquiera mediando dolo. La razón es de causalidad: el daño indirecto no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento, porque entre uno y otro se interponen causas independientes.

Ejemplo — Las vacas de Pothier

El célebre ejemplo de **Pothier**, que **Boetsch** recoge, ilustra la cadena causal. Un comerciante vende una vaca que sabe enferma de una peste contagiosa. La vaca contagia y mata al resto del ganado del comprador (*daño directo*): los animales muertos son consecuencia inmediata del incumplimiento. Al quedarse sin bueyes, el comprador no puede cultivar sus tierras (*¿daño directo o ya más remoto?*). Por no cultivar, no obtiene cosecha, no paga sus deudas y sus acreedores le embargan y rematan sus predios (*daño indirecto*): esta ruina final, aunque encadenada con la venta de la vaca enferma, obedece también a la situación financiera del comprador y a la decisión de sus acreedores, de modo que no puede imputarse al vendedor. La indemnización se detiene en el daño directo; el indirecto queda fuera, por más que históricamente derive del incumplimiento.

(8) Daños previstos e imprevistos (art. 1558)

Dentro de los daños *directos* —los únicos indemnizables— el artículo **1558** introduce una segunda distinción, esta vez ligada al **grado de impu-**

tación: el daño **previsto** es el que se previó o pudo preverse al tiempo del contrato; el daño **imprevisto** es el que, siendo directo, no era previsible al contratar. La regla es:

- Si el incumplimiento es **culpable** (culpa leve o levísima), el deudor responde *sólo de los perjuicios directos previstos*.
- Si el incumplimiento es **doloso** (o con culpa grave, asimilada al dolo), el deudor responde *de los perjuicios directos previstos e imprevistos*.

Ejemplo — Las castañas de El Cairo

Otro ejemplo clásico que **Boetsch** emplea para los perjuicios imprevistos: un comerciante encarga a un transportista llevar un cargamento de castañas a El Cairo para llegar antes que la competencia y vender a precio elevado. El transportista se retrasa culpablemente; al llegar, el mercado ya está abastecido y las castañas se venden a precio normal. El lucro *extraordinario* que el comerciante esperaba (vender primero a sobreprecio) es un **perjuicio imprevisto**: el transportista no podía representarse esa utilidad especial al contratar, de modo que sólo respondería de ella si hubiera actuado con dolo. Si sólo hubo culpa, responde del perjuicio *previsto* (el retardo ordinario), no del lucro extraordinario frustrado.

(6) Daño patrimonial y extrapatrimonial

El daño **patrimonial** recae sobre el patrimonio del acreedor, es decir, sobre bienes y derechos valuables en dinero, y se descompone —ya lo vimos— en daño emergente y lucro cesante. El daño **extrapatrimonial** o **moral** recae sobre intereses no pecuniarios: la integridad física y psíquica, el honor, los afectos, la tranquilidad espiritual. Por su importancia y por el tratamiento singular que le dedica **Rodríguez Grez**, el daño moral contractual se examina en epígrafe separado, a continuación de las restantes clasificaciones.

Las restantes clasificaciones de Grez

Grez completa su sistema con pares que, si bien se superponen parcialmente con los anteriores, aportan matices útiles:

- **(1) Real y virtual.** Ya explicado: el daño real es la pérdida efectiva ($\approx$ daño emergente); el virtual, la ventaja que sólo potencialmente integraba el patrimonio ($\approx$ lucro cesante). Es la distinción *matriz* del pensamiento de Grez y la que le permite sostener su tesis sobre el daño moral.
- **(2) Cierto y eventual.** El daño cierto es indemnizable; el eventual o meramente hipotético, no. Esta clasificación es el fundamento dogmático del problema de la *pérdida de una chance* (infra).
- **(4) Actual y futuro.** El daño actual es el ya producido al tiempo de la demanda o de la sentencia; el futuro es el que se producirá con posterioridad pero con certidumbre suficiente. **El daño futuro es indemnizable si es cierto** —no debe confundirse «futuro» con «eventual»—. El lucro cesante es, típicamente, un daño futuro cierto.
- **(5) Probado y presuntivo.** Por regla general el daño debe probarse (art. 1698; art. 173 CPC); excepcionalmente la ley lo presume, dispensando de prueba, como ocurre con los intereses del art. 1559 en las obligaciones de dinero, que se deben «aunque no se justifiquen perjuicios».
- **(10) Intrínseco y extrínseco.** Distinción fina de Grez: el daño *intrínseco* es el que afecta a la cosa misma objeto de la obligación o a su valor; el daño *extrínseco* es el que el incumplimiento causa en *otros* bienes o intereses del acreedor, distintos de la prestación. La distinción tiene rendimiento al delimitar el alcance de la previsibilidad del art. 1558: el daño intrínseco suele ser previsible, mientras que el extrínseco puede no serlo.
- **(9) Compensatorio y moratorio.** Reproduce, en clave de clasificación del daño, la distinción ya estudiada entre indemnización compensatoria (repara el incumplimiento mismo) y moratoria (repara el retardo). Véase la subsección 5.2.

El daño moral en la responsabilidad contractual

De todas las cuestiones del daño, ninguna ha sido tan debatida como la procedencia del **daño moral en sede contractual**, y en ninguna el aporte de **Rodríguez Grez** es más original y discrepante. Conviene exponer pri-

mero la evolución del problema —en la que coinciden Boetsch, Orrego y Grez— y luego la tesis propia de Grez, que el examinando debe conocer como el desarrollo doctrinal diferenciador de la materia.

De la negación a la admisión

La doctrina y la jurisprudencia **clásicas** negaban la indemnización del daño moral en materia contractual. Se argumentaba: **(i)** que el artículo **1556** sólo menciona el «daño emergente» y el «lucro cesante», ambos de índole patrimonial, sin aludir al daño moral, de modo que éste quedaría excluido; **(ii)** que el daño moral, por no afectar el patrimonio, no sería avaluable en dinero y su reparación importaría un enriquecimiento sin causa; y **(iii)** que en el contrato las partes negocian intereses económicos, no afectivos. Bajo esta concepción, el daño moral sólo se reparaba en sede extracontractual, al amparo del amplísimo artículo **2329**.

La doctrina y jurisprudencia **modernas** han abandonado esa posición y admiten hoy, sin discusión, la reparación del daño moral derivado del incumplimiento contractual. Los argumentos del giro —que **Boetsch y Orrego** recogen— son:

- **Argumento constitucional.** La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo **19** N.º 1 CPR) y el respeto y protección a la honra y a la vida privada (artículo **19** N.º 4 CPR). Negar la reparación del daño moral contractual dejaría sin tutela estos bienes cuando son lesionados a través del incumplimiento de un contrato (por ejemplo, en la responsabilidad médica, en el transporte de pasajeros, en los contratos de prestaciones de salud o educación), lo que pugna con la supremacía constitucional.
- **Argumento de igualdad reparatoria.** No se ve razón para que un mismo daño —el sufrimiento, la lesión a la integridad— se repare si proviene de un hecho ilícito extracontractual y no se repare si proviene del incumplimiento de un contrato. La distinción del régimen no debe traducirse en una desprotección de la persona.

- **Argumento de texto.** El artículo 1556 no *excluye* el daño moral; se limita a mencionar el daño emergente y el lucro cesante sin declarar que sean los únicos rubros. La enumeración no es taxativa en cuanto a la *naturaleza* del daño, sino descriptiva de sus formas patrimoniales más típicas.

Doctrina — La tesis de Rodríguez Grez: el daño moral contractual «deviene» daño material

Aquí **Grez** se aparta de la exposición uniforme de Boetsch y Orrego con una construcción propia que conviene dominar. Para Grez, el daño moral, *tratándose de la responsabilidad contractual*, no se indemniza como un menoscabo puramente afectivo o espiritual, sino en cuanto **«deviene» o se proyecta en un daño material**. Su razonamiento: el incumplimiento que afecta la integridad psíquica, el prestigio o el equilibrio del acreedor termina por *repercutir sobre su capacidad laboral, administrativa o intelectual*, esto es, sobre su aptitud para generar ingresos y administrar su patrimonio. De ese modo, el daño moral contractual se resuelve, en último término, en un **daño virtual y futuro** —una merma de las ganancias que el acreedor habría obtenido— que constituye, en rigor, **una manifestación del lucro cesante**. Grez no niega el daño moral contractual; lo *reconduce* a la lógica patrimonial del art. 1556, presentándolo como un menoscabo virtual de la capacidad de ganancia. Esta es la diferencia capital con Boetsch y Orrego, que admiten el daño moral contractual como categoría *autónoma* de carácter extrapatrimonial, sin necesidad de «materializarlo».

De esta tesis Grez extrae una consecuencia sobre la **naturaleza de la reparación**. Apoyándose en **Fueyo**, sostiene que la reparación del daño moral no es propiamente **compensatoria** —no «compensa» con dinero un dolor, pues el dolor no tiene precio— sino **satisfactiva**: la suma que se concede no equivale al daño (que es incommensurable), sino que procura al lesionado una *satisfacción* o compensación de otra índole, un alivio o reparación simbólica que mitigue el menoscabo. Grez invoca en su apoyo a la doctrina francesa —**Larroumet** y los hermanos **Mazeaud**—, que distingue entre el daño que puede ser exactamente compensado (patrimonial) y el que sólo admite una reparación satisfactoria (moral).

JURISPRUDENCIA — CS, 20 DE OCTUBRE DE 1994 (DAÑO MORAL ASIMILABLE A DAÑO EMERGENTE)

Grez cita este fallo como apoyo de su tesis. En su **considerando 13**, la Corte Suprema razonó que el daño moral, en sede contractual, resulta *asimilable al daño emergente*, en cuanto importa una disminución o menoscabo que debe ser reparado. La sentencia es uno de los hitos del giro jurisprudencial hacia la admisión amplia del daño moral contractual y, leída con Grez, sugiere la idea de que el menoscabo moral se traduce o «materializa» en un detrimento patrimonial reparable.

JURISPRUDENCIA — CA DE CONCEPCIÓN, 20 DE MAYO DE 2002 (PROCEDENCIA Y PRUEBA DEL DAÑO MORAL)

La Corte de Apelaciones de Concepción admitió la reparación del daño moral contractual y se pronunció sobre su prueba y evaluación, inscribiéndose en la línea que, a partir de los años noventa, consolidó la indemnizabilidad del daño moral derivado del incumplimiento. Grez la emplea para ilustrar el tratamiento práctico del rubro por los tribunales de alzada.

La prueba del daño moral

Admitida la procedencia, surge el problema de su **prueba**. La regla general es que el daño debe acreditarse (art. 1698; artículo **173** del Código de Procedimiento Civil, que permite reservar para la ejecución del fallo la discusión sobre la *especie y monto* de los perjuicios, probándose su *existencia* en el juicio declarativo). Respecto del daño moral, sin embargo, parte de la jurisprudencia lo tiene por establecido *in re ipsa* —se desprende de la naturaleza misma del hecho lesivo— mientras otra exige prueba efectiva del padecimiento. **Rodríguez Grez** propone, para acreditar y mensurar el daño moral, atender a **tres elementos**:

- **(1) La naturaleza de la obligación incumplida:** no es lo mismo el incumplimiento de un contrato de contenido puramente económico que el de un contrato que compromete bienes de la persona (salud, seguridad, educación). Cuanto más cerca está la obligación de los bienes personalísimos, más plausible es el daño moral.

- **(2) La gravedad del incumplimiento:** la intensidad y las circunstancias de la infracción (dolo, reiteración, indolencia) inciden en la entidad del padecimiento.
- **(3) Los efectos psíquicos del incumplimiento:** las repercusiones efectivas en la psiquis y en la vida del acreedor —angustia, deterioro de la salud, alteración de las condiciones de existencia—, que son las que, en la lógica de Grez, terminan por proyectarse sobre la capacidad de ganancia.

La valoración del daño moral: las seis doctrinas

El punto más espinoso es la **evaluación** del daño moral, pues no existe un parámetro objetivo de equivalencia entre dinero y dolor. **Grez** sistematiza **seis doctrinas o criterios** que se han propuesto para fijar el *quantum*:

- **(1) Doctrina que niega la reparación:** sostiene que el daño moral no es avaluable y que repararlo importa un enriquecimiento sin causa o una indebida «comercialización» del dolor. Es la posición clásica, hoy abandonada.
- **(2) Doctrina del arbitrio judicial:** entrega la determinación del monto a la *prudencia* del juez, que lo fija discrecionalmente según las circunstancias. Es la posición dominante en la práctica, aunque expuesta a la crítica de arbitrariedad y disparidad de criterios.
- **(3) Doctrina de la sanción ejemplar:** concibe la indemnización del daño moral como una *pena privada* dirigida a sancionar la conducta del deudor, más que a reparar a la víctima. Aproxima el daño moral a los *punitive damages* del derecho anglosajón.
- **(4) Doctrina de la satisfacción o compensación:** la que Grez hace suya con Fueyo; el dinero no equivale al dolor, sino que procura al lesionado una satisfacción sustitutiva que mitigue el menoscabo. La reparación es *satisfactiva*, no compensatoria en sentido estricto.
- **(5) Doctrina que atiende a parámetros o baremos objetivos:** propone tablas, tarifas o precedentes que estandaricen los montos según el tipo de lesión, en busca de previsibilidad e igualdad. Es la tendencia de varios ordenamientos comparados.

- **(6) Doctrina de la reconducción al daño patrimonial:** coherente con la tesis central de Grez, mide el daño moral por su *proyección* sobre la capacidad de ganancia y el patrimonio del afectado, esto es, como un lucro cesante virtual y futuro.

El daño moral en regímenes de responsabilidad objetiva

Grez añade una observación que suele pasar inadvertida: en ciertos regímenes de **responsabilidad objetiva** el propio legislador ha reconocido y *tarifado* el daño moral, lo que confirma su indemnizabilidad y ofrece un parámetro legal de valuación. El ejemplo paradigmático es el **Código Aeronáutico**, cuyos artículos **144**, **148** y **172** establecen un sistema de responsabilidad objetiva del transportador aéreo por muerte o lesiones de los pasajeros, con límites cuantitativos (expresados en unidades de fomento) que comprenden tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial. La existencia de estos baremos legales demuestra que el ordenamiento no sólo admite el daño moral, sino que en ámbitos de riesgo lo predetermina, acogiendo —en la clasificación antes vista— la doctrina de los parámetros objetivos.

La pérdida de una chance u oportunidad

Una figura de creciente relieve, situada justamente en la frontera del requisito de **certidumbre** del daño, es la **pérdida de una chance** (o pérdida de oportunidad). Se presenta cuando el incumplimiento no priva al acreedor directamente de un beneficio determinado, sino de la *probabilidad* de obtenerlo. El problema dogmático es delicado: si el beneficio final era incierto, indemnizar su valor íntegro vulneraría la exigencia de certidumbre (sería reparar un daño eventual); pero negar toda reparación dejaría sin tutela a quien efectivamente perdió una oportunidad valiosa. La solución, que la jurisprudencia chilena ha ido acogiendo, consiste en indemnizar *no* el beneficio final frustrado, sino la *chance misma* —la oportunidad perdida— valorada según la probabilidad que tenía de concretarse.

JURISPRUDENCIA — CS «ALPES CHEMIE S.A. CON CENABAST» (PÉRDIDA DE CHANCE, PRINCIPIOS DE 2025)

En una demanda por **falta de servicio**, Alpes Chemie reclamó de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) la rebaja indebida del puntaje de su oferta en una licitación de medicamentos, lo que —según la actora— le impidió adjudicarse el contrato. La Corte Suprema estimó que el actuar del demandado *no* produjo directamente la privación de la adjudicación, sino que hizo que la demandante **perdiera la oportunidad** de que su oferta fuese considerada una mejor candidata a adjudicarse la licitación. En consecuencia, **no concedió el lucro cesante** (la utilidad esperada de la adjudicación), sino que avaluó y concedió los perjuicios asociados específicamente a la **pérdida de oportunidad**. El fallo deja dos enseñanzas capitales:

(i) La pérdida de chance **no se enmarca** dentro de los tipos de perjuicio tradicionalmente reconocidos —daño emergente, lucro cesante y daño moral—, sino que constituye una *especie diversa* de daño. La Corte sigue así el criterio de fallos anteriores (Roles 154.662-2020 y 4989-2019).

(ii) El daño consistente en la pérdida de chance es **autónomo e independiente del resultado final esperado**. Por ello su evaluación, que debe hacerse *prudenter et in concreto*, ha de ser siempre **restringida**: el monto indemnizable no puede ser igual o equivalente al valor que se esperaba recibir de obtener el beneficio final, pues la obtención de ese beneficio es justamente lo incierto y eventual. No obstante, el valor del beneficio final sí es *útil como base de cálculo* de la reparación de la chance (típicamente, aplicando a ese valor el coeficiente de probabilidad que la oportunidad tenía de concretarse).

Dato de grado — Chance ≠ lucro cesante

No confundas la **pérdida de chance** con el **lucro cesante**. El lucro cesante repara una ganancia *cierta* que se dejó de percibir; la pérdida de chance repara la *probabilidad* frustrada de obtener un beneficio *incierto*. Por eso el monto de la chance es siempre *inferior* al del beneficio final: se obtiene ponderando el valor de ese beneficio por la probabilidad que existía de alcanzarlo. Memoriza la fórmula de la Corte: especie de daño *diversa* de las tres tradicionales, *autónoma* del resultado esperado, evaluación *restringida* y *prudenter et in concreto* (caso «Alpes Chemie con CENABAST»; Roles 154.662-2020 y 4989-2019).

5.6. Tercer requisito: la relación de causalidad

Para que el deudor responda no basta que haya incumplido culpable o dolosamente y que el acreedor haya sufrido un daño: es preciso, además, que entre el incumplimiento y el perjuicio exista una **relación de causalidad**, esto es, que el daño sea *consecuencia* del incumplimiento. La causalidad cumple una doble función: **fundar** la responsabilidad (sólo se responde del daño que se ha causado) y **delimitar** su extensión (sólo se responde hasta donde llega el nexo causal). En sede contractual, el Código exige este vínculo a través de varias normas, señaladamente el artículo **1556** —los perjuicios deben «provenir» del incumplimiento— y el artículo **1558** —que limita la reparación a los perjuicios que son «consecuencia inmediata o directa» del no cumplimiento.

Las teorías de la causalidad

La determinación de cuándo un hecho es «causa» de un daño ha dado lugar a varias teorías, elaboradas principalmente en sede penal y extracontractual pero aplicables, con matices, al ámbito contractual. **Boetsch** las expone así:

- **Teoría de la equivalencia de las condiciones (*conditio sine qua non*).** Todo hecho sin el cual el daño no se habría producido es causa de él; todas las condiciones son *equivalentes*. Para saber si un hecho es causa se aplica el método de la **supresión mental hipotética**: se suprime mentalmente el hecho y se observa si el daño igualmente se habría producido; si desaparece, el hecho es causa. Su defecto es la amplitud excesiva: conduce a una cadena causal infinita (*regressus ad infinitum*).
- **Teoría de la causa adecuada.** Corrige a la anterior: no toda condición es causa, sino sólo aquella que, según el curso *normal y ordinario* de las cosas, es *idónea* o *adecuada* para producir el daño. Se descartan las causas que sólo por azar o por circunstancias extraordinarias condujeron al resultado. Es la teoría más aceptada.
- **Teoría de la causa próxima o relevante.** Atiende a la condición *más cercana* o *más relevante* en la producción del daño, prescindiendo de las remotas.

- **Teoría de la imputación objetiva.** Planteamiento moderno que sustituye el problema puramente naturalístico de la causalidad por un juicio *normativo*: se imputa el daño al incumplimiento cuando éste creó o incrementó un *riesgo jurídicamente desaprobado* que se concretó en el resultado, y cuando el daño queda dentro del *ámbito de protección* de la norma o del contrato infringidos. Esta teoría, de creciente influencia, permite resolver con más finura los casos difíciles (daños por causas concurrentes, daños sobrevenidos, etc.).

Doctrina — La causalidad en sede contractual: supresión mental del incumplimiento

Boetsch precisa que, en materia contractual, la causalidad se verifica preguntándose si el daño se habría producido *de haberse cumplido* la obligación. Operativamente, se realiza la **supresión mental del incumplimiento**: si, suprimido hipotéticamente el incumplimiento (es decir, suponiendo que el deudor sí cumplió), el daño igualmente se habría producido, entonces el incumplimiento *no* es su causa y no hay responsabilidad; si, en cambio, el daño desaparece al suponer cumplida la obligación, el incumplimiento es causa y se responde. A este filtro causal se superpone, en el sistema chileno, el límite normativo del art. 1558 (sólo perjuicios *directos*) y la previsibilidad, que operan como criterios de imputación que *recortan* las consecuencias puramente naturales del incumplimiento.

La interrupción del nexo causal

El vínculo causal entre incumplimiento y daño puede **interrumpirse** cuando interviene una causa *extraña* que pasa a ser la verdadera generadora del perjuicio, exonerando total o parcialmente al deudor. **Boetsch** identifica como factores de interrupción del nexo causal —que se estudian con detalle en la Sección 6— el **caso fortuito o fuerza mayor**, el **hecho o culpa del acreedor** y el **hecho de un tercero**. El Código se refiere a estas hipótesis en diversas disposiciones que conviene tener presentes:

- El artículo **1547**, que exonera al deudor cuando el incumplimiento proviene de caso fortuito (salvo que se haya constituido en mora o que el caso fortuito sobrevenga por su culpa).

- El artículo **1558**, que al limitar la reparación a los perjuicios directos excluye, por falta de nexo, los daños indirectos.
- El artículo **1672**, que en la pérdida de la cosa distingue según medie o no culpa o mora del deudor, e ilustra el desplazamiento de la causa.
- El artículo **1677**, que permite al acreedor exigir la cesión de los derechos o acciones que el deudor tenga contra el tercero por cuyo hecho pereció la cosa, reconociendo así que la causa real fue el hecho del tercero.
- El artículo **1827**, en la compraventa, que pone de cargo del comprador en mora de recibir los riesgos de la cosa, ejemplo de interrupción por hecho del propio acreedor.

Cuando la causa extraña concurre *parcialmente* con el incumplimiento del deudor —por ejemplo, cuando el daño se debe en parte al incumplimiento y en parte a la negligencia del acreedor— procede la **reducción** proporcional de la indemnización, idea que el ordenamiento recoge expresamente para la responsabilidad extracontractual en el artículo **2330** (reducción por exposición imprudente de la víctima al daño) y que la doctrina extiende, por analogía, a la responsabilidad contractual.

5.7. Cuarto requisito: la mora del deudor

El último requisito de la indemnización es la **mora del deudor**. **Abeliuk** la define como «*el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación, unido al requerimiento o interpelación por parte del acreedor*». La mora no se confunde con el simple **retardo**: todo deudor que no cumple oportunamente está en retardo, pero sólo está en *mora* cuando ese retardo le es imputable y, además, el acreedor lo ha **interpelado** —le ha hecho saber que el incumplimiento le causa perjuicio—. El retardo es un hecho objetivo; la mora es una situación jurídica cualificada. La importancia del requisito es capital, pues el artículo **1557** dispone que «se debe la indemnización de perjuicios *desde que el deudor se ha constituido en mora*, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención».

Requisitos de la mora

Para que el deudor quede constituido en mora se requiere: **(1)** que haya *retardo* en el cumplimiento; **(2)** que el retardo sea *imputable* al deudor (dolo o culpa), pues el retardo por caso fortuito no constituye en mora; **(3)** que el acreedor *interpele* al deudor; y **(4)** —tratándose de contratos bilaterales— que el acreedor haya *cumplido o esté llano a cumplir* su propia obligación (art. 1552). Examinemos los dos elementos característicos: la interpelación y la regla «la mora purga la mora».

La interpelación (art. 1551)

La **interpelación** es el acto por el cual el acreedor manifiesta al deudor que el incumplimiento le ocasiona perjuicio. El artículo **1551** reconoce **tres formas** de interpelación, que constituyen otras tantas hipótesis de constitución en mora:

- **Interpelación contractual expresa (art. 1551 N.º 1).** El deudor está en mora «cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora». Aquí las partes han fijado un *plazo expreso* para el cumplimiento; vencido el plazo sin cumplir, el deudor queda automáticamente en mora, sin necesidad de requerimiento adicional. Rige el aforismo *dies interpellat pro homine* («el día interpela por el hombre»): el solo vencimiento del plazo estipulado interpela.
- **Interpelación contractual tácita (art. 1551 N.º 2).** El deudor está en mora «cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla». Es el caso en que, aunque no se ha pactado un *plazo expreso*, de la *naturaleza* de la prestación se desprende que sólo era útil dentro de cierto tiempo (el clásico ejemplo del vestido de novia encargado para la boda, o el toldo para una fiesta determinada). El plazo está tácitamente incorporado por la finalidad del contrato, y su transcurso interpela.

- **Interpelación judicial (art. 1551 N.º 3).** Regla *residual*: «en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor». Cuando no hay plazo expreso ni tácito, el deudor sólo se constituye en mora mediante la **reconvención judicial**, esto es, la notificación de la demanda en que el acreedor exige el cumplimiento. La doctrina mayoritaria entiende que basta la notificación de cualquier demanda dirigida a obtener el cumplimiento (o la resolución con indemnización), sin que se requieran fórmulas sacramentales.

Dato de grado — Las tres interpelaciones del art. 1551

Pregunta segurísima de examen: «¿Cuándo se constituye en mora el deudor?». Responde con los tres numerales del art. 1551: **N.º 1** interpelación contractual *expresa* (plazo estipulado; *dies interpellat pro homine*); **N.º 2** interpelación contractual *tácita* (plazo que emana de la naturaleza de la prestación); y **N.º 3** interpelación *judicial* (regla residual: reconvención judicial). Recuerda que el N.º 1 deja a salvo «los casos en que la ley exija requerimiento», y que en los contratos bilaterales debe sumarse el art. 1552.

«La mora purga la mora» (art. 1552)

En los contratos bilaterales opera la regla del artículo **1552**: «*En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos*». Es la llamada **excepción de contrato no cumplido** (*exceptio non adimpleti contractus*) en su proyección sobre la mora: el contratante que no ha cumplido ni está llano a cumplir su propia obligación **no puede constituir en mora** a su contraparte. Se dice gráficamente que «la mora purga la mora»: la mora de uno neutraliza la del otro. De aquí se sigue que el acreedor que pretende cobrar indemnización debe acreditar que él, a su vez, cumplió o está pronto a cumplir; de lo contrario, su contraparte no está en mora y no se debe indemnización. Esta regla se estudió ya, desde la perspectiva de la resolución, en la Sección 4, y debe manejarse de modo coordinado con el art. 1489.

Efectos de la mora

La constitución en mora del deudor produce **tres efectos** fundamentales:

- **(1) Hace nacer el derecho a la indemnización de perjuicios.** Conforme al art. 1557, los perjuicios —moratorios y, en su caso, compensatorios— se deben desde que el deudor está en mora. Antes de la mora, por regla general, no se debe indemnización (salvo las obligaciones de no hacer, en que se debe desde la contravención).
- **(2) Hace responsable al deudor del caso fortuito sobrevenido durante la mora.** Conforme a los artículos **1547** inc. 2.º y **1672** inc. 2.º, el deudor moroso responde incluso del caso fortuito que sobreviene estando en mora, a menos que pruebe que la cosa igualmente habría perecido en poder del acreedor de haberse cumplido oportunamente. La mora, pues, traslada al deudor el *riesgo* de la cosa.
- **(3) Invierte el riesgo en las obligaciones de especie o cuerpo cierto.** Como derivación de lo anterior, la pérdida fortuita de la especie debida durante la mora del deudor queda de su cargo (art. 1550 a contrario, en relación con el art. 1672).

La mora del acreedor

También el **acreedor** puede incurrir en mora cuando, sin justa causa, *se niega a recibir* la prestación que el deudor le ofrece, o no presta la cooperación necesaria para que el deudor pueda cumplir (*mora accipiendi*). El Código no la regula sistemáticamente, pero la reconoce en diversas disposiciones de las que la doctrina extrae su régimen:

- El artículo **1548**, que tras imponer al deudor de dar la obligación de conservar la cosa, presupone que el acreedor debe recibirla.
- El artículo **1680**, que atenúa la responsabilidad del deudor por la pérdida de la cosa cuando el acreedor se ha constituido en mora de recibir: el deudor sólo responde entonces de *culpa grave o dolo*.
- El artículo **1827**, que en la compraventa pone de cargo del comprador moroso de recibir los costos de conservación y aminora la responsabilidad del vendedor.

Los **efectos** de la mora del acreedor son, principalmente: **(i)** disminuir la responsabilidad del deudor, que pasa a responder sólo de culpa grave o

dolo en la conservación de la cosa (art. 1680); **(ii)** hacer recaer sobre el acreedor los *gastos de conservación y custodia* de la cosa cuya recepción rehúsa; y **(iii)** trasladar al acreedor el riesgo de la cosa. La mora del acreedor no extingue la obligación —para ello el deudor dispone del pago por consignación (arts. 1598 y ss.)—, pero altera sensiblemente la distribución de cargas y riesgos entre las partes.

5.8. Evaluación judicial de los perjuicios

Concurriendo todos los requisitos de la responsabilidad, resta determinar el **monto** de lo que el deudor debe pagar. Esta determinación puede hacerla la *ley*, el *juez* o las *partes*, y según quién la realice la evaluación se denomina **legal**, **judicial** o **convencional**. Como advierte Orrego, conviene fijar de entrada el alcance de cada una: la evaluación *legal* se refiere sólo a la indemnización *moratoria* de las obligaciones de dinero; la evaluación *judicial* y la *convencional* comprenden, en cambio, tanto la indemnización compensatoria como la moratoria. Comenzamos por la judicial, que es —en palabras de Orrego— «la forma más frecuente de evaluar los perjuicios» en la práctica.

La **evaluación judicial** es la que practica el juez, y tiene lugar *cada vez que las partes no han convenido el monto de la indemnización (cláusula penal) ni la ley lo ha regulado (obligaciones de dinero)*. Supone entablar una demanda que se tramita conforme al juicio que corresponda —ordinariamente, el juicio ordinario—, en la que el actor debe probar la existencia de la obligación, el incumplimiento (que hace presumir la culpa, art. 1547 inc. 3.º) y, sobre todo, la **existencia y el monto de los perjuicios**, pues éstos no se presumen (art. 1698).

Doctrina — El art. 173 del Código de Procedimiento Civil: la división de la discusión

Una regla procesal capital, que **Orrego** destaca, es la del artículo **173** del Código de Procedimiento Civil, que permite **dividir en dos etapas** la discusión sobre los perjuicios. Conforme a su inciso 1.º, cuando se ha litigado «sobre la especie y el monto» de los perjuicios, la sentencia debe determinar la cantidad líquida que ha de abonarse, o declarar sin lugar el pago si no resultan probados, o fijar «las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia». Y según su inciso 2.º, cuando *no* se ha litigado sobre la especie y monto, el tribunal «reservará a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso». Esto permite al acreedor obtener primero la *declaración* de la obligación de indemnizar — probando la *existencia* del daño— y diferir para una etapa posterior la discusión sobre su *cuantía*. La utilidad práctica es enorme: el acreedor no queda forzado a acreditar el monto exacto en el mismo juicio en que se discute la procedencia.

En cuanto a su **extensión**, la evaluación judicial comprende, por regla general, el **daño emergente y el lucro cesante** (art. 1556), pudiendo adicionarse el **daño moral** según la tendencia jurisprudencial ya analizada (véase la subsección 5.5, donde se desarrollan en detalle los rubros y sus límites). Recuérdese que el lucro cesante exige un *juicio de probabilidad* fundado en antecedentes reales y objetivos —no en meras conjeturas—, según la doctrina que la propia Corte de Apelaciones de Santiago precisó en su sentencia de 29 de noviembre de 2007 (Rol N.º 3.073-2003), al señalar que el lucro cesante «debe ser necesariamente cierto», aunque con una certeza «de carácter relativo» y no absoluta. Sobre la evaluación judicial pesan, además, los **límites del art. 1558** (sólo perjuicios directos; sólo previstos si el incumplimiento es culpable, también imprevistos si es doloso), de modo que la reparación judicial nunca es enteramente libre, sino que se mueve dentro del marco de reparación *limitada* propio de la responsabilidad contractual que destacaba Rodríguez Grez.

5.9. Evaluación legal (art. 1559)

La **evaluación legal** es la que hace directamente la *ley*, y opera en un único ámbito: el de las **obligaciones de dinero** —las que tienen por objeto el pago de una cantidad de dinero «en su origen»—, reguladas por el artículo **1559**. Orrego sintetiza sus **características**:

- **(1) Es supletoria y excepcional.** *Supletoria*, porque sólo se aplica a falta de pacto expreso (cláusula penal); *excepcional*, porque no rige para cualquier obligación, sino sólo para las de dinero en su origen.
- **(2) Corresponde únicamente a indemnización moratoria.** Como el objeto de la obligación ya es dinero, no cabe «compensar» el dinero con dinero: lo único que procede es indemnizar el *retardo*, lo que se hace agregando al capital los **intereses**. De ahí que la evaluación legal sea, por definición, moratoria.
- **(3) Los perjuicios se presumen.** El acreedor que cobra intereses *no necesita probar perjuicios* (art. 1559 regla 2.^a): basta el retardo para que se devenguen. Es una excepción a la regla general de que el daño debe probarse.
- **(4) Los perjuicios se traducen en «intereses».** El monto está constituido por tasas fijas —porcentajes sobre el capital— que son los intereses convencionales, corrientes o legales.

El régimen de los **intereses** debe leerse hoy en armonía con la **Ley N.º 18.010** sobre operaciones de crédito de dinero. Conviene distinguir las clases de interés:

- **Interés legal:** el fijado por la ley como tasa general. En Chile, por disposición del artículo 19 de la Ley N.º 18.010, el «interés legal» *equivale al interés corriente*: cada vez que las leyes se refieren al interés legal o al máximo bancario, se aplica el corriente.
- **Interés corriente:** el «promedio ponderado por montos de las tasas cobradas por los bancos establecidos en Chile», que determina y publica mensualmente la **Comisión para el Mercado Financiero** en el Diario Oficial (art. 6.º de la Ley N.º 18.010).

- **Interés convencional:** el estipulado por las partes, con el tope del **interés máximo convencional** (art. 6.º inc. final): no puede exceder la cifra mayor entre *1,5 veces* la tasa de interés corriente vigente al pactarse, y la tasa corriente *incrementada en dos puntos porcentuales anuales*. Si se estipula un interés superior al máximo, opera la sanción del artículo **2206** y de la Ley N.º 18.010: se rebaja al interés corriente.

De la regla 1.ª del artículo 1559 se desprende qué intereses se deben: **(i)** los *legales (corrientes)*, si nada se pactó para la mora, o si se estipularon intereses sin especificar su tasa, o en una tasa inferior a la legal; **(ii)** los *convencionales*, si se pactaron (con el tope del máximo convencional); y **(iii)** si los convencionales fueren inferiores al interés legal, se debe éste a partir de la mora (norma protectora del acreedor). La doctrina dominante entiende que los intereses corren sobre la *deuda líquida*, aunque un sector postula —para no premiar al deudor moroso— que deberían devengarse desde que la deuda se hizo exigible, aun siendo ilíquida.

Doctrina — El anatocismo: de la prohibición del Código a la admisión de la Ley 18.010

El **anatocismo** es el interés que producen los intereses devengados e impagos que se han incorporado al capital (interés sobre intereses). El Código Civil lo *prohibía*: el artículo **1559** N.º 3 dispone que «los intereses atrasados no producen interés», y el antiguo artículo 2210 vedaba estipular intereses sobre intereses. Sin embargo, esa prohibición **ya no rige**: el artículo 28 de la Ley N.º 18.010 derogó el art. 2210, y su artículo **9** *autoriza expresamente* el anatocismo, con ciertas restricciones. Más aún, en las operaciones regidas por esa ley el anatocismo se **presume** salvo pacto en contrario: «los intereses correspondientes a una operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporarán a ella, a menos que se establezca expresamente lo contrario». El examinando debe manejar el contraste: **regla del Código Civil (art. 1559 N.º 3): anatocismo prohibido; regla de la Ley 18.010 (art. 9): anatocismo permitido e incluso presumido** en las operaciones de crédito de dinero.

Finalmente, se discute si con el pago de los intereses moratorios se *agota* la indemnización por el retardo en el pago de una suma de dinero. Una

posición lo afirma; otra —que **Orrego** comparte— sostiene que el acreedor puede cobrar una cantidad *mayor* que la resultante de los intereses, con una salvedad: deberá *probar* esos perjuicios adicionales, conforme a la regla 2.^a del art. 1559 interpretada a contrario sensu (que dispensa de prueba *sólo* cuando se cobran intereses).

5.10. Evaluación convencional: la cláusula penal

La **evaluación convencional** es la que hacen las propias *partes*, anticipadamente, mediante la **cláusula penal**. El artículo **1535** la define: «*La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal*». **Orrego** la describe como el pacto en virtud del cual se estipula una prestación a cargo del deudor y en favor del acreedor, *representativa de la evaluación anticipada de los perjuicios* para el caso de incumplimiento en cualquiera de sus formas. Su gran ventaja es fijar de antemano el monto de los perjuicios, de modo que —por emanar de la voluntad de las partes (art. 1545)— prevalece sobre toda otra liquidación.

En cuanto a la **oportunidad** para pactarla, la ley no la fija, pero la doctrina entiende que puede convenirse al celebrar el contrato o con posterioridad, *siempre antes del incumplimiento*; si se estipulara *después* de infringida la obligación, estaríamos más bien ante una **transacción**.

Las tres funciones de la cláusula penal

Boetsch y **Orrego** coinciden en que la cláusula penal cumple **tres funciones**, que conviene distinguir con nitidez:

- **(1) Función de evaluación anticipada de los perjuicios.** Es su función primaria: las partes liquidan por adelantado el daño, evitando la evaluación judicial. De ello deriva una ventaja probatoria decisiva: acreditados la obligación y el incumplimiento, el juez debe condenar al pago de la pena *sin que el acreedor pruebe perjuicio alguno*, y sin que el deudor pueda alegar que el incumplimiento no le causó daño o le causó uno menor (art. **1542**).

- **(2) Función de caución o garantía.** La cláusula penal *asegura* el cumplimiento: se llama «penal» precisamente porque es una *pena* con que se amenaza al deudor para constreñirlo a cumplir. En cuanto caución, refuerza el vínculo y desincentiva el incumplimiento.
- **(3) Función de pena civil.** Puede operar como sanción del incumplimiento, dotando al acreedor de una acción de la que carecería de otro modo. Así, el artículo **1472** permite al acreedor de una *obligación natural* accionar contra el tercero que la caucionó con cláusula penal, aunque carezca de acción contra el principal obligado.

Naturaleza jurídica y características

La cláusula penal es una **obligación accesoria y condicional**. Es *accesoria* porque depende de una obligación principal cuyo cumplimiento garantiza; es *condicional* porque su exigibilidad pende de un hecho futuro e incierto —el incumplimiento de la obligación principal—, que opera como condición suspensiva, expresa, potestativa y negativa. De su carácter accesorio derivan tres reglas (art. **1536**):

- **(i)** La nulidad de la obligación principal *acarrea* la de la cláusula penal (lo accesorio sigue la suerte de lo principal).
- **(ii)** La nulidad de la cláusula penal *no* acarrea la de la obligación principal (lo principal no sigue la suerte de lo accesorio).
- **(iii)** La pena será divisible o indivisible según lo sea la obligación principal.

El artículo 1536 contempla, además, dos hipótesis aparentemente excepcionales en que la pena vale pese a no obligarse el «principal»: **(a)** la *promesa de hecho ajeno* (art. **1450**), en que quien promete que un tercero dará, hará o no hará algo se sujeta a una pena que vale aunque el tercero no resulte obligado (pues no ha ratificado); y **(b)** la *estipulación en favor de un tercero* (art. **1449**), en que quien se obliga ante el estipulante puede sujetarse a una pena para el caso de no cumplir lo prometido al beneficiario. En rigor —observa la doctrina— no son verdaderas excepciones, porque en ambos casos la pena garantiza la obligación *propia* del promitente (de obtener la ratificación o de hacer cumplir lo prometido), no la del tercero.

Doctrina — La cláusula penal como evaluación anticipada: cuatro consecuencias

Del carácter de *evaluación anticipada* de los perjuicios, **Orrego** extrae cuatro consecuencias capitales: **(i)** habiendo cláusula penal, no puede exigirse *conjuntamente* la pena y la indemnización ordinaria, salvo pacto expreso (arts. 1537 y 1543); **(ii)** la exigibilidad de la pena se rige por las mismas reglas que la de toda indemnización (requiere mora); **(iii)** si el incumplimiento proviene de *caso fortuito*, no hay lugar al pago de la pena (pues no hay imputabilidad); y **(iv)** no puede acumularse la obligación principal y la pena —no pueden exigirse ambas— porque ello importaría un doble pago, salvo las excepciones del art. 1537.

Exigibilidad y acumulación

La pena se hace **exigible** desde que el deudor es constituido en *mora* (obligaciones positivas) o desde que *contraviene* la obligación (obligaciones de no hacer). Constituido en mora el deudor, el acreedor adquiere un **derecho alternativo**: puede demandar, a su arbitrio, o la obligación principal o la pena (art. **1537**). Esto constituye una excepción a la regla general de la indemnización compensatoria —que ordinariamente debe pedirse en subsidio del cumplimiento o la resolución—, pues aquí el acreedor puede optar derechamente por la pena.

Las reglas de **acumulación** son las siguientes:

- **No se acumulan la obligación principal y la pena** (art. **1537**), salvo: **(a)** que la pena se haya estipulado por el *simple retardo* (pena moratoria, que se suma a la obligación principal); o **(b)** que se haya pactado expresamente que el pago de la pena *no* extingue la obligación principal (pena compensatoria acumulable por pacto). También procede la acumulación cuando la ley la autoriza, como en la transacción (art. **2463**).

- **No se acumulan la pena y la indemnización ordinaria** (art. **1543**): el acreedor debe optar entre cobrar la pena (con la ventaja de no probar perjuicios) o demandar la indemnización ordinaria (probando los perjuicios efectivos, eventualmente mayores), salvo estipulación expresa que permita sumarlas. Esto revela que la cláusula penal es una *garantía* para el acreedor, pero *no limita* la responsabilidad del deudor: si los daños reales superan la pena, el acreedor puede desentenderse de ella y cobrar la indemnización ordinaria.

Cumplimiento parcial, prueba y divisibilidad de la pena

Tres reglas complementan el régimen: **(a)** si el deudor cumple *parcialmente* y el acreedor acepta ese cumplimiento, el deudor tiene derecho a que se **rebaje proporcionalmente** la pena (art. **1539**); la jurisprudencia ha discutido si la rebaja es discrecional o estrictamente proporcional a la parte cumplida. **(b)** Estipulada la pena, se **presume el perjuicio**: aunque el daño sea ínfimo o inexistente, el deudor no se libera del pago (art. **1542**); como dijo un fallo de la Corte de Santiago de 1958, «resulta superfluo investigar siquiera si dicho incumplimiento ocasionó perjuicios al acreedor». **(c)** En cuanto a la **divisibilidad** entre herederos (art. **1540**): si la obligación principal era divisible, la pena se divide entre los herederos a prorrata de sus cuotas, de modo que sólo puede demandarse la pena al heredero que incumplió su parte; pero si se pactó indivisibilidad de pago, o la obligación era indivisible por naturaleza, el acreedor puede exigir toda la pena al heredero que impidió el cumplimiento total, o a cada uno su cuota, con acción de reembolso de los inocentes contra el infractor. El artículo **1541** agrega que, si la pena está garantizada con hipoteca, puede perseguirse *toda* la pena en el inmueble, como consecuencia de la indivisibilidad de la acción hipotecaria.

La cláusula penal enorme (art. 1544)

Como la cláusula penal puede prestarse a abusos —imponiendo al deudor penas desorbitadas—, el artículo **1544** autoriza su **reducción** cuando es *enorme*, esto es, cuando existe una desproporción considerable entre la obligación principal y la pena. La norma distingue **tres clases de contratos**, con un régimen propio para cada uno:

- **(1) Contratos conmutativos en que la obligación principal y la pena consisten en pagar una cantidad determinada (art. 1544 inc. 1.º).** Aquí la pena no puede exceder el **duplo** de la obligación principal, «incluyéndose ésta en él»; el exceso sobre ese duplo se rebaja. La doctrina mayoritaria (Alessandri, Somarriva, Abeliuk, Claro Solar, Fueyo) interpreta que la pena *no puede superar el doble* de la obligación principal: si la deuda es de \$10.000.000, la pena máxima es \$20.000.000. Una posición minoritaria entiende que podría llegar a \$30.000.000 (el doble *más* la obligación principal). **Abeliuk** defiende la primera tesis razonando que, como por regla general no se acumulan principal y pena, el legislador quiso que el máximo de la pena fuera el doble de la obligación, quedando la suma principal *incluida* en ese duplo.
- **(2) El mutuo (art. 1544 inc. 3.º).** Tratándose de un mutuo, se rebaja la pena «en lo que exceda al máximo del interés que es permitido estipular». Aquí **Orrego** advierte una incongruencia con el artículo 8.º de la Ley N.º 18.010: el art. 1544 rebaja el interés excesivo al *máximo convencional*, mientras que la Ley 18.010 lo rebaja al *interés corriente*. La solución: si se trata de un mutuo de *dinero* (o de saldos de precio de compraventa, art. 26 de la Ley 18.010), se aplica la Ley 18.010 y el interés se reduce al *corriente*; si se trata de un mutuo de cosas fungibles que no sean dinero (regido por el Código Civil), la pena se rebaja al *máximo convencional*.
- **(3) Obligaciones de valor inapreciable o indeterminado (art. 1544 inc. final).** Como la ley no puede fijar un tope, se entrega «a la prudencia del juez» moderar la pena cuando, atendidas las circunstancias, «pareciere enorme» —lo que equivale a fallar conforme a la *equidad natural*—. El ejemplo clásico es el de la antigua sentencia de la Corte de Talca que redujo a \$1.000 una pena consistente en la mitad de una herencia, estipulada por un abogado para el caso de revocársele el poder. También se ha aplicado a la obligación del arrendador de entregar la cosa y a multas diarias desproporcionadas por la restitución tardía del inmueble (CS, octubre de 1990).

Dos precisiones jurisprudenciales finales: la rebaja de la pena **no puede oponerse como excepción** en el juicio ejecutivo (no cabe en el art. 464 del CPC), sino que debe hacerse valer mediante la *acción* correspondiente —típicamente, reconvención si la acción del acreedor es ordinaria—; y

el derecho a pedir la reducción es **irrenunciable**, porque el art. 1544 «no consulta el interés individual de los deudores sino un objeto de conveniencia pública», de modo que admitir su renuncia frustraría el propósito de la ley.

Dato de grado — Los tres casos del art. 1544

Memoriza el esquema de la cláusula penal enorme: **(1) contratos conmutativos** con obligación y pena en cantidad determinada → tope del *duplo* de la obligación principal; **(2) mutuo** → rebaja al *máximo del interés permitido* (matizado por la Ley 18.010, que reduce al *interés corriente* en el mutuo de dinero); **(3) obligaciones de valor inapreciable o indeterminado** → *prudencia del juez* (equidad). Recuerda también: la reducción es **irrenunciable** (conveniencia pública) y debe pedirse por *acción*, no como excepción ejecutiva. Y no olvides el art. 1539 (rebaja proporcional por cumplimiento parcial), que es un caso distinto de reducción.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 5 — La indemnización de perjuicios**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Presta especial atención a: la *perpetuatio obligationis* y la naturaleza de la indemnización; la distinción compensatoria/moratoria y sus reglas de acumulación; el debate sobre la autonomía (tesis tradicional, moderna y la posición matizada de Boetsch, con los fallos «Zorin» y «Santo Tomás»); los cuatro requisitos (imputabilidad —dolo y culpa, graduación del art. 44, presunción del art. 1547 inc. 3.º—, perjuicio, causalidad y mora —las tres interpelaciones del art. 1551—); la teoría del daño de **Rodríguez Grez** (las diez clasificaciones, el daño moral que «deviene» daño material, la reparación satisfactiva y la pérdida de chance); y las tres formas de evaluación (judicial, legal del art. 1559 con el anatocismo, y convencional o cláusula penal, incluida la cláusula penal enorme del art. 1544).

6. CAUSALES DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Desarrollado a lo largo de las secciones anteriores el régimen del incumplimiento y de sus remedios —cumplimiento forzado, resolución e indemnización de perjuicios—, corresponde ahora examinar el reverso de la moneda: **aquellas circunstancias que liberan al deudor del deber de respon-**

der. La pregunta que articula esta sección es una sola y muy precisa: producido objetivamente el incumplimiento, ¿en qué casos puede el deudor sustraerse a la responsabilidad civil que de él derivaría? Conviene tener presente que no toda causal opera del mismo modo: algunas *extinguen* la obligación (la pérdida fortuita de la especie debida), otras se limitan a *eximir de responsabilidad* dejando subsistente el vínculo (el caso fortuito temporal), y otras, en fin, son meras *defensas* que la doctrina debate y que la jurisprudencia ha recibido con desigual entusiasmo.

Tradicionalmente, la doctrina ha sostenido que **la única causal de exención de responsabilidad sería el caso fortuito o la fuerza mayor**. Adicionalmente, algunos autores agregan la **ausencia de culpa**. Una doctrina más minoritaria suma otras causales como el **estado de necesidad**, el **hecho ajeno**, la **teoría de la imprevisión** y la **frustración del fin del contrato**. Todas ellas se analizarán en este capítulo, advirtiendo desde ya —con **Boetsch**— que estas últimas «han tenido escasa (y en algunos casos nula) acogida por la jurisprudencia nacional».

No confundir — eximir de responsabilidad y extinguir la obligación

Conviene separar dos planos que el examinador suele cruzar. **Eximir de responsabilidad** significa que, pese a no haberse cumplido, el deudor no queda obligado a indemnizar: la prestación primitiva puede subsistir (si el impedimento es transitorio) o haberse extinguido por otra vía. **Extinguir la obligación**, en cambio, es hacer desaparecer el vínculo mismo: es lo que ocurre cuando la especie o cuerpo cierto debido perece por caso fortuito (**1670**). El caso fortuito, como veremos, puede producir *ambos* efectos según su carácter sea temporal o permanente; las demás causales, por regla general, sólo operan en el plano de la responsabilidad.

6.1. El caso fortuito o la fuerza mayor

Como consideración preliminar, y siguiendo a **Boetsch**, es necesario advertir que —de acuerdo con cierta doctrina— el Código Civil regula **dos clases de caso fortuito** según sean los efectos que produzca en el cumplimiento:

- **El caso fortuito permanente**, que opera como *modo de extinguir la obligación* por pérdida de la cosa que se debe o imposibilidad absoluta de ejecución del hecho debido. Ejemplo: la destrucción de la especie específica que se debía.
- **El caso fortuito temporal**, que opera como *eximente de responsabilidad* y no como modo de extinguir, porque, terminado el caso fortuito, sí debe cumplirse. Ejemplo: se destruye el camino que necesariamente debía tomar el deudor para entregar la cosa debida; en tal caso, no responde por el retraso en el cumplimiento, pero debe entregar la cosa una vez que se haya reparado el camino.

Esta distinción —que reaparecerá al estudiar los efectos— es la clave de bóveda de toda la institución y explica por qué un mismo concepto puede ser, a la vez, defensa frente a la indemnización y modo de extinción.

6.1.1. Concepto

El artículo 45 lo define diciendo que «se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.». Nuestro Código, a diferencia de otros ordenamientos, emplea como **sinónimos** «fuerza mayor» y «caso fortuito», sin atribuir a cada expresión un origen distinto (interno o externo).

Es generalmente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que, conforme a dicha definición, el caso fortuito se configura como un hecho que debe ser **imprevisible** e **irresistible**, a lo que se agrega además que debe tratarse de un hecho **ajeno al deudor**, cuestión que se desprende del artículo 1547 inciso segundo del mismo Código. Tenemos, así, los tres requisitos clásicos que el examinador exige enunciar sin vacilación: *ajenidad, imprevisibilidad e irresistibilidad*.

JURISPRUDENCIA — CORTE SUPREMA (CONCEPTO DE IMPREVISTO E IRRESISTIBLE)

La jurisprudencia reciente ha «conceptualizado el hecho imprevisto como aquel que la razón humana no puede determinar si se ha de realizar o no, al tiempo que entiende como hecho irresistible aquel cuyas consecuencias no han sido posible evitar ni eludir por no haber medios para impedirlos». Profundizando esas nociones, se ha resuelto que «la naturaleza imprevista se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia, es decir, haber adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y aun así, ser imposible para el agente contrarrestarlo»; por su parte, el carácter irresistible «se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos».

Por su parte, la doctrina —representada aquí por **Brantt**— afirma que «el hecho será ajeno cuando no constituya un riesgo que según el contrato corresponda al deudor»; es decir, corresponde a un hecho que afecta el cumplimiento de la obligación comprometida por el deudor y que escapa de los medios y recursos materiales o personales que debía utilizar para cumplir dicha obligación. Nótese que la ajenidad no se mide en abstracto, sino *en función del contrato*: lo decisivo es la distribución de riesgos que el propio negocio supone.

6.1.2. Elementos o requisitos del caso fortuito

Los elementos del caso fortuito son, entonces, que se trate de un hecho **ajeno al deudor, imprevisto e irresistible**. Es importante destacar que la forma de determinar la efectiva imprevisibilidad e irresistibilidad de un hecho se sustenta en un **juicio en abstracto**, por medio del cual se compara la conducta efectiva del agente con un patrón de conducta estándar que sirve como punto de comparación —el buen padre de familia, el hombre razonable—, de forma tal que pueda dilucidarse si una persona razonable, premunida de las mismas capacidades técnicas y enfrentada a las mismas circunstancias externas que el agente, habría podido prever y resistir el hecho que se invoca como caso fortuito.

Por su parte, la carga de acreditar que un hecho efectivamente constituye caso fortuito recae en el **deudor** de la obligación: el artículo **1547** inciso tercero dispone que incumbe «la prueba del caso fortuito al que lo alega».

a) Hecho ajeno (o inimputable)

Este requisito —que para ciertos autores consiste en que el hecho sea «inimputable», noción algo más restringida— consiste en que la circunstancia que lo configura se encuentre **fuera del ámbito de riesgos asumidos por el deudor** en el contrato, de forma tal que, si se produce un incumplimiento asociado a tales causas, en palabras de **Brantt**, «el deudor no podrá alegar su exención de responsabilidad. Ello, porque no se trata de un riesgo ajeno a él conforme al contrato, y por lo tanto, no puede configurar un caso fortuito a su respecto».

Se debe tratar, pues, de un hecho ajeno al deudor: no debe provenir de su hecho o culpa, ni del hecho o culpa de las personas por quienes él responde. Así resulta de numerosas disposiciones: artículos **934**, **1547** inc. 2.º, **1590**, **1672** inc. 1.º, **1679**, **1925** inc. 1.º, **1926** inc. 1.º, **2015** inc. 3.º, **2016** inc. 2.º, **2178** N.º 2, **2242**, entre otras.

Ejemplo — el comerciante que vende lo que no tiene (Abeliuk)

En Francia se ha fallado que un comerciante que vende a plazo mercaderías que él no tiene debe daños e intereses si una fuerza mayor le impide hacerlas venir lo suficientemente rápido como para entregarlas dentro de plazo. No hay caso fortuito por **faltar la inimputabilidad**: es culpable la conducta del deudor de ofrecer mercaderías de que no disponía. **Abeliuk** presenta este ejemplo como un caso de *falta de previsión*: el vendedor debió prever la dificultad. El impedimento, en rigor, no le era ajeno, sino que provenía de su propia imprudencia al comprometerse.

b) Hecho imprevisto

Que el hecho sea imprevisto significa que, dentro de los cálculos ordinarios de un hombre normal, **no era dable esperar su ocurrencia**. De la **Maza** define los acontecimientos imprevistos como aquellos poco frecuentes, que por excepción suelen sobrevenir, y que no han sido tomados en cuenta por las partes al momento de contratar.

JURISPRUDENCIA — CORTE SUPREMA (IMPREVISIBILIDAD; LA SEQUÍA)

La Corte Suprema ha dicho que «el caso fortuito es imprevisto cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización». De ahí que se haya fallado que «la sequía no constituye en sí misma un caso fortuito, ya que ella es insuficiente para eximirse de responsabilidad si se considera que en períodos de escasez de recursos hídricos, como sucede frecuentemente en nuestro país, es posible la generación a niveles normales de energía hidroeléctrica y aun sustituir el faltante mediante la generación termoeléctrica». El criterio es nítido: un fenómeno *recurrente y esperable* en nuestra geografía no puede invocarse como imprevisto.

c) Hecho irresistible

Se entiende que un evento resulta irresistible cuando, dispuestos todos los medios razonables para evitar su ocurrencia o sus efectos dañosos, éstos se verifican igualmente. El carácter irresistible redunda en dos perspectivas distintas: que el hecho sea **inevitable** —esto es, que física o jurídicamente no sea posible evitar su ocurrencia— y que sus **consecuencias sean irresistibles** —a saber, que no puedan razonablemente eliminarse o aminorarse por parte del deudor—.

JURISPRUDENCIA — LA DILIGENCIA QUE «INTEGRA LA PRESTACIÓN»

Se ha resuelto que «el deudor, con la diligencia necesaria, debe superar toda clase de impedimentos u obstáculos —incluso imprevisibles al tiempo de contratar— que incidan en la ejecución de la obligación. Tratándose de estos impedimentos u obstáculos imprevisibles al tiempo del contrato, como ocurre en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, la diligencia requerida integra la prestación, imponiendo al deudor una actividad que no tuvo cómo prever inicialmente y, consiguientemente, unos costos adicionales. El límite de esta diligencia y de la actividad que se puede esperar del deudor está representado por la *irresistibilidad* de las consecuencias del impedimento u obstáculo. Este límite permite unir la responsabilidad civil por daños con la exoneración de la misma por caso fortuito o de fuerza mayor (artículos 1547 y 45). El deudor incumplidor responde mientras no pruebe que su incumplimiento tuvo por causa un hecho constitutivo de caso fortuito, que se define concretamente, según sea su diligencia exigible».

Dato de grado — los tres requisitos, siempre

Ante cualquier pregunta sobre caso fortuito, parta enunciando los **tres requisitos**: hecho **ajeno** al deudor (art. 1547 inc. 2.º), **imprevisto** (art. 45) e **irresistible** (art. 45). Agregue de inmediato que la prueba incumbe al que lo alega (art. 1547 inc. 3.º) y que el juicio de previsibilidad/irresistibilidad se hace *en abstracto* (buen padre de familia). Esa estructura de cuatro trazos —tres requisitos más carga probatoria— vale tantos puntos como el desarrollo posterior.

6.1.3. Efectos del caso fortuito

El efecto propio del caso fortuito es **liberar de responsabilidad al deudor**. Así lo dice el artículo **1547** inc. 2.º: «el deudor no es responsable del caso fortuito»; y lo reitera el artículo **1558** inc. 2.º: «la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios».

En opinión de **Vial**, es necesario advertir que el caso fortuito presenta una **doble naturaleza jurídica**:

- **(i) Como circunstancia que impide imputar la infracción al deudor.** Ello se traduce en la imposibilidad en que se encuentra el acreedor de exigir indemnización de perjuicios. En este evento, si bien el caso fortuito hace imposible cumplir la obligación, *no la extingue*, porque se supone que el obstáculo es temporal o transitorio y que, una vez que desaparece, la obligación puede cumplirse, sin que el deudor contraiga responsabilidad por el cumplimiento tardío.
- **(ii) Como elemento esencial de un modo de extinción** denominado pérdida de la cosa debida o imposibilidad absoluta de ejecución. Aquí, a diferencia del punto anterior, se trata de un caso fortuito de efectos *permanentes* y no transitorios, por lo que no sólo exime de responsabilidad, sino que además *extingue la obligación*.

En definitiva, en la responsabilidad contractual el caso fortuito constituye, en primer lugar, un **eximente de responsabilidad**: exime al deudor de su deber de indemnizar los perjuicios surgidos de su incumplimiento (total o parcial) si éste se ha producido por causa del caso fortuito. Así resulta del artículo **1547** inc. 2.º —«el deudor no es responsable del caso fortuito, a

menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa»— y del artículo **1558**.

En segundo término, el caso fortuito constituye una **forma de extinguir** obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, que el Código trata bajo la denominación de «la pérdida de la cosa que se debe». El artículo **1670** dispone que «cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación»; pero dicha extinción tiene lugar únicamente cuando la cosa debida perece por caso fortuito (**1672**). La ley presume, en todo caso, que la cosa que perece en poder del deudor lo hace por hecho o culpa suya (**1671**), obligándolo a probar el caso fortuito (**1674**).

6.1.4. Excepciones: casos en que el caso fortuito no libera de responsabilidad

El principio de que el caso fortuito exime de responsabilidad reconoce **cuatro excepciones**, en las cuales el deudor responde no obstante el hecho fortuito:

- **1. Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor.** Así lo señala el artículo **1547** inc. 2.º, y aplican este principio los artículos **1590** inc. 1.º (caso fortuito como eximente) y **1672** inc. 2.º (caso fortuito como modo de extinguir). En verdad, si el hecho proviene de la culpa del deudor, resulta impropio hablar de caso fortuito, pues el hecho le sería imputable.
- **2. Cuando sobreviene durante la mora del deudor.** Así lo dice el artículo **1547** inc. 2.º, y lo reiteran los artículos **1590** inc. 1.º y **1672**. Esta excepción *no rige* si el caso fortuito igualmente hubiere sobrevenido en caso de que el acreedor hubiere tenido en su poder la cosa debida (arts. **1547** inc. 2.º, **1590** inc. 1.º y **1672** inc. 2.º): la mora no agrava la responsabilidad si el daño se habría producido de todos modos.
- **3. Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito.** Ello puede establecerse en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, según los artículos **1547** inc. final, **1558** inc. final y **1673**.

- **4. Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor** (art. **1547** inc. final). Así ocurre, por ejemplo, respecto del que ha hurtado o robado una cosa (**1676**). Otro caso es el contemplado para el colono — arrendatario de predio rústico— en el artículo **1983** inc. 1.º, en cuanto «no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios, que han deteriorado o destruido la cosecha».

6.1.5. Prueba del caso fortuito

Los artículos **1547** inc. 3.º y **1674** establecen que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega. Estas disposiciones constituyen una aplicación de la regla general de *onus probandi* del artículo **1698**, según el cual corresponde la prueba de la extinción de una obligación al que alega esta circunstancia. Constituye una excepción a la regla el artículo **531** del Código de Comercio (ex art. 539), relativo al contrato de seguro, en cuanto dispone que «el siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador».

6.2. La ausencia de culpa

La segunda causal de exoneración de responsabilidad del deudor sería —empleamos deliberadamente el condicional, pues no es generalmente aceptada— la **ausencia de culpa**. El problema dogmático puede formularse en una pregunta sencilla y de honda repercusión práctica: *¿le basta al deudor probar que ha empleado la debida diligencia para liberarse de responsabilidad, o debe probar además la existencia del caso fortuito?*

La doctrina no es uniforme. La **Corte Suprema** ha dicho que le basta al deudor acreditar que ha empleado el cuidado a que lo obligaba el contrato, sin que sea necesario probar el caso fortuito. La discusión, como se ve, no es bizantina: si se exige la prueba del caso fortuito, el deudor que simplemente fue diligente pero no puede identificar la causa precisa de su incumplimiento queda condenado; si basta la ausencia de culpa, ese mismo deudor se libera.

Abeliuk opina que es suficiente con que el deudor pruebe su ausencia de culpa, sobre la base de tres argumentos:

- **a)** La redacción del artículo **1547** inc. 3.º, que contrapone las dos situaciones —prueba de la diligencia o cuidado, y prueba del caso fortuito—. Explica que «si el deudor no se libera sino ante este último, carecería de objeto que probara su diligencia o cuidado».
- **b)** El artículo **1670** establece, sin distinción alguna, que si la cosa perece se extingue la obligación del deudor. La excepción aparece más adelante, en el artículo **1672**, al señalar que si ello ha ocurrido por culpa o durante la mora del deudor la obligación subsiste, pero varía de objeto (la indemnización de perjuicios). Luego, si no ha habido culpa ni mora, no hay excepción y se aplica la regla del artículo 1670, quedando la obligación extinguida.
- **c)** Si conforme al artículo **1678**, cuando la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación sólo se lo obliga a pagar el precio sin indemnización de perjuicios, con mayor razón, si hay un hecho involuntario y no culpable del deudor, éste debe quedar exento de responsabilidad.

En sentido contrario, **Claro Solar** sostiene que «la imputabilidad cesa cuando la inejecución de la obligación o la demora en su ejecución es el resultado de una causa extraña al deudor, o sea, de fuerza mayor o caso fortuito»; para esta posición, sólo el caso fortuito —y no la mera ausencia de culpa— libera al deudor.

Doctrina — el trasfondo: obligaciones de medio y de resultado

El debate se ilumina si se lo conecta con la distinción entre obligaciones de medio y de resultado. En las **obligaciones de medio** —donde lo debido es la diligencia misma— probar que se obró con el cuidado debido equivale a probar el cumplimiento, de modo que la ausencia de culpa basta naturalmente. En las **obligaciones de resultado**, en cambio, el deudor promete un resultado concreto, y la sola diligencia no satisface la prestación: por eso la tesis de Claro Solar (exigir el caso fortuito) calza mejor con ellas. La aparente contradicción doctrinal se atenúa, así, según el tipo de obligación de que se trate.

6.3. El estado de necesidad

Bajo el rótulo de «otras supuestas causales de exención», cierta doctrina nacional agrega el estado de necesidad, el hecho ajeno, la teoría de la imprevisión y la frustración del fin del contrato. Con todo, conviene reiterar que tales causales «han tenido escasa (y en algunos casos nula) acogida por la jurisprudencia nacional». Comenzamos por el estado de necesidad.

El **estado de necesidad** se configura por el hecho de que el deudor queda liberado de responsabilidad en el caso en que, **pudiendo cumplir, no lo hace para evitar un mal mayor**. Se diferencia del caso fortuito en que aquí *no hay un impedimento insuperable*: el deudor podría cumplir, pero opta por no hacerlo sacrificando la prestación para conjurar un daño más grave.

Ejemplo — el capitán del barco (Fueyo)

Fueyo propone varios ejemplos; el más célebre es el del capitán del barco que, en peligro de naufragar, lanza al mar las mercaderías que transporta para aligerar la nave y salvarla. ¿Debe responder frente al dueño de las mercaderías? El deudor *podía* conservar la carga —no había imposibilidad—, pero la sacrificó para evitar un mal mayor (la pérdida de la nave y de las vidas a bordo). He aquí, en estado puro, el problema del estado de necesidad.

La doctrina no es unánime. **Abeliuk** cree que, para quedar exento de responsabilidad, tiene que configurarse una *fuerza mayor*; estima que, si no se configura un caso fortuito, el deudor debe cumplir, ya que no hay disposición alguna en que pueda asilarse el estado de necesidad como eximente autónomo. Pero la **tendencia moderna** es que el estado de necesidad legitima el hecho y lo convierte en lícito, liberando de responsabilidad al deudor.

El Código Civil, en un caso, toca el punto **desechando** el estado de necesidad: es la situación del comodatario que, en un accidente, puesto en la alternativa de salvar la cosa prestada o la propia, opta por esta última (art. **2178** N.º 3). La norma hace responsable al comodatario, lo que se explica porque éste responde hasta de la *culpa levísima* —el comodato cede en exclusivo beneficio suyo—. El argumento *a contrario* es sugerente: si la

ley necesitó decir expresamente que el comodatario responde pese al estado de necesidad, es porque, de no mediar esa norma, podría haberse eximido.

6.4. El hecho o culpa del acreedor

Nuestro Código no ha reglamentado en forma orgánica la **mora del acreedor** (*mora accipiendi*), pero se refiere a ella en varias disposiciones para exonerar de responsabilidad al deudor. La idea de fondo es elemental: si el incumplimiento o el deterioro de la cosa obedece al propio hecho o culpa del acreedor —señaladamente, a su negativa o tardanza en recibir—, sería contrario a toda lógica hacer responsable al deudor.

- En el artículo **1548**, a propósito de las obligaciones de dar, se libera de responsabilidad al deudor por el cuidado de la especie o cuerpo cierto debido cuando el acreedor se ha constituido en mora de recibir.
- En el artículo **1680** se repite la misma idea, haciendo responsable al deudor sólo por *culpa grave o dolo* cuando media mora del acreedor en recibir.
- En el artículo **1827**, en la compraventa, se exige al vendedor del cuidado ordinario de conservar la cosa si el comprador se constituye en mora de recibir.

De estas disposiciones la doctrina extrae los efectos de la mora del acreedor: **atenúa la responsabilidad del deudor** —que pasa a responder sólo de dolo o culpa grave—, lo **libera de los gastos** de conservación y custodia y, según la opinión mayoritaria, **traslada al acreedor el riesgo** de la pérdida fortuita de la cosa. El hecho o culpa del acreedor opera, así, como una genuina causal de exención (total o parcial) de la responsabilidad del deudor.

6.5. El hecho ajeno (de un tercero)

Para determinar la responsabilidad del deudor que incurre en incumplimiento por hecho o culpa de un tercero es preciso distinguir si es civilmente responsable por él o no. La distinción es capital y suele preguntarse:

- **Por regla general, la intervención del tercero es para el deudor un caso fortuito**, siempre que reúna los requisitos propios de éste: imprevisibilidad e irresistibilidad. Por ello el artículo **1677** —que suele citarse como un caso de acción oblicua— establece que el acreedor puede exigir que el deudor le ceda los derechos y acciones que tenga contra el hechor. Lo mismo dispone el inciso final del artículo **1590** para el caso de deterioros.
- **Pero el hecho del tercero por el cual el deudor es civilmente responsable se considera hecho suyo**. Así lo dispone el artículo **1679**: «en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable». Nos hallamos, pues, ante un caso de *responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno*, tal como ocurre en la responsabilidad extracontractual.

Sin embargo, el legislador no dijo en el artículo 1679 —a diferencia de lo que hace el artículo **2320** en sede extracontractual— **quiénes son estos terceros** por los cuales el deudor es civilmente responsable. En los contratos en particular, en cambio, enumera varios casos: artículos **1925**, **1926**, **1929**, **1941**, **1947** inc. final, **2000** inc. 2.º, **2014**, **2015** inc. final, **2003** regla 3.ª, **2242** y **2243**. La regla práctica es nítida: el hecho del *auxiliar* o dependiente de quien el deudor se vale para cumplir no es para él un caso fortuito, sino hecho propio que compromete su responsabilidad.

6.6. La teoría de la imprevisión

Llegamos al punto más debatido y jurisprudencialmente más vivo de toda esta sección. En aquellos contratos de **tracto sucesivo**, en que las obligaciones de las partes se van cumpliendo durante períodos prolongados, puede ocurrir que durante la vida del contrato **sobrevengan hechos imprevistos y graves que hagan para una de ellas excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones**. La pregunta que cabe formular —y que vertebró toda la institución— es si en tal supuesto puede el afectado recurrir a la justicia para que se revise el contrato y se restablezca el equilibrio patrimonial. *Si aceptamos esta posibilidad, estamos aceptando la teoría de la imprevisión.*

6.6.1. Las dos posiciones: *pacta sunt servanda* frente a *rebus sic stantibus*

Frente a estos graves desequilibrios en las prestaciones de cada parte, hay en doctrina dos posiciones encontradas.

Para una **primera posición**, todo contrato es ley para las partes, que ninguna de ellas puede desconocer aunque hayan variado las condiciones bajo las cuales lo celebraron. Lo acordado tiene que cumplirse en la forma convenida (*pacta sunt servanda*); la seguridad jurídica así lo exige. Ello implica no aceptar la revisión de los contratos y, por ende, el rechazo de la teoría de la imprevisión.

Para una **segunda posición** —que tuvo su origen en el Derecho Canónico y que cobró mucha fuerza después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de los fenómenos económicos que de ella derivaron—, debe admitirse, por razones de equidad y de moralidad, la revisión de los contratos cuando varían gravemente, y por causas imprevistas, las condiciones bajo las cuales el contrato fue acordado. Contraponen al *pacta sunt servanda* el principio *rebus sic stantibus*. Dicen los sostenedores de esa posición que «en cada contrato se puede considerar como subentendida una cláusula tácita *rebus sic stantibus*, según la cual las partes no quedarán obligadas a sus prestaciones recíprocas sino en el caso de que las circunstancias generales existentes al tiempo de obligarse subsistan en el mismo estado hasta la ejecución completa de la obligación». Y ello porque «cada parte, al establecer las cláusulas del acto, sólo pensó y sólo pudo pensar en los riesgos normales que podrían ocurrir, y de acuerdo con esto formuló sus condiciones. Los acontecimientos anormales, imprevisibles, no han podido entrar en sus puntos de vista».

De la Maza define la teoría de la imprevisión como aquella doctrina jurídica —conjunto de principios de derecho debidamente fundados— que sostiene que «el juez puede intervenir, a petición de cualquiera de las partes, en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos, cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de formarse el vínculo jurídico, ajenos a su voluntad y que producen perturbación grave con relación a toda una categoría de contratantes, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa, y siempre que aquél llegue a formarse la convicción de que, siendo previsibles estas perturbaciones, las partes no se habrían obligado en las condiciones fijadas».

6.6.2. Requisitos

En doctrina se afirma que, para que opere la teoría de la imprevisión, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

- **1. Que se trate de un contrato de tracto sucesivo o, por lo menos, de ejecución diferida.** «La teoría de la imprevisión tiene necesariamente que suponer obligaciones que tengan duración en el tiempo, prestaciones sucesivas o diferidas o que no estén completamente ejecutadas. De otro modo no es posible concebir que sobrevengan acontecimientos imprevisibles, y esto es de la esencia de la imprevisión.»
- **2. Que por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes y no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones.**
- **3. Que los hechos que producen la alteración sean tan extraordinarios y graves** que, si las partes los hubieran tenido a la vista al momento de contratar, no habrían contratado, o lo habrían hecho en condiciones diferentes.

No confundir — imprevisión, caso fortuito y fuerza mayor

El deslinde es decisivo y suele ser el corazón de la pregunta. El **caso fortuito** hace *imposible* el cumplimiento; la **imprevisión** no lo impide, sino que lo torna *excesivamente oneroso*: el deudor *puede* cumplir, pero a un costo ruinoso. Por eso el caso fortuito *exime* o *extingue*, mientras que la imprevisión, donde se acepta, conduce a la *revisión* o *resolución* del contrato para restablecer el equilibrio. Confundir ambas figuras —invocar caso fortuito cuando lo que hay es excesiva onerosidad— es, como veremos, un error que la Corte Suprema ha sancionado expresamente.

6.6.3. ¿Tiene cabida en Chile? Casos legales de aceptación y de rechazo

A diferencia de otros países —por ejemplo, Argentina—, en Chile **no existe una consagración expresa** de la teoría de la imprevisión, sin perjuicio de que es posible observar casos puntuales en que la propia ley la acepta y otros en que, por el contrario, en forma expresa la rechaza.

La **acepta**, por ejemplo, en el artículo **2003**, regla 2.^a, en el contrato para la construcción de edificios por un precio único prefijado (contrato de empresa): «si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse el recargo de la obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda». Otros ejemplos de disposiciones que acogerían la teoría serían: el artículo **1496**, que admite la caducidad del plazo por causas sobrevinientes; el artículo **2180**, que en el comodato autoriza para pedir la restitución anticipada de la cosa prestada si surge para el comodante una necesidad imprevista y urgente; el artículo **2227**, que en el depósito acepta que el depositario pueda anticipar la devolución de la cosa si ésta peligró o le causa perjuicios; y el artículo **2348**, que permite al acreedor exigir fianza al deudor cuya ausencia del territorio nacional se tema y que carezca de bienes suficientes para la seguridad de la obligación.

En otros casos, **la rechaza expresamente**. Así ocurre en el mismo artículo **2003**, regla 1.^a: «el empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales». Y lo mismo sucede en el artículo **1983**, en el arrendamiento de predios rústicos: «el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha» (inc. 1.^o).

Dato de grado — el «par» del art. 2003

El artículo **2003** es un regalo para el examinador porque contiene, en dos reglas contiguas, la *aceptación* (regla 2.^a: vicio oculto del suelo → revisión judicial del precio) y el *rechazo* (regla 1.^a: encarecimiento de jornales o materiales → no hay aumento) de la imprevisión. Memorice el contraste: lo **imprevisible y oculto** (el suelo) se revisa; el **riesgo ordinario del mercado** (precios de insumos) lo soporta el empresario.

6.6.4. Los proyectos de ley

Han existido proyectos de ley que buscan consagrar la teoría de la imprevisión en nuestro ordenamiento. Uno de ellos es el proyecto «que permite

la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles» (**Boletín N.º 309-07-1**), que data de 1991, consta de cinco artículos, y cuyo artículo 1.º inc. 1.º señala: «Los contratos civiles y mercantiles, bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida, podrán ser revisados judicialmente si la prestación se hubiere convertido, por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente gravosa de ser cumplida. En tal evento, el tribunal estará facultado para modificar las cláusulas respectivas, restableciendo la equivalencia de las prestaciones existente al momento de contratar».

Un segundo proyecto, más reciente y originado por la falta de tramitación del anterior, fue presentado en 2017 (**Boletín N.º 11.204-07**) y pretende incorporar al Código Civil una serie de nuevos artículos —**1546** bis, ter, quáter, quinquies y sexies— que reglamenten la «revisión judicial de los contratos», estableciendo una *acción de revisión* en favor del contratante perjudicado para los contratos «bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo», cuando la prestación se hubiere convertido, «por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente gravosa de ser cumplida». Que ambos proyectos hayan sido necesarios confirma la premisa: *a falta de norma expresa, la imprevisión no tiene reconocimiento general en el Código vigente*.

6.6.5. La discusión doctrinal: rechazo mayoritario y argumentos de aceptación

El problema se presenta, naturalmente, en aquellas situaciones en que **no hay un pronunciamiento legal**. La generalidad de la doctrina **rechaza** la imprevisión, fundada en el *efecto obligatorio de los contratos* (art. **1545**) y, además, en una razón de política jurídica: si las partes supieran que tienen el camino abierto para una posterior revisión del contrato, los deudores inescrupulosos tendrían un pretexto más para eludir o postergar su cumplimiento en largos pleitos. A ello se agrega que la jurisprudencia tradicional señaló que los tribunales carecen de facultades para derogar o dejar sin cumplimiento la ley del contrato, ya sea por razones de equidad, de costumbre o de reglamentos administrativos.

Sin perjuicio de lo anterior, existe cierta doctrina que, fundada en normas y principios generales, entiende que la teoría de la imprevisión **sí tiene cabida** en nuestro ordenamiento, cuestión que ha sido muy aisladamente

aceptada por algunos fallos. Entre los argumentos esgrimidos a favor de la aceptación se cuentan:

- **a) El artículo 1560.** Si para interpretar un contrato debe estarse a la intención de los contratantes más que a lo literal de las palabras, cabe presumir que lo querido por las partes al contratar fue la mantención del contrato en el entendido de que no varíen sustancialmente las condiciones existentes en ese momento. Por ello, si por causas imprevisibles se produce un cambio significativo de esas condiciones, debe procederse a la revisión.
- **b) El artículo 1546,** que obliga a cumplir los contratos de buena fe. Sería contrario a esa buena fe que una de las partes pretenda que la otra cumpla en condiciones excesivamente onerosas, que rompen el equilibrio patrimonial y que fatalmente la llevarán a la ruina.
- **c) El deber de cuidado.** Toda persona, al contratar, contrae un determinado deber de cuidado; si cambian las condiciones, pasaría a asumir un riesgo que va más allá del que aceptó al momento de contratar.
- **d) El artículo 1558 inc. 1.º.** Como por regla general el deudor sólo responde de los perjuicios previstos, si las condiciones cambian violentamente por circunstancias imprevisibles y se mantiene el contrato tal como fue convenido, vendría a resultar que se estaría respondiendo de perjuicios *imprevistos*.

6.6.6. La evolución jurisprudencial

Si bien durante largo tiempo nuestros tribunales rechazaron enérgicamente la aplicación de la teoría de la imprevisión —fundados principalmente en el artículo 1545—, en las últimas décadas cierta jurisprudencia arbitral comenzó a acogerla, tímidamente.

JURISPRUDENCIA — CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2006, ROL 6812-2001 (EL PRIMER FALLO ORDINARIO)

La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que nuestro ordenamiento sí aceptaba la aplicación de esta teoría sobre la base de los artículos **1545, 1546, 1547, 1558, 1560, 1568** y **1444**, todos del Código Civil, en lo que constituye el **primer fallo emanado de los tribunales ordinarios** en este sentido. Razonó la Corte que, si bien de la simple lectura del artículo 1545 pareciera emanar la inmutabilidad absoluta del contrato, el análisis no puede abortarse de inmediato, pues «la teoría de la imprevisión no es, en ningún caso, un peligro para tal principio». Tratándose de un acto jurídico bilateral que reporta beneficio para ambas partes, era el cuidado de un buen padre de familia el que debían emplear, y ese es el único comportamiento exigible. No pudiendo calificarse el contrato sino como oneroso y conmutativo, «la equivalencia en las prestaciones resulta fundamental, por cuanto dicha característica es un elemento de la naturaleza de ese tipo de contrato, de manera que, al alterarse la equivalencia en las prestaciones, se lesiona el contrato mismo, situación que permite consecuentemente su revisión».

Con todo, esa apertura no se ha consolidado. Dos sentencias recientes de la Primera Sala de la **Corte Suprema**, dictadas a propósito de los efectos contractuales del estallido social y de la pandemia de COVID-19, fijan con nitidez el estado actual de la cuestión y, leídas en conjunto, ofrecen el mejor mapa del problema: una *cierra* la puerta a la imprevisión cuando se la disfraza de caso fortuito; la otra *la entreabre* con cautela, sólo respecto de prestaciones accesorias y por la vía de la buena fe.

JURISPRUDENCIA — CORTE SUPREMA, 11 DE MARZO DE 2025, ROL N.º 217.959-2023 (REDACCIÓN DEL ABOGADO INTEGRANTE ÁLVARO VIDAL OLIVARES)

En «Constructora Pardo y González», sobre un contrato de construcción no escriturado cuya obra se ejecutó parcialmente (80-85%), los demandados invocaron **caso fortuito o fuerza mayor** (estallido social y pandemia) para excusar su incumplimiento. La Corte advirtió que los demandados «yerran al fundamentar la excusa, no en la circunstancia de verse impedidos de cumplir, sino que en la excesiva onerosidad de la ejecución íntegra de la prestación»: conforme a la diligencia promotora exigible, el cumplimiento *era posible*, aunque a un costo mayor. Y de ahí la frase que conviene memorizar: «al presentar las cosas de esta manera, la alegación de caso fortuito o fuerza mayor **esconde una de imprevisión o alteración sobrevenida de las circunstancias, excusa que, mientras no se modifique el Código Civil, no tiene cabida en nuestro derecho de contratos**». Agregó tres precisiones de gran valor sistemático: (i) que, aun de concurrir el caso fortuito, la liberación habría sido *transitoria* —cesada la irresistibilidad, renace la exigibilidad de la prestación—; (ii) que, si el incumplimiento es *esencial*, el acreedor conserva la facultad resolutoria del artículo **1489** (citando CS, 21 de noviembre de 2024, Rol N.º 230.406-2023); y (iii) que el caso fortuito, según el artículo **1547** inc. 2.º, sólo habría exonerado del deber de *indemnizar*, no del deber de cumplir.

JURISPRUDENCIA — CORTE SUPREMA, 15 DE JULIO DE 2024, ROL N.º 161.630-2023 («INMOBILIARIA EL BOSQUE CON CASAMPERE»)

Arrendamiento de un sitio industrial; la arrendataria dejó de pagar las rentas desde marzo de 2020 por las restricciones sanitarias y el contrato terminó luego por mutuo acuerdo. La arrendadora cobraba las rentas devengadas y una multa moratoria de 0,5 UF por día de atraso (cláusula 3.^a). La Corte distinguió: respecto de las **rentas** —obligación esencial cuyo riesgo de los actos de autoridad la propia arrendataria había asumido en la cláusula 7.^a—, no cabía revisión ni rebaja (arts. **1924** y **1932**), y la reconvencción de terminación o rebaja fue rechazada. Pero respecto de la **multa moratoria** —prestación *no esencial*—, la Corte razonó que un «hecho sobreviniente, ajeno a la voluntad de las partes, que sin haber sido posible de prever produce un desequilibrio tal en sus prestaciones que el cumplimiento importa ahora un desembolso exagerado» se enmarca en «lo que la doctrina denomina la teoría de la imprevisión, o de excesiva onerosidad sobreviviente», recogiendo la definición de **Abeliuk**. Concluyó que los tribunales «se encuentran premunidos de la facultad de examinar si se ha visto afectado el equilibrio económico de las prestaciones» propias de un contrato conmutativo, y que la multa, devenida «altamente desproporcionada y desprovista de equidad y justicia», no podía exigirse «sin atentar contra la conmutatividad del contrato», sin que ello infrinja el artículo **1545** «al formar dicho equilibrio parte precisamente del convenio». Reforzó la decisión con el artículo **1546** y la *doctrina de los actos propios* (citando a Inés Pardo de Carvallo y a Díez-Picazo): la arrendadora, que venía negociando con la arrendataria desde marzo de 2020 y conocía sus dificultades, no podía después cobrar una multa diaria sin contradecir su propia conducta (*venire contra factum proprium*).

Doctrina — cómo leer juntas ambas sentencias

El contraste es más fino de lo que sugiere el rótulo «acoge / rechaza». La sentencia de 2025 (**Vidal Olivares**) cierra la puerta a la imprevisión *como tal*: no tiene cabida mientras no se reforme el Código, y menos puede colarse disfrazada de caso fortuito. La de 2024 no contradice ese principio: *no* revisa la obligación esencial (las rentas) ni invoca la imprevisión como acción autónoma, sino que neutraliza una *prestación accesorio* (la multa) por la vía de la **buena fe** (art. 1546) y los **actos propios**, apoyándose además en que su exigencia rompía la conmutatividad que «forma parte del convenio» (art. 1545). El mensaje combinado para el grado es claro: la revisión por excesiva onerosidad **no se acepta como institución general y autónoma**; cuando los tribunales corrigen un desequilibrio sobreviniente lo hacen, con extrema cautela, anclados en la buena fe, en la conmutatividad y en los actos propios, y normalmente sobre prestaciones secundarias.

Dato de grado — la respuesta segura sobre imprevisión

Si le preguntan si la teoría de la imprevisión rige en Chile, responda en este orden: **(1)** no hay consagración general expresa; **(2)** la doctrina mayoritaria la rechaza por el art. 1545 (fuerza obligatoria); **(3)** hay casos legales puntuales de aceptación (art. 2003 regla 2.^a, arts. 1496, 2180, 2227, 2348) y de rechazo (art. 2003 regla 1.^a, art. 1983 inc. 1.^o); **(4)** la minoría la defiende con los arts. 1546, 1560 y 1558; **(5)** la jurisprudencia la abrió tímidamente (CA Santiago, 2006, Rol 6812-2001), pero la Corte Suprema, en 2025 (Rol 217.959-2023), reafirmó que «mientras no se modifique el Código Civil, no tiene cabida», sancionando además su uso encubierto bajo el ropaje del caso fortuito. Cierre mencionando los dos proyectos de ley (Boletines 309-07 y 11.204-07) como prueba de que su recepción general exigiría reforma legal.

6.7. La frustración del fin del contrato

La **frustración del fin del contrato** se configura cuando, en un contrato bilateral, oneroso, conmutativo y que no sea de ejecución instantánea, la fi-

nalidad particular perseguida por uno de los contratantes se ve malograda absolutamente por un hecho imprevisible que no debía soportar, debiendo determinarse de qué manera habrá de cumplirse la obligación correlativa de la que es deudor, en circunstancias de que el contrato ya no le presta ningún beneficio, no obstante poder ser llevada a cabo igual.

Como expresa el jurista español **Diez-Picazo**, por «fin del contrato» debe entenderse «el propósito a que el contrato sirve dentro de la vida real, vale decir, el resultado empírico o práctico que, en orden a los peculiares y propios intereses, se pretende alcanzar». De ahí que el mismo autor hable de «una pérdida de sentido y de razón de ser de la prestación», toda vez que la utilidad que la misma rendía, por un hecho imprevisible y extrínseco al riesgo que debe soportar, ha quedado amagada: el interés real en el contrato ha muerto, no obstante que objetivamente puede realizarse. Esta finalidad individual —la utilidad específica que el cocontratante persigue mediante la convención—, cuando se encuentra *expresada* en ella, no es indiferente y determina la producción de consecuencias jurídicas.

No confundir — frustración del fin e imprevisión

Si bien es clara la afinidad entre ambas teorías, existe una diferencia precisa que el examinador valora: mientras la **imprevisión** se ocupa del destino del contrato frente a circunstancias que *encarecen* el cumplimiento de las prestaciones de una de las partes, la **frustración del fin** se aboca a una hipótesis más reducida —la suerte del contrato cuando una de las partes *pierde todo interés* en su acreencia, perviviendo el deber de cumplir la obligación contraída—. En la imprevisión la prestación sigue interesando, pero cuesta demasiado; en la frustración la prestación ya no interesa, aunque pueda ejecutarse sin dificultad. El ejemplo escolar es el del balcón arrendado para ver un desfile que finalmente se cancela: el arriendo es perfectamente cumplible, pero ha perdido su razón de ser.

En general, la doctrina indica que los **presupuestos** necesarios para que opere la frustración del fin del contrato son los siguientes:

- **a) Que el contrato sea bilateral**, puesto que sólo así la frustración absoluta e imprevisible del interés de un cocontratante puede afectar el curso de la ejecución ulterior del contrato. Si fuese unilateral, y el acreedor no debiera observar ninguna obligación correlativa, no habría estímulo para demandar el cumplimiento y no quedarían dudas que despejar.
- **b) Que el contrato sea oneroso**. Ambas partes deben tener interés en el contrato para que pueda hablarse con propiedad de frustración del fin: si sólo lo tiene el acreedor, la pérdida sobrevenida de la utilidad simplemente lo motivará a desestimar el cumplimiento.
- **c) Que el contrato sea conmutativo**. La frustración será relevante en esta categoría, pues la valoración que cada parte hizo en función del interés que la convención les reportaba, hecha al perfeccionarse el contrato, se ve quebrantada por una alteración imprevisible que malogra el interés particular de uno de los contratantes.
- **d) Que el contrato sea de ejecución diferida o tracto sucesivo**, pues en los contratos de ejecución inmediata no existe un intervalo de tiempo dentro del cual puedan mudar las circunstancias existentes al nacer la convención.
- **e) Que el beneficio de una de las partes se haya frustrado y las obligaciones del contrato sean objetivamente realizables**. La peculiaridad de esta figura es, justamente, que las obligaciones nacidas de la convención *pueden todavía ejecutarse*, pese a que para uno de los sujetos la utilidad del derecho personal se ha difuminado por una causa sobreviniente.
- **f) Frustración absoluta y perpetua del interés del cocontratante afectado**. No es cualquier alteración la que legitima reclamar estos efectos: todo contrato supone un marco de riesgo delineado primero por la voluntad de las partes y, en su silencio, por la ley, debiendo distinguirse si el riesgo corresponde a la parte que pierde el interés o si permite alegar la frustración del fin.

- **g) Que la frustración sea inimputable a las partes e imprevisible.** Es imprescindible que la mutación de circunstancias no sea consecuencia de una conducta dolosa o culposa de ninguno de los cocontratantes, pues principios severos del Derecho Privado —la prohibición de aprovecharse del propio dolo o torpeza, y el principio de responsabilidad— impiden esta hipótesis.

Tampoco respecto de la frustración del fin existe en Chile una **consagración expresa**, sin perjuicio de casos puntuales en que la propia ley la acepta. Un primer caso es el artículo **1932**, que confiere al arrendatario derecho a la terminación del arrendamiento —y aun a la rescisión— «si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada», y, si el impedimento es parcial, faculta al juez para decidir, según las circunstancias, entre la terminación o una rebaja del precio o renta. Esta regla es congruente con el artículo **1924** N.º 2, que impone al arrendador la obligación de mantener la cosa en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. Un segundo caso es el artículo **52** de la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, que permite al autor dejar sin efecto el contrato de edición si, transcurridos cinco años de estar la edición en venta, el público no hubiere adquirido más del 20% de los ejemplares. Y un tercero, incorporado por la **Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías** (vigente en Chile desde el 1.º de marzo de 1991): su artículo **79.1** establece como causal de exención el que se frustre la expectativa económica para cualquiera de las partes, en tanto el evento que afecte la utilidad del crédito haya sido imprevisible e inevitable según el grado de diligencia comprometido.

Fuera de esas disposiciones expresas, en general la doctrina estima que en Chile esta teoría **no tiene cabida**. Como señala **Ríos**, el artículo **1547** dispone que, para fijar la extensión del cuidado que comporta cada obligación, debe estarse a un criterio económico legalmente establecido: según la utilidad que el contrato brinde a cada parte se fija el grado de cuidado —oscilando entre la culpa grave y la levísima, y centrándose en la culpa leve (buen padre de familia, art. **44**) si la utilidad es compartida—. Siendo así, no puede demandarse a quien responde de culpa leve —como ocurre con el cocontratante en la frustración del fin— nada que exceda el nivel de actividad comprometido según el beneficio que le reporte la convención: un hecho imprevisible e inimputable no autoriza a exigirle más

allá del límite de la conducta debida. Hay que remarcar, además, que la frustración del fin del contrato **no libera a la parte perjudicada de cumplir sus obligaciones**: debe seguir cumpliendo las anteriores al evento frustrante y, con posterioridad, sus demás deberes contractuales, quedando eximida sólo de aquello que sobrepase el nivel de actividad determinado por la utilidad perseguida —fronteras todas fijadas por los artículos **1545** a **1550**, en especial el que distribuye los niveles de diligencia según la utilidad económica del contrato—.

Dato de grado — el panorama de las causales «menores»

Para las cuatro causales discutidas (estado de necesidad, hecho ajeno, imprevisión y frustración del fin), tenga lista una frase de cierre: *son causales de elaboración doctrinal, sin consagración general, recibidas sólo en casos legales puntuales y con escasa o nula acogida jurisprudencial*. Distinga siempre la causal **indiscutida** (caso fortuito, arts. 45 y 1547) de las **discutidas**, y recuerde que la frustración del fin se diferencia de la imprevisión en que aquí el cumplimiento es posible y barato, pero *inútil*.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 6 — Causales de exención de responsabilidad**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Presta especial atención a: los **tres requisitos** del caso fortuito (ajeno, imprevisto, irresistible —arts. 45 y 1547—), su prueba (art. 1547 inc. 3.º) y su *doble naturaleza* según Vial (eximente / modo de extinguir, arts. 1670-1674); las **cuatro excepciones** en que el caso fortuito no libera; el debate sobre la **ausencia de culpa** (Abeliuk vs. Claro Solar) y su conexión con las obligaciones de medio y de resultado; el **estado de necesidad** (capitán de Fuego; art. 2178 N.º 3) y el **hecho o culpa del acreedor** (*mora accipiendi*, arts. 1548, 1680, 1827); el **hecho ajeno** (arts. 1677 y 1679); y, muy especialmente, la **teoría de la imprevisión** —concepto, requisitos, casos legales de aceptación (art. 2003 regla 2.ª) y rechazo (art. 2003 regla 1.ª, art. 1983), proyectos de ley, la trilogía jurisprudencial (CA Santiago 2006 Rol 6812-2001; CS 2025 Rol 217.959-2023 «no tiene cabida mientras no se modifique el Código Civil»; CS 2024 Rol 161.630-2023 sobre la multa moratoria y los actos propios)— y su deslinde con la **frustración del fin del contrato** (Diez-Picazo; arts. 1932, 1924 N.º 2; art. 79.1 de la Convención de Viena).

7. LOS DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR

Hemos visto que el incumplimiento contractual abre al acreedor un abanico de remedios —el cumplimiento forzado, la indemnización, la resolución— y que todos ellos descansan, en último término, sobre una misma garantía: el patrimonio del deudor. De nada serviría reconocer al acreedor una acción de cumplimiento o un derecho a ser indemnizado si, llegado el momento de ejecutar la sentencia, el deudor careciera de bienes sobre los cuales hacerla efectiva, o si esos bienes hubiesen sido dilapidados, ocultos o traspasados a terceros. Por ello, junto a los derechos principales y secundarios del acreedor, el ordenamiento le reconoce un conjunto de **derechos auxiliares** destinados, precisamente, a velar por la integridad de esa garantía patrimonial. Como explica **Orrego**, su finalidad es que «el derecho principal de pedir el cumplimiento de la obligación y el derecho secundario de exigir la indemnización de perjuicios, no se tornen facultades puramente teóricas».

7.1. El derecho de prenda general y su fundamento

El punto de partida de toda esta materia es el llamado —impropiamente, como en seguida veremos— **derecho de prenda general del acreedor**. Enseña **Boetsch** que esta institución no es sino la traducción jurídica del aforismo clásico según el cual «quien se obliga compromete todos sus bienes»; es decir, que la persona que contrae una obligación asegura su cumplimiento no con su persona —pues, abolida la prisión por deudas, el deudor no responde con su libertad—, sino con todos los bienes que conforman el activo de su patrimonio. Tal «derecho» se encuentra consagrado en el artículo **2465**, que dispone que «*toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618*».

En torno a este precepto conviene precisar tres cuestiones que la doctrina destaca unánimemente:

- **La nomenclatura es defectuosa.** La expresión «derecho de prenda general» ha sido —apunta **Boetsch**— correctamente criticada, por cuanto en los hechos no existe aquí un contrato real de prenda, que supondría la entrega de bienes muebles del deudor al acreedor. Si la denominación se mantiene es únicamente por su valor ilustrativo: viene a recordar que *todos* los bienes del deudor quedan afectos al cumplimiento de la obligación, del mismo modo en que la cosa pignorada queda afecta al pago en la prenda propiamente tal.
- **No comprende los bienes inembargables.** El derecho de prenda general no alcanza a los bienes inembargables señalados en los artículos **1618** del Código Civil y **445** del Código de Procedimiento Civil, pues se trata, en general, de aquellos considerados necesarios para la subsistencia del deudor y su familia. La garantía recae, pues, sobre el patrimonio embargable.
- **Obligación «personal» se opone a obligación «real».** Cuando el artículo 2465 ampara con el derecho de prenda general a toda obligación «personal», no emplea el adjetivo en el sentido de obligación del deudor principal, sino en contraposición a las obligaciones «reales», que son las que emanan de cauciones reales como la prenda y la hipoteca. El acreedor de una obligación garantizada con caución real no puede perseguir su cumplimiento sobre todos los bienes del constituyente, sino solamente sobre aquellos afectos a la garantía. Todo lo contrario ocurre con las garantías personales, como la fianza: el fiador, al igual que el deudor principal, se obliga con todos sus bienes.

Ahora bien —y aquí está el fundamento de toda la materia que sigue—, si es el patrimonio del deudor el que responde del cumplimiento de sus obligaciones, el acreedor tiene un interés evidente y legítimo en que ese patrimonio no se menoscabe y, en lo posible, se acreciente mientras pende la obligación. De ahí que la ley le otorgue, en palabras de **Boetsch**, «ciertas acciones o medios destinados a mantener la integridad de ese patrimonio, a fin de que los bienes que lo componen no se deterioren, se enajenen o confundan con otros patrimonios». **Orrego** precisa que estos medios persiguen una **doble finalidad**: por una parte, *mantener* la integridad del patrimonio del deudor, evitando que los bienes que lo integran se reduzcan a tal punto de no servir para responder; y, por otra, *acrecentar*

ese patrimonio, sea incorporando nuevos bienes, sea reintegrando aquellos que el deudor hizo salir en fraude y perjuicio de sus acreedores.

Doctrina — Enumeración de los derechos auxiliares

No hay completa uniformidad doctrinal sobre cuáles son los derechos auxiliares, pero existe consenso en atribuir tal carácter a cuatro instituciones: **(1) las medidas conservativas**, destinadas a evitar que determinados bienes salgan del patrimonio del deudor; **(2) la acción oblicua, indirecta o subrogatoria**, destinada a obtener que ingresen al patrimonio del deudor bienes que éste negligentemente pretende dejar fuera; **(3) la acción pauliana o revocatoria**, cuyo objeto es reintegrar al patrimonio del deudor bienes que han salido de él en perjuicio de los acreedores (art. 2468); y **(4) el beneficio de separación**, destinado a impedir que los bienes del causante se confundan con los del heredero en perjuicio de los acreedores hereditarios o testamentarios (arts. 1378 a 1385). Algunos autores agregan, además, el **derecho legal de retención** (arts. 1937, 2162, 2193, 2234; arts. 545 y 546 del Código de Procedimiento Civil).

7.2. Las medidas conservativas

Las medidas conservativas constituyen el primero y más elemental de los derechos auxiliares. El Código hace referencia a ellas en diversas disposiciones —los artículos 156, 761, 1078 y 1492 inciso final, entre otros— pero, como advierten tanto **Boetsch** como **Orrego**, no las define ni establece un principio general que las consagre. La doctrina ha suplido este silencio. Para **Alessandri**, las medidas conservativas «son aquellas que tienen por objeto mantener intacto el patrimonio del deudor, evitando que salgan de su poder los bienes que lo forman, a fin de hacer posible el cumplimiento de la obligación». **Claro Solar**, por su parte, expresa que «tienen el carácter de conservativas todas las medidas destinadas a asegurar el ejercicio futuro de un derecho, sin constituir su ejercicio actual». Y **Vial** las define como «aquellas que pueden ejercer los acreedores para evitar que los bienes embargables del deudor se destruyan o deterioren, o sean objeto de enajenaciones que los hagan salir del patrimonio de este».

De estas definiciones se desprende el rasgo esencial de la categoría: la medida conservativa *asegura* el ejercicio futuro de un derecho, pero no lo ejerce ni transforma el patrimonio del deudor; se limita a mantener el *statu quo*. En ello se distingue, como veremos, de la acción oblicua y de la pauliana, que sí producen un cambio en el patrimonio del deudor. Aunque el Código no consagra un principio general, el derecho del acreedor a impetrar medidas conservativas se desprende —observa **Orrego**— de un conjunto de disposiciones dispersas en el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil. Refundiendo las enumeraciones de ambos autores, pueden mencionarse:

- **Las medidas precautorias** reglamentadas en los artículos 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, consistentes en el secuestro de la cosa objeto de la demanda, el nombramiento de uno o más interventores, la retención de bienes determinados y la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados; a las que se suman las **medidas precautorias innominadas** que admite y regula el artículo 298 del mismo Código, así como las **medidas prejudiciales** de los artículos 273 y siguientes.
- **La guarda y aposición de sellos**, de que tratan los artículos **1222** y siguientes del Código Civil, y la **declaración de herencia yacente** (art. **1240**).
- **La confección de inventario solemne**, exigida por numerosas disposiciones (arts. **124**, **374**, **775**, **1255**, **1765**, **1766**).
- **Las facultades conservativas reconocidas a titulares de derechos sujetos a incertidumbre**: el fideicomisario, el asignatario condicional y el acreedor condicional pueden impetrar providencias conservativas (arts. **761**, **1078** y **1492**).
- **El derecho legal de retención** que la ley concede al poseedor vencido, al vendedor, al arrendatario, al arrendador, al mandatario y al acreedor prendario (arts. **914**, **1826**, **1937**, **1942**, **2162** y **2401**), en cuanto permite conservar la cosa como medio de presión y garantía.
- **El desasimio** propio del procedimiento concursal de liquidación: la privación impuesta al deudor de administrar sus bienes, facultad que asume el liquidador designado en representación de la masa de acreedores (Ley N.º 20.720).

7.3. La acción oblicua o subrogatoria

7.3.1. Concepto y denominaciones

La ley, en determinados casos, otorga a los acreedores el derecho de actuar en nombre del deudor respecto de ciertas acciones o derechos que, correspondiéndole a éste, negligentemente —o con el propósito de perjudicar a sus acreedores— no ejercita. Ello con el objeto de que esas acciones o derechos ingresen al patrimonio del deudor, mejorando de ese modo el derecho de prenda general. **Abeliuk** la define con sencillez como «el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores, cuando el primero es negligente en hacerlo». Es el caso, por ejemplo, del deudor que repudia una herencia, que renuncia a una donación o que no cobra las rentas a que tiene derecho por un arrendamiento: en todos esos supuestos el acreedor podría actuar en nombre del deudor y aceptar la herencia o la donación, o cobrar las rentas.

Las tres denominaciones que recibe esta acción se explican por **Boetsch** con precisión: se la llama **subrogatoria** porque los acreedores pasan a ocupar el lugar del deudor para ejercitar sus derechos y acciones, haciéndolo por cuenta y a nombre de él; e **indirecta u oblicua** porque la acción o derecho no se incorpora directamente al patrimonio del acreedor, sino que primero ingresa al del deudor, para que después aquél pueda hacer efectivo su crédito sobre ese patrimonio. Como subraya **Orrego**, entre los bienes que forman el patrimonio del deudor se cuentan también los derechos y acciones —cosas incorpóreas que no por ello dejan de ser bienes— y, como los artículos **2465** y **2469** no distinguen entre bienes corporales e incorpóreas, estos últimos quedan igualmente afectos al derecho de prenda general. La subrogación, eso sí, sólo procede respecto de derechos que se refieran a bienes embargables: no tiene lugar sobre derechos extrapatrimoniales —como los de familia— ni sobre aquellos que no pueden ser perseguidos por el acreedor.

Doctrina — ¿Existe una acción oblicua general en Chile? (debate)

A diferencia del Derecho francés, cuyo antiguo artículo 1166 permitía a los acreedores «ejercitar todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que estén unidos exclusivamente a su persona», el Código chileno **no contiene una disposición que conceda la acción oblicua de manera general**; sólo hay casos específicos. De ahí el debate doctrinal: para **Alessandri, Fueyo y Abeliuk**, la acción oblicua sólo cabe en los casos en que la ley expresamente la autoriza; para **Claro Solar**, en cambio, ella operaría en forma general, pues — pese a no haber un texto tan claro como el francés— la situación sería semejante y emanaría de los artículos **2465 y 2466**. La opinión dominante es la primera: sólo procede en los casos legales. Conviene, pues, repasar esos casos.

7.3.2. Casos en que la ley consagraría la acción oblicua**a) El artículo 2466 inciso 1.º: prenda, usufructo y derecho legal de retención**

Dispone el artículo **2466** inciso 1.º: «*Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le conceden las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores*». A primera vista, la frase final estaría otorgando a los acreedores la facultad de subrogarse en esos derechos. Pero el alcance del precepto ha suscitado dudas y ha dividido a la doctrina en dos posiciones, que **Orrego** expone con detalle.

Primera posición (subrogación real en el ejercicio del derecho). Para autores como **Alcalde Rodríguez**, los acreedores pueden efectivamente subrogarse al deudor en el ejercicio de los derechos reales de usufructo, prenda, hipoteca y retención —escapando sólo los derechos de uso y habitación y los usufructos legales, por ser inembargables y personalísimos—. Alcalde ilustra esta tesis con ejemplos concretos:

- **Derecho de prenda.** Si A debe una suma a B y, a su vez, A es acreedor de C por otra suma garantizada con prenda (supongamos, una valiosa pintura que A tiene en su poder), y A es renuente a cobrar a C porque sabe que, una vez recibido el dinero, B se lo embargará, entonces B puede ejercer la facultad del artículo 2466: subrogando a A, se sustituye en los derechos del acreedor prendario, entre ellos el de retener la cosa empeñada —medida de presión para que C cumpla— y, en su defecto, el de vender el bien y pagarse con su producto.
- **Derecho de usufructo.** Sustituyendo al deudor titular del usufructo, los acreedores podrán hacerse dueños de los frutos —naturales o civiles— que produzca el bien y, mediante ellos, satisfacer sus créditos; e incluso retener la cosa fructuaria si el deudor tuviere créditos contra el nudo propietario por reembolsos o indemnizaciones. Alcalde invoca aquí una elocuente **nota de Bello** al artículo 2659 del «Proyecto Inédito» (correspondiente al actual art. 2466): *«El usufructuario insolvente conserva el derecho de usufructo en este sentido: que la facultad de percibir los frutos, en la cual se subroga el concurso, no puede durar más tiempo que el derecho mismo: si el usufructo fuese vitalicio, los frutos dejarían de pertenecer al concurso luego que falleciere el deudor»*. De esta nota Alcalde extrae que la atribución concedida a los acreedores no consiste en el embargo y posterior venta del derecho del usufructuario, sino en la posibilidad de ejercer, en lugar y a nombre del deudor, una facultad que a éste pertenece.
- **Dominio e hipoteca.** Aunque el artículo 2466 no los menciona, Alcalde concluye que también quedan comprendidos: la razón de la omisión es meramente de redacción, pues la norma supone un deudor insolvente que mantiene en su poder una especie ajena, y por eso no aludió ni al dominio del propio deudor ni a la hipoteca (donde la cosa no está en su poder). En consecuencia, el acreedor podría subrogar a su deudor y deducir en su nombre una acción reivindicatoria o una acción hipotecaria que le pertenecen pero que él no ejercita.

- **Derecho legal de retención.** Si B obró como mandatario de A e incurrió en gastos no reembolsados, conservando en su poder bienes recibidos por cuenta del mandante, el artículo 2162 lo faculta para retenerlos. Si B es a su vez deudor de C y sólo tiene en su patrimonio el crédito contra A —que no desea cobrar—, C podría subrogar a B y, en tal calidad, retener la cosa para impedir que sea entregada al mandante sin que cumpla su obligación de reembolso, y como medio de presión para el pago.

Segunda posición (embargo y venta forzada del derecho). Para Abeliuk (N.º 766), en cambio, el artículo 2466 no establece una verdadera acción oblicua, sino que «pareciere más bien que el legislador continuara reglamentando el derecho de ejecución que fluye de la garantía general establecida en los artículos 2465 y 2469». El razonamiento es el siguiente: el artículo 2465 permite ejecutar todos los bienes *del deudor*; pero en su patrimonio pueden existir bienes ajenos sobre los que él tiene ciertos derechos reales (prenda, usufructo) o el derecho de retenerlos. Respecto del bien mismo el deudor es mero tenedor, pero es dueño de su derecho de prenda o usufructo; tales derechos son perfectamente embargables. Así, los acreedores podrían embargar y rematar el derecho de usufructo y pagarse con el producto —lo que no pueden es rematar el bien mismo, pues debe respetarse la nuda propiedad ajena, frente a la cual procedería la tercería de dominio—. En materia de prenda, embargarían el crédito garantizado y lo sacarían a remate como cualquier otro bien. La acción oblicua, en cambio, produciría efectos muy distintos: en el usufructo, que los acreedores pasaran a gozar de éste por cuenta del deudor; en la prenda o la retención, que cobraran directamente los créditos garantizados. Para Abeliuk, los incisos 2.º y 3.º del precepto —y en especial el giro «sin embargo» con que comienza el inciso 3.º, referido a bienes ajenos que el deudor no puede perseguir por ser inembargables— confirman que se está reglamentando una modalidad de la acción ejecutiva, y no estableciendo una acción oblicua.

b) El artículo 2466 inciso 2.º: los derechos del deudor como arrendador o arrendatario (arts. 1965 y 1968)

El inciso 2.º del artículo 2466 añade que los acreedores «*podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendata-*

rio, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968». Hay aquí, en realidad, dos hipótesis inversas.

El artículo **1965** contempla el caso en que los acreedores del **arrendador** traban ejecución y embargo en la cosa arrendada: «subsistirá el arriendo, y se substituirán el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador». **Alcalde** grafica su utilidad: si A debe a B y es dueño de una propiedad —único bien de su patrimonio— arrendada a C, y la enajenación forzada del inmueble produciría un precio muy reducido mientras la renta es alta, la norma permite a B subrogar a A en el contrato y percibir, en lugar y a nombre suyo, la renta que paga C, haciendo efectivo en ella su crédito. Ahora bien, tanto **Alcalde** como **Abeliuk** advierten que aquí, propiamente, no hay acción oblicua: lo que ocurre es un *traspaso legal del contrato* a consecuencia del embargo, como modalidad de la ejecución. Tanto es así —remarca **Abeliuk**— que «esta sustitución sólo beneficia a los acreedores que intentaron el embargo, y no a la masa, como ocurre con la acción oblicua»; y, siendo el embargo una medida provisional, si el deudor paga, el embargo se alza y aquél recupera su calidad de arrendador.

El artículo **1968** contempla la situación inversa: la insolvencia declarada del **arrendatario**, que «no pone necesariamente fin al arriendo», pues «el acreedor o acreedores podrán substituirse al arrendatario, prestando fianza a satisfacción del arrendador». Como explica **Alcalde** con un ejemplo, si A es un comerciante insolvente que arrienda a C un establecimiento donde desarrolla su giro, y B —proveedor de A— tiene esperanza de cobrar en la medida en que A recupere su situación económica, B puede subrogar al deudor en la relación contractual, constituyendo fianza en beneficio de C, para mantener vigente el arriendo. En este caso —a diferencia del art. 1965— **Abeliuk** sí reconoce que la figura «tiene mucho de acción oblicua», aunque también participe de la cesión legal de contrato.

c) El artículo 1677: la cesión de acciones contra el tercero que destruyó la cosa

Cuando el deudor no puede cumplir la obligación de entregar una especie o cuerpo cierto porque ésta se perdió por hecho o culpa de un tercero, el artículo **1677** dispone que, aunque por ello se extinga la obligación del deudor, «*podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones*

que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa». **Alessandri y Meza Barros** incluyen este caso entre los de acción oblicua. Sin embargo —y esto es importante para el examen— tanto **Abeliuk** como **Alcalde** rechazan esa calificación: no hay aquí subrogación, sino *cesión legal de derechos*. La razón es que, perecida la cosa por culpa de un tercero, la obligación del deudor se extingue por «pérdida de la cosa que se debe» —un caso fortuito que lo libera de responsabilidad— de modo que el deudor normalmente *no ha sufrido daño alguno* y, por tanto, carece de acción contra el tercero. Quien ha sufrido el perjuicio es el acreedor, que cobrará los daños directamente al tercero. Sólo excepcionalmente el deudor tendrá acciones que ceder —por ejemplo, si había dejado la cosa en depósito bajo cláusula penal y ésta se destruye por culpa del depositario: allí debe ceder al acreedor su acción para reclamar la pena, lo que reporta la ventaja de no tener que probar perjuicios—; pero aun entonces, insisten ambos autores, no hay acción oblicua, sino un caso de cesión legal de derechos.

d) Los artículos 1238 y 1394: la repudiación de una herencia, legado o donación

Si el deudor repudia una herencia o legado en perjuicio de sus acreedores, el artículo **1238** dispone que «*los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedores y hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste*». El artículo **1394** repite la misma idea para la repudiación de una donación, autorizando a los acreedores para «substituirse a un deudor que así lo hace, hasta concurrencia de sus créditos».

Estas figuras tienen, según coinciden **Abeliuk y Alcalde**, una **naturaleza mixta**: participan a la vez de la acción oblicua y de la pauliana. Tienen mucho de oblicua —tanto que el art. 1394 habla de «sustitución» del deudor, porque se ejerce un derecho de éste—; pero también bastante de pauliana —tanto que el art. 1238 emplea, tan erróneamente como el art. 2468, la expresión «rescisión», pues se deja sin efecto un acto ya ejecutado y en perjuicio de los acreedores—. La diferencia decisiva con la pauliana propiamente tal es que aquí **no se exige el fraude pauliano**, sino el mero perjuicio a los acreedores, de prueba mucho más sencilla. Alcalde precisa

que la operación se compone de dos actuaciones diferenciables: primero, dejar sin efecto el repudio (lo que no es propiamente acción revocatoria, por faltar el fraude); y, segundo, ocurrir al tribunal para que autorice a sustituir al deudor y aceptar la asignación hasta concurrencia de los créditos. Lo grafica con un ejemplo: B debe 50 a C y no tiene bienes; luego recibe de A una herencia de 100, pero la repudia porque sabe que, ingresado el dinero, C lo embargará; entonces C solicita al juez que revoque el repudio hasta 50 y lo autorice para sustituir al deudor y aceptar la herencia por esa cantidad.

Doctrina — Un caso discutido: el artículo 1689 (nulidad y reivindicatoria)

Para parte de la doctrina cabe agregar otro supuesto: la posibilidad de que el acreedor ejerza la acción reivindicatoria del deudor tras una declaración de nulidad. **Alcalde** razona que, declarada la nulidad de un contrato, deben efectuarse las restituciones mutuas según las reglas de la reivindicación (art. 1689); si el deudor —que vendió a un tercero el único bien embargable de su patrimonio— no demuestra intención de reivindicar para que el bien no reingrese y sea embargado, el acreedor podría, habiendo obtenido la nulidad (que puede pedir todo el que tenga interés, art. 1683), subrogarse y entablar la reivindicatoria que pertenece al deudor. **Orrego** matiza que esto operaría sólo si el comprador hubiese, a su vez, enajenado el inmueble a un subadquirente; de lo contrario bastaría la demanda de nulidad, sin necesidad de reivindicar.

7.3.3. Requisitos de la acción oblicua

Refundiendo los requisitos que sistematizan **Boetsch** y **Orrego**, la acción oblicua —en cuanto se admita su procedencia— exige condiciones relativas al acreedor, al crédito, al deudor y a los derechos sobre los que recae:

- **En cuanto al acreedor.** Sólo se requiere que tenga *interés*, lo que ocurre cuando la negligencia del deudor en ejercitar el derecho compromete su solvencia. Falta este requisito si el deudor tiene bienes suficientes para cumplir sus obligaciones; de ahí que el artículo 2466 hable del «deudor insolvente».

- **En cuanto al crédito.** Debe ser *cierto* —el acreedor debe tener realmente tal calidad— y no estar sujeto a condición suspensiva pendiente, pues en tal caso sólo cabe impetrar medidas conservativas. Respecto del crédito sujeto a **plazo** suspensivo hay discusión: para **Alessandri y René Jorquera**, el acreedor a plazo podría ejercer la subrogatoria, pues tiene interés evidente en que la obligación se cumpla; para **Claro Solar, Meza Barros, Abeliuk y Ramos Pazos**, en cambio, se le niega, porque el crédito debe ser no sólo cierto sino *actualmente exigible* —el ejercicio de una acción del deudor es más que un acto conservatorio: produce un cambio en su patrimonio, sustituyendo un valor realizado a uno realizable—. El plazo obsta a la exigibilidad, salvo el caso de notoria insolvencia que lo hace caducar (art. 1496 N.º 1).
- **En cuanto al deudor.** Debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos y acciones, circunstancia que corresponde probar al acreedor. Anota **Abeliuk** que no es necesario constituir previamente en mora al deudor —ni siquiera, en buena doctrina, oírlo—, aunque recomienda de toda conveniencia emplazarlo para evitar discusiones posteriores sobre el efecto de la acción a su respecto.
- **En cuanto a los derechos y acciones.** Deben ser patrimoniales y referirse a bienes embargables; en ningún caso opera la subrogación respecto de derechos personalísimos —como la acción de reclamación del estado de hijo o los derechos de uso y habitación—.

7.3.4. Forma de ejercicio y efectos

En cuanto a la **forma**, los acreedores no necesitan, por regla general, autorización judicial previa para ejercer las acciones y derechos del deudor: la autorización «arranca de la ley». Por excepción, en los casos de los artículos 1238 y 1394 sí es necesario que el juez autorice al acreedor para aceptar por el deudor la asignación o donación, precisamente porque allí el deudor ha manifestado su voluntad contraria a incorporarla.

Los **efectos** derivan todos del principio de que el acreedor actúa por cuenta y a nombre del deudor —se asemeja a la representación, pero difiere de ella en que aquí lo mueve su propio interés—. De ello se sigue, con **Boetsch**: (a) el tercero demandado puede oponer al acreedor las mismas excepciones que podía oponer al deudor; (b) la sentencia produce cosa juzgada respecto del deudor —lo que Abeliuk encuentra discutible,

de ahí su recomendación de emplazarlo siempre—; (c) no se requiere una resolución previa que autorice la subrogación, calificándose ésta en el mismo juicio; y (d) lo más relevante: los bienes ingresan al *patrimonio del deudor*, de modo que la acción **beneficia a todos los acreedores** y no sólo al subrogante (arts. **2465** y **2469**). Es justamente por este último efecto —observa Abeliuk— que la acción oblicua tiene, en la práctica, escasa importancia y aplicación: el acreedor diligente que la ejerce termina compartiendo el fruto de su esfuerzo con los demás acreedores.

7.4. La acción pauliana o revocatoria

7.4.1. Concepto, origen y fundamento

Mientras la acción oblicua busca *incorporar* al patrimonio del deudor bienes que nunca han entrado en él, la acción pauliana persigue *reintegrar* bienes que ya salieron de ese patrimonio en fraude de los acreedores. La institución tiene su origen en Roma, donde los actos realizados por un deudor en fraude de sus acreedores constituían un delito privado —el *fraus creditorum*— sancionado mediante una acción especial que los comentaristas llamaron «pauliana». **Boetsch** recuerda que el origen del apelativo es discutido: algunos lo atribuyen al pretor que habría establecido la acción, de nombre *Paulus*; parece más verosímil que derive del gran jurisconsulto **Paulo**, que trata de ella en un fragmento del Digesto. Se la llama también **revocatoria** porque tiene por objeto revocar, dejar sin efecto, los actos fraudulentos del deudor realizados en perjuicio de sus acreedores. Está tratada en el artículo **2468**, y **Abeliuk** la define como «la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurran los demás requisitos legales».

Su **fundamento** —destaca **Orrego**— es el acto fraudulento ejecutado por el deudor, cometido con el propósito de perjudicar a los acreedores. De ahí que, a diferencia de la oblicua, la acción pauliana corresponda a los acreedores *personalmente*: es una acción que les es propia, una acción directa que está en su patrimonio y les pertenece en su condición de víctimas de un hecho ilícito del deudor que exige reparación.

No confundir — Seis diferencias entre la acción oblicua y la pauliana

Aunque ambas conducen al mismo fin —la incorporación de bienes al patrimonio del deudor—, **Orrego** las distingue nítidamente: **(1)** el antecedente de la oblicua es un actuar *negligente* del deudor (culpa); el de la pauliana, un acto *fraudulento* (fraude, que para algunos es una especie de dolo: un delito civil). **(2)** La oblicua hace ingresar bienes que *nunca estuvieron* en el patrimonio del deudor (una herencia que repudia); la pauliana *reincorpora* bienes que el deudor hizo salir fraudulentamente. **(3)** Los bienes obtenidos por la oblicua aprovechan a *todos* los acreedores; los de la pauliana, sólo al acreedor *que la ejerció*. **(4)** La pauliana es acción *directa*, que pertenece por derecho propio a los acreedores; en la oblicua actúan en nombre y representación del deudor. **(5)** La pauliana prescribe en un año desde el acto o contrato; la oblicua no tiene una regla única de prescripción. **(6)** Parte de la doctrina niega la oblicua si el crédito no es actualmente exigible; la pauliana, en cambio, puede intentarla el acreedor a plazo, pues la insolvencia del deudor hace caducar el plazo (art. **1496** N.º 1).

7.4.2. Oportunidad: no se requiere procedimiento concursal

Un punto que el examen suele explorar: **no es necesario** que el deudor esté sometido a un procedimiento concursal de liquidación o haya hecho cesión de bienes para que proceda la acción pauliana. Es verdad que el artículo 2468 se refiere a «los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso», pero ello —explican **Boetsch** y **Orrego**— sólo busca diferenciar la situación jurídica de los actos anteriores y posteriores a la resolución de liquidación, no exigir el concurso como presupuesto. De lo contrario, quedarían sin poder atacarse muchos actos fraudulentos y lesivos. Abierto el concurso, rige en cambio el artículo **2467**, que declara nulos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o sobre los que se ha abierto concurso; y los actos previos pueden además revocarse por las **acciones revocatorias concursales** de los artículos 287 y siguientes de la Ley N.º 20.720, que descargan al acreedor de la prueba del fraude, presumiéndolo —el artículo 287 consagra una «revocabilidad objetiva» (basta el plazo sospechoso

y el perjuicio a la masa) y el artículo 288 una «revocabilidad subjetiva» (que añade la mala fe del tercero) —.

7.4.3. Requisitos de la acción pauliana

Siguiendo el orden de **Boetsch**, los requisitos se estudian en relación con el acto, el deudor, el acreedor y el tercero adquirente. **Orrego** los reconduce, con acierto, a dos exigencias capitales para revocar un acto: una *objetiva* —el perjuicio— y otra *subjetiva* —el fraude—.

a) Requisitos en relación con el acto

La acción pauliana puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato *voluntario* del deudor —no los forzados, en los que no se divisa fraude ni voluntad—. Los términos del artículo 2468 son amplios: caben actos unilaterales o bilaterales, gratuitos u onerosos, donaciones, renunciaciones de derechos, etc. Las cauciones otorgadas por el deudor también quedan incluidas si son fraudulentas; por eso el N.º 1 del artículo 2468 menciona la prenda, la hipoteca y la anticresis. Sería el caso, por ejemplo, de una deuda pendiente que el deudor garantiza con una hipoteca totalmente innecesaria.

b) El perjuicio (requisito objetivo) y los acreedores que pueden accionar

El acreedor que entabla la acción debe tener *interés*, y sólo lo tiene cuando concurren dos circunstancias: que el deudor sea insolvente o que con el acto aumente su insolvencia, y que su crédito sea *anterior* al acto que produce la insolvencia. Explica **Somarriva** que «se entiende que existe este perjuicio cuando a consecuencia del acto el deudor queda en insolvencia, o se aumenta la ya producida»; y agrega que al acreedor que adquiere tal carácter *después* del acto, éste no puede causarle perjuicio, pues conocía el estado de los negocios del deudor y aceptó contratar en esas condiciones. **Orrego** precisa dos exigencias respecto de la insolvencia: debe ser *contemporánea* con el ejercicio de la acción (no son atacables los actos si, pese a la enajenación, el deudor conserva bienes suficientes) y debe provenir, total o parcialmente, del acto que se pretende revocar (nexo *causal*). Por ello se afirma que la acción pauliana es *subsidiaria*: el acreedor sólo recurre a ella cuando le es imposible obtener el

pago por otros medios. Tampoco pueden atacarse por esta vía los actos que sólo dejen de enriquecer al deudor —que serían materia de acción oblicua— ni los que recaigan sobre bienes inembargables, pues allí no hay perjuicio al derecho de prenda general. Este requisito tiene, pues, carácter **objetivo**.

c) El fraude pauliano (requisito subjetivo)

Respecto del deudor, el artículo 2468 exige que esté de *mala fe*. Pero se trata de una mala fe específica, denominada **fraude pauliano** o mala fe pauliana, que consiste —según define el propio N.º 1 del artículo 2468— en realizar el acto *conociendo el mal estado de sus negocios*. Respecto de los terceros que contraten con el deudor, el fraude consiste asimismo en el conocimiento de ese mal estado. Esta es la circunstancia que deberán probar los acreedores para obtener la revocación, y su carácter es **subjetivo**.

Doctrina — El gran debate: ¿es el fraude pauliano una especie de dolo?

La cuestión es de enorme relevancia práctica, pues de ella depende, entre otras cosas, si los contratantes responden *solidariamente* (art. **2317** inc. 2.º). Se observan dos posturas. **(1) El fraude pauliano es una especie de dolo (delito civil)**. Para **Alessandri**, aunque este fraude «no tiene nada de parecido con el dolo en los contratos» —no hay maquinaciones para arrancar el consentimiento, sino la ejecución de un acto con el propósito de perjudicar a los acreedores que quedan al margen—, constituye un verdadero *delito civil* que obliga a reparar el daño; el fraude pauliano supondría, así, dolo en el actuar del deudor, si bien el dolo propio de la responsabilidad extracontractual. **Abeliuk** habla de un «dolo especialísimo»: hay dolo, pero no el que vicia el consentimiento (invocable por la parte perjudicada), sino un dolo en perjuicio de terceros que sólo éstos pueden hacer valer. **(2) El fraude pauliano no es dolo**. Esta tesis, que distingue netamente ambas figuras, fue recogida por la Corte Suprema en un fallo capital que conviene conocer al detalle.

JURISPRUDENCIA — CORTE SUPREMA, 18 DE OCTUBRE DE 2017, ROL N.º 18.184-2017 (FRAUDE PAULIANO Y SOLIDARIDAD)

En una acción pauliana dirigida a revocar la compraventa de un inmueble, el juzgado de Lebu había rechazado la demanda acogiendo la prescripción opuesta por el comprador. La **Corte de Apelaciones de Concepción** (31 de marzo de 2017) revocó: razonó que los demandados, al actuar «conjuntamente y de común acuerdo», cometieron un *ilícito civil*, un acto fraudulento, de modo que su responsabilidad era **solidaria** (art. 2317 inc. 2.º); y, siendo solidaria, la interrupción de la prescripción respecto de uno perjudicaba también al otro, por lo que la acción no estaba prescrita. La **Corte Suprema** casó este fallo y confirmó el de primera instancia, sentando una doctrina precisa: *«el fraude pauliano no exige la intención de perjudicar; para que exista basta el conocimiento o la conciencia del perjuicio que el acto del deudor puede causar al acreedor»*. El artículo 2468 *«no requiere la intención de perjudicar a los acreedores, pues limita el fraude al conocimiento del mal estado de los negocios del deudor»*, mientras que el dolo del artículo 44 es *«la intención positiva de inferir injuria»*. Por tanto, *«la mala fe que requiere la acción pauliana (...) necesariamente difiere de la culpa o del dolo propios de la responsabilidad civil regulada en el artículo 2314»*, y *«el hecho ilícito al que se alude en el artículo 2317 inciso 2.º (...) no abarca el denominado fraude pauliano»*. Conclusión: **no hay solidaridad** entre el deudor y el tercero adquirente, de modo que la notificación a uno no interrumpió la prescripción respecto del otro, y la excepción de prescripción debía acogerse.

Orrego toma posición frente a este fallo: personalmente se inclina por la solución de la Corte de Apelaciones de Concepción —es decir, por la solidaridad— pero *no porque haya dolo*, sino porque existe *fraude*, y el fraude, al igual que el dolo, origina responsabilidad solidaria conforme al inciso 2.º del artículo 2317, que precisamente alude a «todo fraude o dolo». En el mismo sentido, **Claro Solar** distingue conceptualmente ambas figuras —«el fraude es ejercido por personas que contratan entre sí o por una persona aislada para perjudicar a un tercero; y el dolo (...) ser ejercido por uno de los contratantes contra el otro»— pero reconoce que el distingo «pierde transcendencia en la práctica», pues el Código, en el hecho, los usa como sinónimos en cuanto a sus efectos (art. 2317). El examinando debe, pues, dominar las dos lecturas y saber que la Corte Suprema, en 2017, optó por separar el fraude pauliano del dolo y negar la solidaridad.

d) Requisitos en relación con el tercero: actos gratuitos y onerosos

Aquí la ley distingue, y la distinción es clásica. Para revocar un acto a título **oneroso** es necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del tercero adquirente, esto es, que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor (art. **2468** N.º 1). En cambio, para revocar un acto a título **gratuito** basta la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores, sin requisito especial alguno en el beneficiario (art. **2468** N.º 2). La razón de esta diferencia —explica **Boetsch**— está en los intereses en juego: frente al acreedor que quiere mantener íntegra su garantía, la ley sacrifica con mayor facilidad al tercero que *nada ha desembolsado*, pues con la revocación no pierde nada y queda igual que antes del acto (*certat de lucro captando*); en cambio, el adquirente a título oneroso ha hecho un sacrificio económico (*certat de damno vitando*), y por eso el legislador no puede prescindir de su actitud y sólo lo sanciona si fue también fraudulento. El principio general es, entonces, que la acción pauliana **no afecta a los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso**, pero sí a los de mala fe a título oneroso y a los adquirentes a título gratuito, sea cual fuere su buena o mala fe.

e) Situación del subadquirente

El Código no reguló la situación de los subadquirentes —aquellos cuyos derechos emanan del tercero que contrató con el deudor (el deudor donó su automóvil a A, y A lo vendió a B)—. La doctrina discrepa. Si la acción pauliana *no procedía* contra el adquirente directo (por ser de buena fe a título oneroso), hay acuerdo en que tampoco procede contra el subadquirente, cualquiera sea su título o buena fe. La discusión surge cuando la acción *sí* procede contra el adquirente. Para **Alessandri**, fundado en que la pauliana sería acción de «rescisión» y en los artículos **2468** y **1681** y siguientes, las mismas reglas de la nulidad rigen a los subadquirentes: y como la nulidad judicialmente declarada da acción contra terceros poseedores sin distinguir su buena o mala fe ni la naturaleza del título, la pauliana los afectaría siempre. Para **Meza Barros** y **Abeliuk**, en cambio, debe aplicarse al subadquirente la *misma solución que al adquirente* —pues la pauliana no es acción de nulidad y no habría razón para colocar al subadquirente en peor situación que el adquirente—: la revocación procede contra el subadquirente a título gratuito esté de buena o mala fe, pero contra el subadquirente a título oneroso sólo si está de mala fe.

7.4.4. Características, efectos y prescripción

La acción pauliana presenta —según **Boetsch**— tres **características**: (a) es una acción *directa* del acreedor, que ejerce a su propio nombre y no por cuenta del deudor; (b) es una acción *personal* —punto que ha suscitado controversia, porque, al igual que otras acciones personales, puede afectar a terceros; en efecto, el tercero adquirente debe ser parte en el pleito, tanto que si es a título oneroso está en discusión su buena fe—; y (c) es una acción *patrimonial*, de donde se sigue que es renunciable, transferible, transmisible y prescriptible.

El **efecto** propio de la acción es dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, pero sólo *hasta el monto del crédito* del acreedor que la intenta; consecuencia de ello es que el deudor puede *enervar* la acción pagando al acreedor. La revocación es, además, *relativa* desde dos puntos de vista, como subraya **Orrego**: por una parte, no aprovecha al deudor sino sólo a los acreedores —entre deudor y tercero el acto subsiste, de modo que si, pagado el crédito, queda un saldo del bien realizado en subasta, ese saldo es para el tercero y no para el deudor, pues de lo contrario el fraude se revertiría en beneficio del propio deudor—; y, por otra, no aprovecha a todos los acreedores sino sólo a los que fueron parte en la instancia (art. **3** del Código Civil), salvo el caso del procedimiento concursal de liquidación, en que la acción se intenta «en interés de la masa». Los efectos concretos variarán según el acto: si se trata de una enajenación, ésta quedará total o parcialmente sin efecto y el adquirente perderá la cosa; si se ataca una hipoteca, se cancelará; si se impugna una remisión, renacerá el crédito.

En cuanto a la **prescripción**, la acción pauliana prescribe en el plazo de *un año* contado desde la fecha del acto o contrato (art. **2468** N.º 3). Por tratarse de una prescripción especial o de corto tiempo, *no se suspende* y corre contra toda persona (art. **2524**). Las acciones revocatorias concursales, por su parte, prescriben en un año contado desde la respectiva resolución (art. 291 de la Ley N.º 20.720).

7.4.5. Naturaleza jurídica

La determinación de la naturaleza jurídica de la acción pauliana es uno de los puntos clásicos de la disciplina, con tres grandes tesis que **Abeliuk** (N.º 776) sistematiza asumiendo que se trata de una acción personal:

- **Tesis de la nulidad relativa (Alessandri).** Tomando pie de la expresión «rescindibles» que emplea el artículo 2468, entiende que es una acción de nulidad relativa, lo que tiene importancia para resolver si a los subadquirentes se les exige o no mala fe (fundado en el art. 1689, Alessandri concluye que no). En contra, **Ramos** objeta que, aunque el artículo 2468 emplee la forma verbal «rescindan», la pauliana no es acción de nulidad, pues el acto que se pretende dejar sin efecto es *válido*: en su formación no hubo vicio originario alguno, y sin vicio originario no hay nulidad. La nulidad, además, opera retroactivamente y afecta a todo el acto, mientras que la revocación deja sin efecto el acto sólo en la parte que perjudica a los acreedores, subsistiendo en lo demás.
- **Tesis de la inoponibilidad por fraude (Somarriva, Abeliuk).** Es la opinión *más aceptable*. El acto es perfectamente válido y oponible entre las partes —ni el deudor ni el tercero podrían impugnarlo alegando que fue fraudulento—, pero el acreedor puede desconocerlo y privarlo de efectos respecto de él, como ocurre justamente en la inoponibilidad; y el acto se revoca sólo en la parte que lo perjudica, no más allá. El que la revocación opere hasta el monto del crédito es un buen argumento a favor de esta tesis. **Orrego** añade un argumento decisivo: la acción sólo corresponde a quienes eran acreedores al tiempo de la enajenación, de modo que el mismo contrato no puede ser nulo para esos acreedores y válido para los posteriores —o es nulo para todos, o no lo es para nadie—; en cambio, sí puede ser *inoponible* a unos (los acreedores anteriores) y oponible a otros (los posteriores), lo que confirma la naturaleza de inoponibilidad.
- **Tesis indemnizatoria (Planiol).** Se trataría de una acción de responsabilidad por un hecho ilícito, en la que la reparación adopta una forma especial: dejar sin efecto el acto ilícito. Abeliuk objeta que esta tesis no explica por qué la acción afecta también al adquirente a título gratuito de buena fe, respecto del cual no hay acto ilícito y, sin embargo, procede la revocación.

7.5. El beneficio de separación

El cuarto y último de los derechos auxiliares no opera sobre actos del deudor, sino sobre un fenómeno propio de la sucesión por causa de muerte: la *confusión de patrimonios*. En virtud de los principios sucesos-

rios, fallecida una persona, su patrimonio —activo y pasivo— pasa a sus herederos, confundándose con el patrimonio de éstos. Ahora bien —explica **Boetsch**— si el heredero estaba cargado de deudas, sus acreedores personales mejoran su situación, pues pasan a contar con un patrimonio más rico sobre el cual hacer efectivas sus acreencias; pero ello ocurre en perjuicio de los acreedores que el difunto tenía en vida (los **acreedores hereditarios**) y de aquellos cuyos créditos emanan del testamento (los **acreedores testamentarios** y legatarios), quienes verán peligrar sus créditos al tener que concurrir con los acreedores propios del heredero sobre una misma masa.

Para conjurar ese riesgo, la ley establece el **beneficio de separación de patrimonios**, que tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los del heredero, a fin de que los acreedores hereditarios y testamentarios puedan pagarse sobre los bienes del causante *con preferencia* a los acreedores personales del heredero. Es, pues, un derecho auxiliar que cumple la función de *mantener* separada —e intacta— la garantía sobre la cual los acreedores del difunto contaron al contratar. El Código lo regula en los artículos **1378** a **1385** (Título XII del Libro III), y su estudio detallado corresponde a la sucesión por causa de muerte; baste aquí con identificarlo como el último de los medios de conservación del patrimonio del deudor.

Dato de grado — cómo ordenar los cuatro derechos auxiliares

Si en el examen le piden los derechos auxiliares, ofrezca primero el **fundamento común** (el derecho de prenda general, art. 2465, y la doble finalidad de *mantener y acrecentar* el patrimonio del deudor) y luego enuncie los cuatro según su función: **(1) medidas conservativas** → mantener; **(2) acción oblicua** → acrecentar incorporando bienes que *nunca entraron* (sin fraude, beneficia a todos); **(3) acción pauliana** → acrecentar reintegrando bienes que *salieron en fraude* (con fraude pauliano, sólo aprovecha al demandante); **(4) beneficio de separación** → mantener separada la garantía evitando la confusión hereditaria. El par oblicua/pauliana es el más preguntado: tenga listas las seis diferencias y, sobre la pauliana, los dos requisitos (perjuicio objetivo + fraude subjetivo), la distinción gratuito/oneroso (art. 2468 N.º 2 / N.º 1) y la naturaleza de inoponibilidad.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 7 — Los derechos auxiliares del acreedor**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección. Presta especial atención a: el **derecho de prenda general** (art. 2465, nomenclatura impropia, bienes inembargables arts. 1618 CC y 445 CPC, «personal» vs. «real») y la *doble finalidad* de los derechos auxiliares (mantener / acrecentar); las **medidas conservativas** (defs. Alessandri / Claro Solar / Vial; medidas precautorias arts. 290 y ss. CPC, guarda y aposición de sellos art. 1222, inventario solemne, desasimiento Ley 20.720); la **acción oblicua o subrogatoria** (concepto de Abeliuk; debate sobre su procedencia general —Alessandri/Fueyo/Abeliuk vs. Claro Solar—; las dos lecturas del art. 2466 con los ejemplos de Alcalde sobre prenda, usufructo —nota de Bello al Proyecto Inédito—, dominio/hipoteca y retención; el art. 1677 como cesión legal de derechos y no oblicua; los arts. 1965 y 1968; la naturaleza mixta de los arts. 1238 y 1394; requisitos y el efecto de que *beneficia a todos los acreedores*); y, muy especialmente, la **acción pauliana o revocatoria** —origen romano, las seis diferencias con la oblicua, el doble requisito (perjuicio/insolvencia objetivo + fraude pauliano subjetivo), el gran debate sobre si el fraude pauliano es o no una especie de dolo y sus consecuencias en la solidaridad (CS 18 de octubre de 2017, Rol 18.184-2017, frente a la CA de Concepción), la distinción entre actos gratuitos y onerosos (art. 2468 N.º 2 y N.º 1), la situación del subadquirente, la prescripción de un año (art. 2468 N.º 3) y las tres tesis sobre su naturaleza jurídica (nulidad / indemnización / inoponibilidad, siendo esta última la más aceptada)—, además del **beneficio de separación** (arts. 1378 a 1385) como medio para evitar la confusión de patrimonios en perjuicio de los acreedores hereditarios y testamentarios.

8. CLÁUSULAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD

Todo el régimen de responsabilidad contractual estudiado en las secciones anteriores —los grados de culpa, la previsibilidad de los perjuicios, la carga de la prueba, el caso fortuito— constituye lo que la doctrina llama el *régimen legal supletorio*: el conjunto de reglas que se aplican *a falta de pacto en contrario*. Pero ese régimen no es, en su mayor parte, de orden público. Desde la entrada en vigencia del Código Civil, diversas disposiciones han permitido que las partes establezcan una regulación especial de la responsabilidad civil que deriva del incumplimiento, agravándola o atenuándola según su conveniencia. Esta sección estudia esas **cláusulas modificatorias de la responsabilidad**: su admisibilidad y límites, las reglas con que deben interpretarse y el sentido que ha de darse a las cláusulas de estilo que más controversias han generado en la práctica.

8.1. Consideraciones generales: admisibilidad, tipología y límites

El fundamento positivo de la modificación convencional de la responsabilidad se encuentra, como enseña **Orrego**, en los *incisos finales* de dos disposiciones capitales: el artículo **1547**, que tras fijar el grado de diligencia exigible y la carga de la prueba aclara que todo ello rige «sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes»; y el artículo **1558**, que tras regular los perjuicios de que responde el deudor agrega que «las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas». A ellos se suma el artículo **1673**, que permite a las partes distribuir los riesgos de la ejecución, disponiendo que en tal caso «se observará lo pactado». De estas normas se concluye que la responsabilidad normal del deudor puede resultar *mayor o menor* de lo que sería según las reglas generales.

Ahora bien —advierte **Boetsch**—, pese a su evidente utilidad, estas estipulaciones han suscitado en la práctica numerosas controversias, sobre todo cuando se redactan en términos muy amplios, absolutos o perentorios, empleando de manera categórica expresiones como «todo» o «ningún» perjuicio, incumplimiento o situación. Las discrepancias se han incrementado en las últimas décadas por el empleo cada vez más habitual de modelos de cláusulas y contratos provenientes del extranjero, en particular de países del *Common Law*: muchas de estas «importaciones» son

traducciones literales que no se han cuidado de adecuar armónicamente al ordenamiento nacional. Con todo, observa **Boetsch**, esta clase de estipulaciones —nacionales o foráneas— en abstracto y a primera vista *no parecen adolecer de nulidad absoluta* por objeto o causa ilícita, en cuanto su tenor no contraviene el orden público, las buenas costumbres o la ley (salvo casos especiales). Las controversias sobre su sentido y alcance deben, más bien, resolverse mediante un ejercicio interpretativo de la convención, a fin de conservar su eficacia.

Atendiendo a su dirección, las cláusulas modificatorias se clasifican en dos grandes grupos —que **Orrego** sistematiza con ejemplos legales precisos—, a los que la doctrina añade un tercero, las exonerativas, como caso extremo de las atenuantes:

- **Cláusulas que agravan la responsabilidad.** Las partes pueden estipular: (i) que el deudor responda incluso del *caso fortuito* (arts. **1547** y **1673**), asumiendo así un riesgo que ordinariamente lo liberaría; (ii) que responda de un *grado de culpa* más estricto, que lo obligue a emplear mayor diligencia que la que normalmente le corresponde (Orrego cita el art. **2222** a propósito del depósito); y (iii) que responda de los *perjuicios* de manera más gravosa que la del artículo 1558 —por ejemplo, que aun habiendo sólo culpa se responda de los perjuicios directos previstos *e imprevistos*—.
- **Cláusulas que atenúan la responsabilidad.** Inversamente, las partes pueden: (i) *rebajar el grado de culpa* del que ordinariamente se habría respondido; o (ii) estipular que sólo se responderá de los perjuicios *directos previstos* y no de los directos imprevistos. La forma extrema de la atenuación es la **cláusula exonerativa** o de irresponsabilidad, que pretende liberar al deudor de toda responsabilidad.

Atención — El límite infranqueable: nunca puede condonarse el dolo (ni la culpa grave) futuro

La libertad para atenuar la responsabilidad reconoce un tope categórico. Como sintetiza **Orrego**, «*nunca podrá convenirse que se le exima al deudor de responsabilidad, pues ello equivaldría a condonar el dolo futuro*» (art. **1465**: «la condonación del dolo futuro no vale»). Y por la misma razón **tampoco puede eximirse al deudor de la culpa lata o grave**, pues el artículo **44** dispone que ésta «en materias civiles equivale al dolo». De modo que la irresponsabilidad pactada sólo puede referirse, válidamente, a la *culpa leve y levísima* —o a responder por menos perjuicios—, pero jamás al dolo ni a la culpa grave. Una cláusula de exoneración total e indiscriminada degeneraría, además, en una condición meramente potestativa del deudor («cumpliré sólo si quiero»), nula conforme al artículo **1478**.

Precisamente porque las convenciones que liberan al deudor de responsabilidad son *extraordinarias* —recuérdese que en materia contractual la culpa se presume (art. **1547** inc. 3.º)—, aunque se aceptan, están sometidas a límites. **Fueyo** los sistematiza en un célebre octálogo, que conviene tener presente: **(1)** que no se desmaterialice la esencia del vínculo obligatorio; **(2)** que no se contravenga el orden público, la moral o las buenas costumbres; **(3)** que no se atente contra el principio general de la buena fe ni haya ejercicio abusivo de los derechos; **(4)** que no se atente contra la legítima libertad contractual; **(5)** que no medie en el agente dolo o culpa grave; **(6)** que no se actúe contra prohibición expresa de la ley; **(7)** que no se esté en el campo de los derechos irrenunciables; y **(8)** que no se configure un incumplimiento meramente potestativo y voluntario del deudor.

Doctrina — El fundamento último: el contrato como instrumento de distribución de riesgos (Aedo)

¿Por qué tolera el ordenamiento que las partes alteren su régimen de responsabilidad? La doctrina moderna —con **Cristián Aedo**, sobre la base de **Brantt, Morales y Barros**— ofrece una explicación de fondo: la responsabilidad contractual es un **régimen disponible** precisamente porque el contrato es, ante todo, un *instrumento de distribución voluntaria de los riesgos* a los que las partes deciden someterse. Basta revisar las normas del Código que la regulan para comprobarlo: todas ellas permiten que los contratantes alteren el régimen —el artículo **1547** los autoriza a fijar el grado de diligencia de que se responde y el alcance del caso fortuito; el artículo **1558** les permite modificar la extensión de los daños reclamables, hasta el extremo (señala Aedo) de responder de daños indirectos que carecen de causalidad—. El eje de esa distribución de riesgos es la culpa, y el ámbito de la reparación queda circunscrito a lo que las partes *previeron al tiempo de celebrar el contrato* (de ahí la regla de previsibilidad del art. 1558). Ahora bien —y esta es la advertencia capital de **Aedo**—, esta justificación supone que las partes se hallen en una *genuina posición de distribuir sus riesgos*, es decir, una relativa igualdad con igual acceso a la información. Cuando esa premisa falta —contratos de adhesión, relaciones de consumo—, la libre distribución de riesgos no garantiza la justicia del contrato, la buena fe (art. **1546**) opera como dispositivo de control de la autonomía privada, y la frontera entre la responsabilidad contractual y la aquiliana tiende a desdibujarse. La validez de las cláusulas modificatorias, por tanto, es tan robusta como real sea la libertad con que se pactaron.

8.2. Reglas de interpretación de estas cláusulas

Como estas cláusulas no fueron concebidas por el legislador chileno —son, según vimos, un trasplante del *Common Law*— y como su redacción suele ser amplia, genérica y muchas veces ambigua, el problema central que plantean no es tanto el de su *validez* en abstracto cuanto el de su *interpretación* en concreto. **Boetsch** propone, en esta materia, un conjunto de reglas hermenéuticas que permiten determinar el sentido y alcance de

tales estipulaciones sin desnaturalizar el sistema legal de responsabilidad. Las examinamos ordenadamente.

8.2.1. La modificación de la responsabilidad requiere estipulación expresa, especial y explícita

La primera regla es que el régimen legal de responsabilidad —el de los artículos **1547** y siguientes— constituye el *derecho común*, esto es, la regla supletoria que se aplica a falta de pacto. De ahí que sólo pueda entenderse alterado mediante una **estipulación expresa, especial y explícita**. Lo confirma el propio Código, que admite la modificación convencional «*sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes*» (art. **1547** inc. final), y que reitera la misma idea a propósito de la extensión de los perjuicios indemnizables (art. **1558** inc. final) y de la responsabilidad por caso fortuito (art. **1673**). Estas cláusulas son, en la nomenclatura del artículo **1444**, *elementos accidentales* del contrato: no se entienden incorporadas sino en virtud de cláusulas especiales. De ello se sigue una consecuencia práctica de la mayor importancia: en la duda sobre si las partes quisieron o no apartarse del régimen legal, ha de estarse por la **subsistencia de éste**, pues la alteración no se presume.

8.2.2. Prevalencia de la intención y de la buena fe sobre la literalidad

Sentado que existe una cláusula modificatoria, su alcance no se determina por el solo tenor de las palabras. Rige aquí la regla cardinal del artículo **1560**, conforme a la cual, «*conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras*». Y la regla del artículo **1561**, según la cual, por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplican a la materia sobre que se ha contratado. De modo que una cláusula redactada en términos absolutos («el deudor no responderá de daño alguno») no puede leerse aisladamente, sino a la luz de la finalidad económica del contrato y de lo que las partes razonablemente pudieron querer.

Pero el verdadero eje de la interpretación de estas cláusulas es el principio de la **buena fe** consagrado en el artículo **1546**: los contratos «*deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la*

naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella». Este precepto cumple, como destaca **Boetsch**, una doble función: *integradora* —incorpora al contrato deberes no expresados— e *interpretativa* —fija el sentido de lo expresado—. En palabras de **Fueyo**, en virtud de la buena fe «*ya no hay contratos de derecho estricto*»: toda estipulación, por absoluta que aparezca, se modela conforme a las exigencias de la lealtad y la corrección recíprocas. **Baraona** y, antes, **Betti** insisten en que la buena fe impone un «*deber de cooperación debido en interés ajeno*», que ninguna cláusula de irresponsabilidad puede aniquilar sin contrariar la propia esencia del vínculo. Y todo ello sin desconocer la fuerza obligatoria del contrato (art. **1545**, *pacta sunt servanda*): la buena fe no autoriza a desconocer lo pactado, sino a interpretarlo rectamente. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha hecho suyo este criterio, entendiendo la buena fe en sentido *objetivo*, como estándar de conducta exigible a un contratante leal y honesto.

Doctrina — La buena fe como límite hermenéutico de las cláusulas de irresponsabilidad

La conjunción de los artículos **1546**, **1560** y **1561** conduce a una conclusión sistemática: las cláusulas que alteran la responsabilidad no se interpretan extensivamente. Una cosa es que las partes puedan, dentro de los límites legales, redistribuir los riesgos del contrato; y otra muy distinta es que, escudándose en una redacción amplia, una de ellas pretenda liberarse de toda diligencia y burlar la legítima expectativa de la otra. La buena fe objetiva opera, entonces, como un correctivo que impide leer estas cláusulas más allá de lo que su función económica y la lealtad contractual permiten.

8.2.3. Interpretación restrictiva

Como corolario de lo anterior, estas cláusulas se interpretan **restrictivamente**. El fundamento es doble. En el plano de la técnica interpretativa, opera el artículo **1563**, conforme al cual, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. En el plano de los principios, la *responsabilidad* del deudor que no cumple es el principio general del sistema; las cláusulas que la limitan o suprimen son, por definición, *excepcio-*

nales, y las excepciones son de derecho estricto. De ahí que, ante una cláusula de redacción dudosa, deba preferirse el sentido que menos se aparte del régimen común de responsabilidad: lo que la cláusula no exonera con claridad, queda sujeto a las reglas generales.

8.2.4. No se presume la condonación del dolo o de la culpa grave pasados, pero pueden condonarse expresamente

Es preciso distinguir con cuidado dos hipótesis que el artículo 1465 trata de manera diametralmente opuesta. La **primera parte** de ese precepto admite la condonación del dolo —y, por extensión del artículo 44, de la culpa grave— *ya acaecido*, esto es, pasado o presente: «*El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente*». De este giro se desprende, a contrario, que el dolo pasado **sí puede condonarse**, con dos exigencias: que la condonación sea *expresa* y que el acreedor tenga *conocimiento* del dolo que perdona. Tiene esta aplicación general en los **finiquitos** totales o parciales: el acreedor puede renunciar a perseguir un dolo o una culpa grave ya consumados, pero esa renuncia no se presume ni se infiere de fórmulas genéricas; debe constar de manera específica y con cabal noticia de aquello que se condona.

8.2.5. La condonación del dolo o de la culpa grave futuros es un límite infranqueable

Radicalmente distinta es la **segunda parte** del artículo 1465: «*La condonación del dolo futuro no vale*». La razón es de orden público: admitir que un contratante quede de antemano liberado de las consecuencias de su propio dolo equivaldría a autorizarlo a no cumplir cuando le pluguiere, vaciando de contenido la obligación. Una cláusula tal adolece de **objeto ilícito** y, por consiguiente, de **nulidad absoluta** (art. 1682). Y como el artículo 44 equipara la culpa grave al dolo «en materias civiles», la prohibición se extiende a la condonación anticipada de la *culpa lata o grave*. Cabe añadir, con **Boetsch**, que una exención total y anticipada de responsabilidad importaría además sujetar el cumplimiento a una *condición meramente potestativa* de la voluntad del deudor, nula a la luz del artículo 1478. He aquí, pues, el límite que ninguna autonomía privada puede traspasar: se puede pactar responder de menos —de la sola culpa leve o levísima, de menos

perjuicios—, pero jamás pactar de antemano la impunidad del dolo o de la culpa grave.

8.3. Análisis de determinadas cláusulas de estilo

Las reglas hermenéuticas anteriores no son meras abstracciones: se ponen a prueba al enfrentarlas con las fórmulas que la práctica contractual repite una y otra vez. **Boetsch** somete a examen las más frecuentes —las llamadas *cláusulas de estilo*—, que por su redacción amplia o absoluta parecerían exonerar al deudor mucho más allá de lo que el ordenamiento tolera. Veremos que, leídas conforme a las reglas precedentes, su alcance real es mucho más acotado.

8.3.1. La cláusula «no se admitirá interpretación»

Es común que los contratos incorporen una cláusula según la cual su texto «no admitirá interpretación» o «deberá estarse exclusivamente a su tenor literal». Tal estipulación es, en rigor, **ineficaz** para lograr su propósito. Como advierte **Claro Solar**, todo contrato —por claro que parezca— *siempre* debe ser interpretado, aunque más no sea para constatar que su sentido es unívoco: la interpretación es una operación lógica previa e inevitable a toda aplicación. Además, las reglas de interpretación de los artículos **1560** y siguientes, y muy señaladamente el principio de buena fe del artículo **1546**, pertenecen al *orden público* contractual y no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes. Una cláusula que pretenda excluir toda interpretación choca, así, contra normas indisponibles, y debe tenerse por no escrita en cuanto persigue ese efecto.

8.3.2. La cláusula «responderá de todo o de cualquier incumplimiento»

Cuando se estipula que el deudor «responderá de todo incumplimiento» o «de cualquier incumplimiento», se está ante una cláusula *agravatoria* que conviene precisar. En el sistema del Código, lo *normal* es que el incumplimiento provenga de culpa: por eso la culpa contractual **se presume** (art. **1547** inc. 3.º: «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo»), conforme al llamado *principio de normalidad*. El dolo, en cambio, **no se presume** sino en los casos especialmente previstos por la ley, y debe probarse (art. **1459**). De ahí que la fórmula «responderá de

todo incumplimiento», interpretada restrictivamente y conforme al régimen probatorio, deba entenderse referida al incumplimiento *culposo* —y, más precisamente, a la culpa leve que es el estándar general—, pero no transforme automáticamente la posición del deudor en una de responsabilidad por dolo, que requiere prueba y no admite presunción.

8.3.3. La cláusula «responderá de todo o de cualquier daño»

Análoga precisión exige la cláusula por la que el deudor «responderá de todo daño» o «de cualquier daño». Para medir su alcance hay que recordar la regla del artículo 1558: si no hay dolo, el deudor responde sólo de los perjuicios *directos previstos* (o que pudieron preverse) al tiempo del contrato; si hay dolo, responde también de los *directos imprevistos*. El dolo, además, según el artículo 1458 inc. 2.º, da lugar a la indemnización *total* del daño que produjo. De este modo, una cláusula que extienda la responsabilidad a «todo daño» opera, respecto del deudor que no actúa con dolo, como una *agravante* que lo obliga a soportar perjuicios imprevistos que ordinariamente no le serían imputables. Ahora bien, esa extensión tiene un límite estructural: el dolo y la culpa grave rompen la proporcionalidad del régimen y no pueden ser objeto de agravación o de exoneración por esta vía. Como enseña Gatica, la regla del dolo «*no puede sufrir ninguna atenuación*», y el propio artículo 1558 inc. final, al admitir la modificación convencional, no permite alterar la regla que el dolo impone. La cláusula «de todo daño», por tanto, se mueve dentro del campo de la culpa, agravando la extensión del resarcimiento, pero sin poder invadir el terreno reservado al dolo y a la culpa lata.

8.3.4. La cláusula que excluye los «daños indirectos»

Frecuentísima en los contratos de inspiración anglosajona es la cláusula por la cual el deudor «no responderá de los daños indirectos» (*consequential damages*). Boetsch no comparte que esta cláusula sea válida desde una lectura puramente exegética del Código, y por buenas razones. Primero, porque el daño indirecto —aquel que no es consecuencia directa e inmediata del incumplimiento— *de suyo no se indemniza* en nuestro sistema, por faltarle el requisito de la **causalidad**: el artículo 1558 sólo hace responder de los perjuicios que son consecuencia directa del incumplimiento. Excluir lo que ya está excluido es, en este plano, una cláusula ino-

cua o redundante. Segundo, porque la categoría de los «daños indirectos», tomada del *Common Law*, es entre nosotros *indeterminada* e *indeterminable* con precisión, lo que la hace fuente de incertidumbre. De ahí que, para **Boetsch**, esta cláusula sólo cobra eficacia y sentido si se la reconduce a la figura de la **cláusula penal** (art. **1542**): las partes son libres de evaluar anticipadamente los perjuicios y de excluir convencionalmente ciertas partidas, pero entonces queda sujeta al control del artículo **1544**, que autoriza a reducir la pena enorme. Fuera de ese cauce, la pretendida exclusión de los daños indirectos carece de un asidero dogmático sólido en el Derecho chileno.

Dato de grado — Cómo abordar una cláusula modificatoria en el examen

Ante una cláusula que altera la responsabilidad, conviene seguir un orden: **(1)** calificarla —¿agrava, atenúa o exonera?—; **(2)** verificar el *límite infranqueable*: jamás puede condonarse el dolo ni la culpa grave futuros (arts. **1465** y **44**), so pena de objeto ilícito y nulidad absoluta (art. **1682**); **(3)** recordar que la alteración *no se presume* y exige estipulación expresa (arts. **1547** y **1558** incisos finales, y **1673**); **(4)** interpretarla *restrictivamente* y conforme a la buena fe (arts. **1546**, **1560**, **1563**); y **(5)** reconducir, cuando proceda, la fórmula al molde de la cláusula penal (arts. **1542** y **1544**). Quien domina este esquema resuelve cualquier variante que le propongan.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 8 — Cláusulas que modifican la responsabilidad**. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** antes de continuar. Asegúrate de distinguir con nitidez entre cláusulas que agravan, atenúan y exoneran, y de tener siempre presente el límite del dolo y la culpa grave futuros.